

MANUAL

Responsabilidad extracontractual del Estado

*Daño, causalidad, títulos de imputación, responsabilidad por la actividad judicial
y del legislador, reparación directa, Ley 2195 de 2022 y acción de repetición*

Teoría, normas, jurisprudencia y casos
Derecho colombiano

JULIANA HERNÁNDEZ GALVIS

Octubre de 2026

Índice general

Presentación	v
1 La responsabilidad extracontractual y su diferencia con otros regímenes de responsabilidad	1
1.1 ¿Qué es la responsabilidad?	1
1.2 Evolución histórica de la responsabilidad extracontractual	2
1.3 Responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva	4
1.4 Concepto de responsabilidad extracontractual	4
1.5 Responsabilidad extracontractual y responsabilidad contractual	4
1.6 Responsabilidad extracontractual y responsabilidad penal	5
2 Nociones generales del derecho civil	7
2.1 La responsabilidad extracontractual como fuente de obligaciones (art. 1494 del C.C.)	7
2.2 Fundamento de la responsabilidad extracontractual (art. 2341 del C.C.)	7
2.3 Noción de culpa en el Código Civil	8
2.4 Regímenes subjetivos de responsabilidad	8
2.5 La revolución industrial y los regímenes objetivos	9
2.6 Responsabilidad directa e indirecta	10
2.7 Relaciones entre la responsabilidad extracontractual y la penal	12
2.8 Funciones de la responsabilidad extracontractual	13
2.9 ¿Quién define el fundamento de la responsabilidad y sus consecuencias?	14
3 Historia de la responsabilidad extracontractual del Estado	15
3.1 Evolución de la responsabilidad del Estado	15
3.2 El Fallo Blanco (Tribunal de Conflictos, 8 de febrero de 1873)	16
3.3 La responsabilidad del Estado en Colombia	17
3.4 La Asamblea Nacional Constituyente de 1991	22
3.5 La responsabilidad extracontractual del Estado después de 1991	26
3.6 <i>Iura novit curia</i> y estudio de los títulos de imputación	28
3.7 Función de la responsabilidad extracontractual del Estado	31
3.8 Caso integrador: vehículo oficial y actividad peligrosa (el alcalde de Pinchote)	31
4 Primer elemento constante de la responsabilidad: el daño y el perjuicio	32
4.1 Los elementos constantes de la responsabilidad	32
4.2 Daño y perjuicio	32
4.3 Primera utilidad: la caducidad	33

4.4	Segunda utilidad: víctimas directas e indirectas	36
4.5	Características (requisitos) del perjuicio indemnizable	36
4.6	Tipologías de perjuicios en la jurisdicción de lo contencioso administrativo	43
4.7	El daño emergente	43
4.8	El lucro cesante	45
4.9	Los perjuicios morales	50
4.10	El daño a la salud	55
4.11	Daños por la vulneración de bienes constitucional y convencionalmente protegidos	57
5	Segundo elemento constante de la responsabilidad: la causalidad	59
5.1	El problema: causa material y causa jurídica	59
5.2	La causalidad como elemento constante	59
5.3	Los dos niveles de imputación	60
5.4	Teorías sobre la causalidad	60
5.5	La teoría de la imputación objetiva	62
5.6	Problemáticas reales en el estudio de la causalidad	64
5.7	Causales de ruptura del nexo causal: la causa extraña	67
5.8	Requisitos de la causa extraña	67
5.9	¿Toda acción del agente estatal genera responsabilidad del Estado? La culpa personal del agente	69
5.10	¿Los daños causados por particulares son imputables al Estado?	70
5.11	Concurrencia de causas en la producción del daño	71
5.12	Mecanismos de compensación de daños	73
6	Títulos de imputación	76
6.1	Factores de atribución en la responsabilidad extracontractual civil	76
6.2	Factores de atribución en la responsabilidad extracontractual del Estado (posición mayoritaria)	76
6.3	La falla del servicio	76
6.4	Regímenes de responsabilidad basados en la falla del servicio	77
6.5	Regímenes de responsabilidad objetiva	82
7	Otros temas relacionados con la responsabilidad extracontractual del Estado	84
7.1	Daños antijurídicos causados por la acción u omisión de los agentes judiciales	84
7.2	El error judicial	84
7.3	La privación injusta de la libertad	88
7.4	Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia	91
7.5	Responsabilidad por el hecho del legislador y del constituyente	91
7.6	El favorecimiento de la víctima (<i>favor victimae</i>)	93
7.7	Responsabilidad precontractual	95
7.8	Responsabilidad contractual: la existencia del contrato	95
8	La reparación directa como vía procesal para reclamar la responsabilidad extracontractual del Estado	97
8.1	El medio de control de reparación directa (art. 140 de la Ley 1437 de 2011)	97
8.2	Fuente del daño	97

8.3	¿Qué se puede pedir?	98
8.4	Legitimación en la causa por activa	98
8.5	Caducidad	98
8.6	Otras reglas procesales relevantes	98
9	La desnaturalización de la responsabilidad extracontractual del Estado en la Ley 2195 de 2022	100
9.1	Introducción: el flagelo de la corrupción	100
9.2	La reparación directa antes y después de la Ley 2195	100
9.3	Responsabilidad extracontractual derivada del delito	101
9.4	Exposición de motivos: la supuesta insuficiencia de los mecanismos existentes	101
9.5	Reparación del daño e insuficiencia de los instrumentos existentes	101
9.6	Reparación de perjuicios	102
9.7	¿Qué es un acto de corrupción y cómo se determina su ocurrencia?	102
9.8	<i>Non bis in idem</i>	102
9.9	Caducidad	102
9.10	Imposición de multas (art. 61)	103
9.11	Problemas prácticos del <i>non bis in idem</i> entre la reparación directa y el proceso de responsabilidad fiscal	103
9.12	Función de la responsabilidad extracontractual del Estado	104
9.13	Conclusiones	104
10	La responsabilidad patrimonial del agente estatal: la acción de repetición	105
10.1	Normas relevantes anteriores a la Constitución (Código Contencioso Administrativo)	105
10.2	La Constitución de 1991	105
10.3	Limitaciones constitucionales para el ejercicio de la acción de repetición	106
10.4	El esquema constitucional	107
10.5	La Ley 678 de 2001	109
10.6	La Ley 2195 de 2022	111
10.7	Jurisprudencia relevante reciente sobre la acción de repetición	112

Presentación

Este manual expone la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia: sus antecedentes en el derecho civil y en la historia del derecho administrativo, la cláusula general del artículo 90 de la Constitución, los elementos de la responsabilidad (daño y nexo causal), los títulos de imputación, la responsabilidad por la actividad judicial y por el hecho del legislador, el medio de control de reparación directa, las reformas de la Ley 2195 de 2022 y la responsabilidad patrimonial del agente estatal mediante la acción de repetición.

El contenido se elaboró exclusivamente a partir del material del curso de Responsabilidad extracontractual del Estado (diapositivas, apuntes y exposiciones de clase). Cada tema se desarrolla con definiciones, clasificaciones, normas, jurisprudencia y ejemplos, e incluye las principales críticas y debates sobre la materia.

Convenciones.

DEFINICIÓN. Definiciones de figuras y conceptos.

EJEMPLO. Ejemplos y casos, reales o hipotéticos.

COMENTARIO. Comentarios, críticas, debates y remisiones entre capítulos.

Citas textuales de normas, sentencias y doctrina.

Abreviaturas. C.C.: Código Civil. C.P.: Constitución Política. CPACA: Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). CCA: Código Contencioso Administrativo (anterior). CGP: Código General del Proceso. CE: Consejo de Estado. S3: Sección Tercera. CSJ: Corte Suprema de Justicia. Corte IDH / CIDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos. SMLMV / SMMLV: salarios mínimos legales mensuales vigentes. ANDJE: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. ANTV: Autoridad Nacional de Televisión.

Capítulo 1

La responsabilidad extracontractual y su diferencia con otros regímenes de responsabilidad

1.1 ¿Qué es la responsabilidad?

Un texto ilustra los distintos sentidos que tiene la palabra «responsabilidad» en el lenguaje común:

«Como capitán de un barco, X era responsable por la seguridad de sus pasajeros y su carga. Pero en su último viaje, se embriagaba todas las noches y fue responsable de la pérdida del barco con todo lo que llevaba. Se rumoraba que estaba loco, pero los médicos lo encontraron responsable de todas sus acciones. Durante el viaje, X se comportó muy irresponsablemente y varios incidentes que tuvo en su carrera demuestran que no era una persona responsable. El capitán siempre sostuvo que fueron las tormentas excepcionales las responsables por la pérdida del barco, pero en un proceso judicial que se le siguió fue encontrado responsable por la pérdida de vidas y bienes. Todavía vive y es moralmente responsable por la muerte de muchas mujeres y niños.»

EJEMPLO. En síntesis: el capitán es «responsable» por la seguridad de sus pasajeros; se embriaga todas las noches y es «responsable» de la pérdida del barco; los médicos lo encuentran «responsable» de sus actos; se comporta «irresponsablemente»; él culpa a las tormentas como «responsables» de la pérdida; un juez lo declara «responsable» de las vidas y bienes perdidos, y sigue siendo «moralmente responsable» de las muertes.

Sentidos de la palabra «responsabilidad» que muestra el ejemplo:

- Obligaciones o deberes derivados de un cargo.
- Factor causal.
- Estado mental e imputabilidad.
- Estándar de diligencia.
- Calificación de conductas reprochables.

1.2 Evolución histórica de la responsabilidad extracontractual

1.2.1 Derecho romano: la Ley de las XII Tablas

«Tab. 8, 10. El que hubiere incendiado una casa o un montón de trigo puesto junto a la casa, se manda que atado y azotado sea quemado vivo, si a sabiendas y deliberadamente hubiere hecho esto; pero si por casualidad, esto es, por negligencia, se manda o que resarza el daño, o, si no fuera solvente, es castigado con más lenidad; más en la denominación de la casa se comprenden todas las especies de edificios.»

«Tab. 8, 2. Si se ha amputado un miembro y no se logra la composición pecuniaria, se aplique el talión.»

«Tab. 8, 3. Si se ha fracturado un hueso a un hombre libre, está obligado a pagar la pena de 300 sestercios, si es un esclavo, de 150.»

«Tab. 8, 4. Si se injuria a otro, la pena es de 25 sestercios.»

En otras palabras: quien incendia una casa o el trigo junto a ella a sabiendas es azotado y quemado vivo; si lo hace por negligencia, debe resarcir el daño o, si es insolvente, recibe un castigo más leve. Si se amputa un miembro y no hay composición pecuniaria, se aplica el talión. Fracturar un hueso a un hombre libre se paga con 300 sestercios; a un esclavo, con 150. La injuria se paga con 25 sestercios.

Características:

- Distingue entre daños a las cosas y daños a las personas.
- Es un derecho casuístico.
- Confunde la responsabilidad penal con la extracontractual (confusión entre pena y reparación).
- La *iniuria* se entiende como acción (delito) o conducta antijurídica.

1.2.2 Derecho romano: la *Lex Aquilia*

«El que hubiere matado con injuria al esclavo o a la esclava ajenos, a un cuadrúpedo, o a una res, sea condenado a pagar al dueño el precio mayor que aquello tuvo en aquel año.»

«Respecto a las demás cosas, excepto el esclavo y las reses que hayan sido muertos, si alguien hiciere daño a otro, porque hubiere quemado, quebrado o roto alguna cosa con injuria, sea condenado a pagar al dueño tanto cuanto aquella cosa valiere en los treinta días próximos.»

Es decir: quien mata con injuria a un esclavo o a un animal ajeno paga al dueño el mayor valor que tuvo en ese año; por las demás cosas que se quemen, quiebren o rompan con injuria, se paga lo que valían en los treinta días siguientes.

Características:

- La *iniuria* pasa a ser una calificación de la conducta: primero el dolo, luego la culpa.
- Surge una cláusula general de daño.

- Surgen criterios de valoración de perjuicios.
- Persisten la *iniuria* como delito y la confusión entre responsabilidad penal y extracontractual (entre pena y reparación).

1.2.3 Derecho romano: la acción edictal (*actio de effusis vel deiectis*)

«Si se hubiere arrojado o derramado alguna cosa en el sitio por donde vulgarmente se transita, o donde la gente se detiene, daré, contra el que allí habitare, acción en el duplo por cuanto daño con ello se hubiere causado o hecho. Si se dijera que del golpe de lo arrojado había perecido un hombre libre, daré acción de cincuenta áureos; si viviera, y se dijese que se le causó daño, daré acción para aquel contra quien se reclama sea condenado en tanto cuanto por tal cosa pareciera justo al juez.»

Es decir: si se arroja o derrama algo en un lugar de tránsito, se concede acción contra quien habita allí por el doble del daño; si muere un hombre libre, la acción es de cincuenta áureos; si sobrevive, por lo que el juez considere justo.

Características:

- Surgen las primeras hipótesis de responsabilidad objetiva.
- Nace del crecimiento urbanístico de Roma.
- Responde a la necesidad de indemnizar cuando es difícil individualizar al responsable.
- Se funda en la condición de *habitor* (quien habita el lugar).
- Sigue la lógica económica del principio *cuius commoda eius et incommoda*: quien se beneficia de algo también debe asumir sus inconvenientes.

1.2.4 Período moderno (anterior al Código Civil): el iusnaturalismo

En el período moderno, el iusnaturalismo, con autores como Grocio, contribuyó al abandono progresivo del derecho casuístico y a la expansión de la idea de daño. La culpa empezó a consolidarse como fundamento de la responsabilidad.

«Llamamos aquí *maleficium* a toda culpa, ya en el hacer, ya en no hacer, que pugna con aquello que los hombres deben hacer comúnmente o por razón de cierta cualidad. De tal culpa nace, naturalmente, obligación, si se hizo daño, de que se resarza.» (Grocio)

Características del iusnaturalismo:

- La culpa como fundamento de la responsabilidad.
- Abandono del derecho casuístico y expansión del daño.

Características del período premoderno (anterior a los códigos civiles):

- Simbiosis entre la moral cristiana y el derecho romano.
- La culpa como fundamento de la responsabilidad.
- Diferenciación entre la responsabilidad civil y la penal.

1.2.5 Surgimiento de los códigos civiles

Con la codificación quedan diferenciadas tres clases de responsabilidad:

- Responsabilidad penal.
- Responsabilidad contractual.
- Responsabilidad extracontractual.

1.3 Responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva

DEFINICIÓN. **Responsabilidad subjetiva:** aquella en la que, para atribuir responsabilidad, debe probarse que el autor del daño actuó con culpa o dolo, además de probarse el daño y el nexo causal.

$$\text{Régimen subjetivo} = \text{daño} + \text{nexo causal} + \text{culpa}$$

DEFINICIÓN. **Responsabilidad objetiva:** no exige probar culpa o dolo; basta acreditar el daño y su imputación conforme al régimen jurídico aplicable.

$$\text{Régimen objetivo} = \text{daño} + \text{nexo causal (o relación de imputación)}$$

En el régimen subjetivo deben estar los tres elementos para que haya condena; en el objetivo, dos. En Colombia, la falla del servicio responde a una lógica subjetiva, mientras que títulos como el riesgo excepcional y el daño especial corresponden a esquemas objetivos.

COMENTARIO. Debe distinguirse entre los elementos que estructuran la responsabilidad (tres en el régimen subjetivo, dos en el objetivo) y quién tiene la carga de probarlos: son problemas diferentes.

1.4 Concepto de responsabilidad extracontractual

DEFINICIÓN. **Responsabilidad extracontractual:** es la obligación de reparar daños causados por hechos jurídicos. Es una fuente de obligaciones en materia civil y surge por daños producidos por hechos distintos de los contratos.

Diferencia entre acto y hecho jurídico:

DEFINICIÓN. **Acto jurídico:** manifestación de voluntad encaminada a producir efectos jurídicos, o acuerdo de voluntades entre sujetos que buscan generar efectos jurídicos.

DEFINICIÓN. **Hecho jurídico:** fenómeno humano o no humano que produce consecuencias jurídicas sin que exista o medie necesariamente la voluntad de producir ese efecto jurídico concreto.

1.5 Responsabilidad extracontractual y responsabilidad contractual

1.5.1 Diferencias

Criterio	Responsabilidad extra-contractual	Responsabilidad contractual
Fuente del daño	Hecho jurídico	Acto jurídico o contrato
Elementos	Según el régimen: subjetivo (daño, nexo y culpa) u objetivo (daño y nexo causal o imputación)	Contrato + incumplimiento + daño + nexo causal + imputación
Indemnización	Reparación integral del daño	Por regla general, solo los daños previsibles; si hay dolo, también los perjuicios inmediatos o directos (art. 1616 del C.C.)

Elementos en la responsabilidad contractual. Sí se exige imputación al deudor; la culpa puede integrar ese juicio de imputación, pero no siempre debe ser probada por el acreedor, pues en ciertos eventos se presume con el incumplimiento.

- **Obligaciones de medio:** la responsabilidad contractual suele ser subjetiva; se analiza si el deudor actuó con la diligencia debida.
- **Obligaciones de resultado:** la responsabilidad contractual es objetiva; no hay que demostrar si se incumplió con o sin culpa: basta, en principio, demostrar que el resultado prometido no se obtuvo, y el deudor debe acreditar una causa que lo exonere.

Indemnización en la responsabilidad contractual. Solo se reclaman los perjuicios previsibles, a menos que haya dolo (art. 1616 del C.C.).

1.5.2 Similitudes

En ambos ámbitos puede existir responsabilidad subjetiva u objetiva, según la obligación y el régimen aplicable:

- Régimen subjetivo de responsabilidad.
- Régimen objetivo de responsabilidad.

1.6 Responsabilidad extracontractual y responsabilidad penal

1.6.1 Diferencias

Criterio	Responsabilidad extra-contractual	Responsabilidad penal
Elementos	Subjetivo: daño, nexo y culpa. Objetivo: daño y nexo causal o imputación	Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad

Criterio	Responsabilidad extra-contractual	Responsabilidad penal
Función (¿para qué existe?)	Principalmente resarcitoria o indemnizatoria: reparar el daño injustamente causado y restablecer, en lo posible, el equilibrio alterado	Retributiva, sancionatoria, preventiva general y especial, y resocializadora
Consecuencia	Condena indemnizatoria (monetaria)	Penas previamente tipificadas en el Código Penal, incluida la privación o restricción de la libertad, y penas accesorias

La función de la responsabilidad extracontractual. Busca reparar el daño injustamente causado a una persona y restablecer, en la medida de lo posible, el equilibrio alterado por ese daño. Su función esencial es resarcitoria o indemnizatoria: que la víctima sea compensada por los perjuicios sufridos. Además, se le atribuye una función preventiva (incentiva a las personas y a las autoridades a actuar con diligencia para evitar daños) y una función de distribución de riesgos, especialmente en regímenes de responsabilidad objetiva. En el caso del Estado colombiano, esta función se conecta con el artículo 90 de la Constitución, que impone la obligación de reparar los daños antijurídicos que le sean imputables. (Sobre las objeciones a la función preventiva, ver Capítulo 2, sección 2.8.)

1.6.2 Similitudes

- **La fuente de la responsabilidad:** un mismo evento puede activar los dos mundos. El delito es, al mismo tiempo, un hecho jurídico generador de responsabilidad civil extracontractual; por eso se activan ambas responsabilidades, la penal y la civil extracontractual.

EJEMPLO. El caso O. J. Simpson: fue absuelto en el proceso penal (por duda), pero perdió el proceso civil y fue condenado a pagar por el homicidio de su esposa.

- **El estudio de la causalidad:** en ambos campos es relevante.

COMENTARIO. Las teorías sobre la causalidad (equivalencia de las condiciones, causa próxima, causalidad adecuada e imputación objetiva) se originaron en el derecho penal y luego fueron trasladadas por los civilistas y por la jurisdicción de lo contencioso administrativo a la responsabilidad extracontractual (ver Capítulo 5). Además, la acción penal y la acción de reparación directa son acciones diferentes (ver Capítulo 4).

Capítulo 2

Nociones generales del derecho civil

2.1 La responsabilidad extracontractual como fuente de obligaciones (art. 1494 del C.C.)

«ARTÍCULO 1494. Fuente de las obligaciones. Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia.» (Código Civil)

Importancia. Este artículo permite ubicar la responsabilidad extracontractual como fuente de obligaciones: indica que el delito es un hecho jurídico y que los hechos jurídicos son fuente de la responsabilidad extracontractual (pueden generar obligaciones de reparar). Además, muestra:

- La autonomía, pero también las relaciones, entre la responsabilidad extracontractual y la penal.
- La autonomía entre la responsabilidad extracontractual y la contractual.

COMENTARIO. La responsabilidad extracontractual da lugar a obligaciones de carácter personal y no de carácter real. Esta precisión es la base del requisito del «carácter personal del perjuicio» (ver Capítulo 4).

2.2 Fundamento de la responsabilidad extracontractual (art. 2341 del C.C.)

«ARTÍCULO 2341. Responsabilidad extracontractual. El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido.» (Código Civil)

Importancia. Establece el fundamento general de la responsabilidad extracontractual civil: la culpa. «Fundamento» significa el porqué se responde: en materia civil, por regla

general, se responde por culpa porque el legislador así lo dispuso en la norma, y por eso debe probarse la culpa. El art. 2341 es la norma que establece el régimen subjetivo de responsabilidad.

- Se evoluciona de la *iniuria* a la culpa como fundamento de la responsabilidad.
- La culpa es el fundamento de la responsabilidad extracontractual civil.

2.3 Noción de culpa en el Código Civil

- **¿El Código Civil define la culpa extracontractual?** No. El art. 63 del C.C. define la culpa en materia contractual (manejo de negocios) y regula sus grados. No existe una definición legal de la culpa extracontractual.
- El art. 2341 la exige como fundamento general; su contenido lo han desarrollado la doctrina y la jurisprudencia como la infracción del deber de cuidado exigible.
- **La tridivisión del art. 63 no aplica en la responsabilidad extracontractual.** Los grados de culpa están encaminados al mundo de los contratos. En el mundo de los hechos jurídicos la tridivisión no tiene razón de ser: no importa si la culpa es leve, grave o levísima; si el daño es imputable, se responde por todo el daño, porque la reparación es integral.

DEFINICIÓN. Culpa (definición doctrinal de los hermanos Mazeaud): «un error de conducta tal, que no lo habría cometido una persona cuidadosa situada en las mismas circunstancias externas que el autor del daño».

- **Análisis en abstracto:** la culpa se valora comparando la conducta del autor con la de esa persona cuidadosa.
- **Culpa y culpabilidad no son sinónimos.** La acción de repetición, por ejemplo, procede por dolo o culpa grave y exige un juicio específico de culpabilidad del agente (ver Capítulo 10).

2.4 Regímenes subjetivos de responsabilidad

Elementos	Exoneración
1. Daño o perjuicio (para los administrativistas son conceptos distintos)	Ausencia de daño o perjuicio
2. Nexo de causalidad: demostrar que el daño proviene de una acción u omisión del demandado	Ruptura del nexo causal, probando alguna de estas causas: hecho exclusivo de un tercero, hecho exclusivo de la víctima, fuerza mayor o caso fortuito
3. Culpa: debe acreditarse para que haya condena	Ausencia de culpa o diligencia: probar que se actuó de manera diligente y prudente

El demandado se exonera destruyendo alguno de los tres elementos.

2.4.1 Aspecto probatorio: el art. 167 del CGP

A cada parte le corresponde probar los hechos en que funda sus afirmaciones y excepciones. Si se es demandante, se debe probar el daño, el nexo y la culpa; si el demandado se quiere exonerar, debe probar las excepciones que alega (por ejemplo, el hecho de un tercero, o que obró con diligencia) o controvertir los hechos.

2.4.2 La carga dinámica de la prueba

DEFINICIÓN. Carga dinámica de la prueba: el juez, de oficio o a petición de parte, puede distribuir la carga de probar determinados hechos y asignarla a quien se encuentre en mejores condiciones para acreditarlos, por tener mayor cercanía, disponibilidad o facilidad de acceso a la prueba.

- Puede hacerse hasta antes de dictar sentencia.
- No es una inversión automática de toda la carga de la prueba, sino una redistribución según las circunstancias concretas del caso.
- Es frecuente en responsabilidad médica, donde el profesional o la institución de salud suele estar en una posición probatoria más favorable respecto de aspectos técnicos o científicos.

2.5 La revolución industrial y los regímenes objetivos

2.5.1 Origen histórico: influencia de la revolución industrial

- Surgimiento de actividades peligrosas en las fábricas y en la sociedad (máquinas, vehículos).
- Necesidad de proteger a los trabajadores de eventuales riesgos en el trabajo.
- Necesidad de proteger a los consumidores de los riesgos creados por actividades peligrosas.

2.5.2 Consecuencias: el favorecimiento de la víctima

- Régimen objetivo de responsabilidad para actividades peligrosas, originado a partir de una interpretación jurisprudencial «amplia» del art. 1384 del Código Civil francés (responsabilidad por el hecho de las cosas).
- Leyes relativas a accidentes de trabajo e indemnizaciones tarifadas.
- Socialización de riesgos a través de contratos de seguros obligatorios y no obligatorios.

Con la revolución industrial aumentó el uso de máquinas, vehículos y otros instrumentos capaces de generar riesgos significativos. Esto llevó a replantear el régimen tradicional de responsabilidad extracontractual, fundado principalmente en la culpa. Surgieron regímenes de responsabilidad objetiva, en los que la obligación de reparar no depende necesariamente de demostrar culpa, sino de la creación o materialización de un riesgo. Este desarrollo tuvo una importante influencia de la jurisprudencia francesa. Paralelamente, el crecimiento de estas actividades riesgosas impulsó la utilización de contratos de seguro como mecanismo para distribuir y cubrir económicamente los riesgos.

2.5.3 Responsabilidad extracontractual por actividades peligrosas

- **Fundamento: la creación del riesgo.** No está principalmente en la culpa, sino en el riesgo creado por el desarrollo de una actividad peligrosa o por el uso de una cosa peligrosa.
- **Responsabilidad del guardián.** Responde quien tiene la guarda material o jurídica de la actividad o del instrumento, es decir, quien ejerce poder de dirección, control y manejo sobre este y obtiene provecho de su utilización.

EJEMPLO. Si Óscar es propietario y guardián de una motocicleta y conserva sobre ella poder de dirección y control, puede llegar a responder por los daños causados con su utilización, incluso cuando sea otra persona quien la conduzca, dependiendo de las circunstancias del caso.

- **Clases de cosas peligrosas:**
 - Por su estructura: cuando su propia naturaleza implica un riesgo especial.
 - Por su comportamiento: cuando adquieren peligrosidad por la forma en que son utilizadas, manipuladas o puestas en funcionamiento.

2.5.4 Regímenes objetivos de responsabilidad: elementos y exoneración

Elementos	Exoneración
1. Daño o perjuicio	Ausencia de daño o perjuicio
2. Nexo causal entre la actividad peligrosa y el daño	Ruptura del nexo de causalidad mediante una causa extraña

La diligencia no exonera, porque está en el ámbito de la culpa y la culpa no es elemento del régimen: el demandado no puede decir que iba manejando bien, que paró o que fue diligente.

COMENTARIO. Conclusión. En responsabilidad extracontractual la regla general es el régimen subjetivo, fundado en la culpa. Sin embargo, existen eventos de régimen objetivo, especialmente cuando el daño proviene del desarrollo de una actividad peligrosa o del uso de una cosa o instrumento peligroso; allí el fundamento se desplaza de la culpa al riesgo creado.

COMENTARIO. Síntesis. En materia civil, el fundamento general de la responsabilidad es la culpa (art. 2341 del C.C.). Excepcionalmente, el fundamento es el riesgo: cuando se trata de actividades peligrosas o instrumentos peligrosos, lo que permite aplicar un régimen objetivo. En el ámbito contractual, la responsabilidad objetiva se aplica cuando hay obligaciones de custodia u obligaciones de resultado. Lo general es el régimen subjetivo y, excepcionalmente, en estas pocas situaciones, el régimen objetivo. La lógica en la responsabilidad estatal es bastante parecida (ver Capítulo 6).

2.6 Responsabilidad directa e indirecta

DEFINICIÓN. **Responsabilidad directa (por el hecho propio):** se presenta cuando en una misma persona coinciden el autor material del daño y el responsable de

repararlo; quien causa el daño es también quien debe responder por sus consecuencias.

DEFINICIÓN. Responsabilidad indirecta (por el hecho ajeno): se presenta cuando el autor material del daño y la persona llamada a responder son sujetos diferentes.

Aspecto	Responsabilidad directa	Responsabilidad indirecta
Fundamento legal	Art. 2341 del C.C.	Arts. 2347 y 2349 del C.C.
Fundamento de la imputación	Culpa o creación de riesgo por el causante del daño	Culpa o creación de riesgo por el causante del daño, más culpa <i>in eligendo</i> (elección inadecuada) o <i>in vigilando</i> (incumplimiento del deber de vigilancia o control) del responsable
Prescripción	Ordinaria del art. 2536 del C.C. (10 años), salvo regla especial	Especial del art. 2358 del C.C. (3 años contados desde la perpetración del acto)
Sujetos	Causante del daño = responsable del daño	Causante del daño $\neq$ responsable del daño

- El art. 2347 del C.C. establece que una persona puede responder por los hechos de quienes se encuentren bajo su cuidado o dependencia. Ejemplos tradicionales: la responsabilidad de los padres por determinados hechos de sus hijos y la del empleador por los hechos de sus dependientes, en los casos previstos por la ley.
- Frente a la víctima puede operar una presunción de culpa indirecta o mediata, de modo que no siempre debe demostrar directamente que el responsable escogió o vigiló mal.
- El término de tres años del art. 2358 debe distinguirse del régimen general aplicable a la responsabilidad directa.

EJEMPLO. Una empresa contrata a un mensajero que, durante el desarrollo de sus funciones, causa un accidente. Dependiendo de las circunstancias, la víctima puede reclamar no solo contra el autor material del daño, sino también contra quien jurídicamente deba responder por el hecho ajeno.

EJEMPLO. Caso: accidente de tránsito de un bus de una empresa de servicio público. En la demanda no se tiene que probar la culpa. El análisis de los posibles demandados es el siguiente:

- **Conductor:** responsabilidad directa y régimen objetivo (actividad peligrosa); término para demandar, 10 años.
- **Dueño del bus:** responsabilidad directa y régimen objetivo; término, 10 años. Puede responder como guardián de la actividad o del instrumento, según quién conserve la dirección y el control.
- **Empresa:** debe analizarse si su responsabilidad es directa o por el hecho ajeno y cuál es el fundamento de imputación. Si se le imputa la culpa *in vigilando* o *in eligendo* (régimen subjetivo), el término es de 3 años.

El caso sirve para distinguir la culpa *in vigilando* o *in eligendo* y los términos de prescripción.

2.7 Relaciones entre la responsabilidad extracontractual y la penal

El delito como fuente de daños. Un mismo hecho puede dar lugar a dos acciones: la acción penal y la acción civil. La absolución penal no siempre impide una condena civil.

«ARTÍCULO 2358. Prescripción de la acción de reparación. Las acciones para la reparación del daño proveniente de delito o culpa que puedan ejercitarse contra los que sean punibles por el delito o la culpa, se prescriben dentro de los términos señalados en el Código Penal para la prescripción de la pena principal. Las acciones para la reparación del daño que puedan ejercitarse contra terceros responsables, conforme a las disposiciones de este capítulo, prescriben en tres años contados desde la perpetración del acto.» (Código Civil)

Caminos de la víctima:

- Si la acción penal prescribe, se pierde el incidente de reparación integral de perjuicios.
- Se puede adelantar al mismo tiempo el proceso penal y el proceso civil; la pregunta es hasta qué punto la decisión penal ata la decisión del juez civil.

Elemento en común: la causalidad (Ley 600 de 2000). Existían dos artículos en la Ley 600 de 2000 que regulaban los efectos de la cosa juzgada penal en el proceso de reparación de perjuicios; hoy están derogados:

«Art. 57. Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria. La acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que la conducta causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa.»

«Art. 59. Efectos de la declaratoria de responsabilidad. Cuando no se hubiere constituido parte civil y se condene al procesado, la responsabilidad no podrá ser discutida en el proceso civil, debiendo limitarse éste a la clase y monto de los perjuicios.»

Las cuatro razones del art. 57. Si la absolución se daba por una de las cuatro razones, el proceso civil debía terminar automáticamente; si no, continuaba:

- **Razón 1 – La conducta no se realizó:** no hubo daño (falta el hecho dañoso).
- **Razón 2 – El sindicado no la cometió:** no hubo nexo causal.
- **Razón 3 – Obró en estricto cumplimiento de un deber legal:** solo importa, y solo exonera, si se está aplicando un régimen subjetivo de responsabilidad extracontractual.
- **Razón 4 – Obró en legítima defensa:** rompe el nexo causal; debe analizarse según el régimen civil aplicable.

En cualquier otro caso de absolución, el juez civil puede condenar: puede subsistir responsabilidad civil, porque los presupuestos y los estándares probatorios de ambos procesos son diferentes. La lógica de estos cuatro casos se sigue aplicando hoy, a pesar de que la norma ya no existe.

Art. 59. Con la sentencia penal condenatoria quedaba acreditada la responsabilidad, y en el proceso civil solo se discutía la tasación (clase y monto) del perjuicio, no el nexo causal.

COMENTARIO. Conclusión: aunque las dos normas no están vigentes, su lógica se sigue usando y debe explicársele al juez.

2.8 Funciones de la responsabilidad extracontractual

1. Reparatoria o compensatoria: busca reparar integralmente el daño causado.

2. Preventiva: parte de la doctrina se la atribuye, pero es discutible: el proceso no busca prevenir el daño, porque cuando se demanda el daño ya fue causado. Las acciones preventivas por excelencia son, por ejemplo, la acción popular y la tutela.

3. Demarcatoria: busca delimitar qué conductas son jurídicamente admisibles y cuáles no dentro de la sociedad, estableciendo estándares de comportamiento y señalando cuándo una actuación que causa daño genera el deber de responder. Se predica principalmente de los regímenes subjetivos, porque en ellos se valora la conducta del agente a partir de la culpa o el dolo; en los regímenes objetivos la responsabilidad no depende de demostrar que la conducta fue reprochable: no hay lugar a demarcar.

4. Distributiva: busca distribuir socialmente las consecuencias económicas del daño, especialmente a través de mecanismos de aseguramiento obligatorio o voluntario. El costo del daño no recae exclusivamente sobre quien lo causa, sino que se reparte entre un conjunto de personas que contribuyen al sistema mediante primas o aportes.

EJEMPLO. El SOAT: los propietarios de vehículos pagan una prima y, cuando ocurre un accidente de tránsito, el seguro cubre determinadas prestaciones con cargo al fondo común formado por esas contribuciones. Así, el riesgo y sus consecuencias económicas se redistribuyen entre todos los asegurados.

5. Sancionatoria: en principio, la responsabilidad extracontractual no busca sancionar al responsable, sino reparar integralmente el daño. En Estados Unidos existen los daños punitivos, que sí cumplen una función sancionatoria: el juez puede imponer una suma superior al valor del perjuicio para castigar conductas especialmente graves y disuadir su repetición; su cuantía puede atender al grado de reproche o culpabilidad de la conducta. En Colombia, como regla general, no existe la figura autónoma del daño punitivo en la responsabilidad civil: la indemnización debe corresponder al perjuicio efectivamente causado.

COMENTARIO. En principio la indemnización llega hasta el monto del perjuicio: «todo el perjuicio, nada más y nada menos que el perjuicio». Con esa base puede cuestionarse si la posibilidad de triplicar los perjuicios morales en graves violaciones de derechos humanos no introduce una función sancionatoria (ver Capítulo 4, perjuicios morales).

6. Expresiva: busca transmitir un mensaje de reconocimiento, reivindicación y restablecimiento de los derechos vulnerados, mediante medidas que no son exclusivamente económicas: medidas de satisfacción como disculpas públicas, actos de reconocimiento

de responsabilidad, rectificaciones o publicación de decisiones. En Colombia, el Consejo de Estado ha ordenado este tipo de medidas en casos de graves vulneraciones de derechos, incluida la privación injusta de la libertad, para reconocer públicamente la afectación sufrida por la víctima y contribuir a la reparación integral.

2.9 ¿Quién define el fundamento de la responsabilidad y sus consecuencias?

- La visión de la responsabilidad puede construirse desde la víctima o desde el responsable.
- ¿Quién lo define? El legislador.
- **Hoy, en la práctica**, es el juez quien define si el régimen es subjetivo u objetivo, porque ni la ley ni la Constitución regulan el tema; por eso, por los mismos hechos, se falla con regímenes diferentes. Cuando la ley o la Constitución no fijan expresamente un único régimen, el juez determina el título de imputación aplicable según los hechos y la jurisprudencia.

2.9.1 ¿A quién favorece cada régimen?

- **Régimen subjetivo: favorece más al demandado** en términos probatorios, porque impone al demandante una carga adicional: no basta demostrar el daño y el nexo causal; también debe acreditar la culpa o el dolo, salvo que opere alguna presunción. Eso hace más difícil estructurar la responsabilidad.
- **Régimen objetivo: favorece más a la víctima (demandante)**, porque no tiene que probar la culpa o el dolo; le basta acreditar los elementos de ese régimen, principalmente el daño, el nexo causal y la imputación. El demandado no se exonera demostrando que actuó con diligencia: normalmente debe acreditar una causa extraña que rompa el nexo causal (fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima o hecho exclusivo de un tercero).

2.9.2 La responsabilidad médica

La regla general en Colombia es que la responsabilidad médica es subjetiva: no basta con que el paciente haya sufrido un daño; debe demostrarse una falla en la conducta médica (negligencia, imprudencia, impericia o incumplimiento de la *lex artis*), además del daño y del nexo causal. El médico no responde simplemente porque el resultado haya sido desfavorable. Sin embargo, la carga de la prueba puede distribuirse dinámicamente cuando la institución o el profesional están en mejores condiciones de acreditar hechos técnicos. Hay situaciones específicas en que ciertas obligaciones pueden aproximarse a obligaciones de resultado, pero la atención médica ordinaria es, por regla general, una obligación de medio. (Sobre las excepciones en la responsabilidad médica del Estado —ginecobstetricia, cirugías estéticas, infecciones nosocomiales—, ver Capítulo 6.)

Capítulo 3

Historia de la responsabilidad extracontractual del Estado

3.1 Evolución de la responsabilidad del Estado

- **Edad Media:** *The king can do no wrong*; inmunidad o irresponsabilidad del gobernante, especialmente durante los regímenes absolutistas, bajo la concepción de que el soberano no respondía por los daños causados en ejercicio del poder.
- **Surgimiento del principio de legalidad y del Estado de derecho:** también las autoridades están sometidas al ordenamiento jurídico. El principio de legalidad tiene dos dimensiones: los particulares pueden hacer todo aquello que no esté prohibido por una norma previa y cierta; las autoridades solo pueden actuar dentro de las competencias que la Constitución y la ley les atribuyen previamente. A partir de allí se fortalece la posibilidad de exigir responsabilidad al Estado cuando su actuación causa daños.
- **Responsabilidad extracontractual del Estado basada en normas del derecho civil:** inicialmente se analizaba aplicando reglas del Código Civil.
- **Autonomía de la responsabilidad extracontractual del Estado:** progresivamente se construyó un régimen autónomo, con principios, normas y criterios propios del derecho administrativo.

3.1.1 Antecedentes: la Escuela del Servicio Público

En Francia adquirió especial importancia la Escuela del Servicio Público, según la cual el derecho administrativo encontraba buena parte de su justificación en que una de las funciones centrales del Estado era la prestación de servicios públicos orientados a satisfacer el interés general. Desde esta perspectiva, la actividad estatal no podía regirse exclusivamente por el derecho privado, pues el Estado actuaba con finalidades y potestades distintas de las de los particulares. Se consolidó así la idea de un régimen jurídico especial y autónomo, propio del derecho administrativo, aplicable tanto a la organización y prestación de los servicios públicos como a la responsabilidad derivada de su funcionamiento.

3.1.2 El surgimiento de la jurisdicción contencioso administrativa en Francia

Después de la Revolución francesa se consolidó una fuerte desconfianza frente a los jueces ordinarios, porque durante el Antiguo Régimen algunos tribunales habían obstaculizado reformas impulsadas por el poder político. Por ello, inicialmente se limitó la posibilidad de que los jueces intervinieran en asuntos administrativos y se fortalecieron órganos con funciones consultivas dentro de la propia Administración. Con el tiempo, Francia desarrolló un modelo de justicia dual: una jurisdicción ordinaria para los asuntos privados y una jurisdicción administrativa especializada para los conflictos relacionados con la actuación del Estado. Este modelo contrasta con sistemas de justicia más unitarios, como el de Estados Unidos.

3.2 El Fallo Blanco (Tribunal de Conflictos, 8 de febrero de 1873)

«Considerando que la responsabilidad, que podría incumbir al Estado por los daños ocasionados a particulares, como resultado de la actuación de personas empleadas en los servicios públicos, no puede regirse por los principios que se establecen en el Código Civil para las relaciones entre particulares. Que dicha responsabilidad no es ni general ni absoluta; que se rige por normas especiales que varían en función de las necesidades del servicio y de la necesidad de conciliar los derechos del Estado con los derechos privados; Que, por tanto, en virtud de las leyes antedichas, la autoridad administrativa es la única competente para conocer de esta causa;...»

EJEMPLO. Los hechos. Agnès Blanco, una niña, fue atropellada y gravemente lesionada por un vagón perteneciente a una fábrica de tabacos administrada por el Estado francés. Su padre demandó buscando que se aplicaran las reglas del Código Civil sobre responsabilidad.

El Tribunal de Conflictos adoptó dos decisiones fundamentales:

- **Decisión procesal:** el asunto debía ser conocido por la jurisdicción administrativa, porque el daño estaba relacionado con el funcionamiento de un servicio público estatal.
- **Decisión sustancial:** la responsabilidad del Estado por los daños causados por sus servidores no puede regirse automáticamente por las normas del Código Civil aplicables entre particulares, porque están de por medio la prestación de un servicio público, el interés general y la naturaleza especial de la actividad estatal. No es ni general ni absoluta: se rige por normas especiales propias del derecho administrativo, que varían según las necesidades del servicio y la necesidad de conciliar los derechos del Estado con los derechos privados.

Importancia. Es considerado una piedra angular del derecho administrativo moderno, porque consolidó la autonomía de la responsabilidad del Estado frente al derecho civil y reforzó la existencia de una jurisdicción especializada para conocer de estos conflictos.

COMENTARIO. Este fallo explica también la tensión entre las necesidades del servicio y los derechos de las víctimas, que está en la base del *favor victimae* (ver Capítulo 7, sección 7.6).

3.3 La responsabilidad del Estado en Colombia

3.3.1 Nacimiento de la jurisdicción contencioso administrativa en Colombia

- **Origen consultivo.** De manera semejante al antecedente francés, el Consejo de Estado tuvo inicialmente funciones consultivas. Fue creado por Simón Bolívar mediante un decreto expedido en Angostura el 30 de octubre de 1817 (no por el Congreso de Angostura, que se reunió en 1819). Durante el siglo XIX su existencia fue intermitente: algunas constituciones lo contemplaron y otras lo suprimieron.
- **La Constitución de 1886** permitió establecer la jurisdicción contencioso administrativa: su artículo 164 habilitó al legislador para organizarla y el artículo 141 contempló que el Consejo de Estado ejerciera funciones jurisdiccionales si la ley establecía esa jurisdicción.
- **La Ley 130 de 1913** materializó su organización y constituye el primer Código Contencioso Administrativo. En 1914 se restableció el Consejo de Estado como órgano consultivo y tribunal supremo de esta jurisdicción.
- **Dualidad de jurisdicciones:** se adoptó la separación entre la jurisdicción ordinaria y la contencioso administrativa, siguiendo la influencia francesa y la necesidad de contar con un juez especializado en asuntos administrativos.
- **Competencia inicial y diferencia con Francia:** la jurisdicción contencioso administrativa colombiana comenzó principalmente como juez de legalidad de los actos administrativos, mediante mecanismos antecedentes de las actuales pretensiones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho; inicialmente no tenía una competencia general sobre responsabilidad contractual y extracontractual del Estado. En Francia, la jurisdicción administrativa ya había desarrollado competencias sobre responsabilidad estatal (aunque no conocía todos los pleitos del Estado, pues también había asuntos atribuidos a la justicia ordinaria). Por esa distribución, buena parte de las controversias sobre responsabilidad extracontractual estatal en Colombia fue resuelta inicialmente por la jurisdicción ordinaria.
- **Ampliación de competencias:** la Ley 167 de 1941 amplió las competencias de la jurisdicción administrativa en asuntos específicos, como las indemnizaciones por trabajos públicos. El traslado general de las controversias sobre contratos administrativos y responsabilidad extracontractual se consolidó con el Decreto 528 de 1964 (no ocurrió de manera general en 1941 ni mediante decretos leyes de ese año).

3.3.2 Períodos de la responsabilidad del Estado en Colombia

Período	Jurisdicción competente
1886-1941	Jurisdicción ordinaria
1941-1991	Jurisdicción de lo contencioso administrativo

3.3.3 Fundamentos aplicados por la jurisdicción ordinaria (posiciones de la Corte Suprema de Justicia)

La Corte Suprema construyó inicialmente la responsabilidad estatal aplicando las reglas del Código Civil. Su evolución puede organizarse en etapas, aunque las distintas tesis coexistieron y no se sustituyeron de forma completamente sucesiva.

1. Primer período – Personas jurídicas: remisión a las normas sobre responsabilidad indirecta. La Corte aplicó al Estado la responsabilidad por el hecho ajeno que utilizaba para las personas jurídicas: el funcionario causaba el daño y la entidad respondía por la culpa en su elección (*in eligendo*) o vigilancia (*in vigilando*). Esta tesis podía desfavorecer a la víctima por dos razones:

- El término de prescripción de tres años aplicable a la responsabilidad indirecta era más corto.
- La discusión se centraba en la elección o vigilancia del agente (esta culpa podía presumirse, por lo que no siempre correspondía a la víctima demostrar directamente que la entidad había elegido o vigilado mal).

2. Segundo período – Personas jurídicas: remisión a las normas sobre responsabilidad directa. La actuación de los agentes empezó a atribuirse directamente a la persona jurídica, que respondía por una conducta jurídicamente propia.

- Se aplicaba el término ordinario de prescripción de veinte años vigente en esa época, más amplio y favorable para reclamar.
- El fundamento dejó de ser la culpa en la elección o vigilancia y pasó a ser la conducta atribuible a la propia entidad.

3. Tercer período – Tesis organicista. Distinguía entre dos clases de agentes dentro de la persona jurídica:

- **Órganos (agentes órganos) de dirección o representación:** expresaban la voluntad de la entidad y comprometían su responsabilidad directa.
- **Agentes subalternos:** ejecutaban las órdenes de los directivos y sus actuaciones generaban responsabilidad indirecta.

EJEMPLO. El fallo Tinjacá (1962) consolidó la responsabilidad directa y superó esa distinción jerárquica: la actuación funcional del agente se atribuye a la Administración, independientemente de que sea directivo o subalterno.

4. Falla del servicio. La Corte Suprema la desarrolló inicialmente y luego el Consejo de Estado la retomó y profundizó. Con la ampliación de sus competencias, especialmente en 1964, la jurisdicción administrativa consolidó el estudio de la responsabilidad estatal mediante distintos títulos (falla del servicio, daño especial y riesgo excepcional), que tienen antecedentes propios y no surgieron todos después de una transferencia general de competencias en 1941.

3.3.4 Fundamentos aplicados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo antes de 1991

Antes de la Constitución de 1991 se aplicaban tres fundamentos: la falla del servicio, el riesgo excepcional y el daño especial.

a) Falla del servicio

«ARTÍCULO 16. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.» (Constitución de 1886)

Fundamento. El artículo 16 de la Constitución de 1886 establecía el deber de las autoridades de proteger la vida, honra y bienes de las personas. Cuando el Estado incumple ese deber de protección, puede configurarse una falla del servicio.

Modalidades. La falla del servicio se presenta cuando el Estado:

- **No presta el servicio:** omisión del servicio.
- **Lo presta tardíamente:** actúa después del momento en que debía hacerlo.
- **Lo presta defectuosamente:** actúa, pero de manera inadecuada o incumpliendo sus deberes.

Naturaleza: régimen subjetivo. Exige demostrar que la Administración incumplió un deber (no prestó el servicio, lo prestó tardíamente o lo prestó defectuosamente). Se examina la conducta de la entidad, sin que sea necesario identificar a un funcionario culpable. Cumple una función equivalente a la culpa en materia civil: se compara cómo actuó la entidad estatal y cómo debía actuar según sus obligaciones y las circunstancias del caso; si su actuación estuvo por debajo del estándar exigible, se configura la falla. La sola ocurrencia del daño no basta: que alguien resulte lesionado o muera no demuestra automáticamente una falla del servicio; debe acreditarse el incumplimiento estatal y su relación con el daño.

Características (relatividad de la falla, falla anónima y falla presunta):

- **Relatividad.** La obligación estatal de protección es de medio, no absoluta: el Estado no puede estar omnipresente. Se exige una actuación diligente según las circunstancias, no garantizar que nunca ocurra un daño.

EJEMPLO. El barrio peligroso. El Estado no puede estar presente en todos los barrios peligrosos del país; por eso, si a alguien le roban en uno de ellos, no existe automáticamente responsabilidad por falla del servicio. Pero si los policías del CAI conocen lo que está ocurriendo y, pudiendo y debiendo intervenir, no hacen nada, puede existir falla del servicio por falta de protección.

- **Carácter anónimo.** La demanda se dirige contra la entidad estatal y no es necesario identificar el nombre del agente que causó el daño; basta demostrar la falla atribuible al funcionamiento de la Administración y su relación con el daño.
- **Falla presunta y carga dinámica de la prueba.** La regla general es que el demandante prueba los hechos que sustentan su reclamación y el demandado los que fundamentan sus excepciones (regla que estaba en el art. 177 del Código de Procedimiento Civil y hoy está en el art. 167 del Código General del Proceso). En la **falla presunta**, la falla se presume y corresponde a la entidad desvirtuarla demostrando que actuó adecuadamente; esto no significa que se presuman automáticamente el daño y el nexo causal. La **carga dinámica de la prueba** (art. 167 del CGP) permite al juez asignar la prueba de un hecho a la parte que esté en mejores condiciones para acreditarlo; lo decide mediante providencia motivada, antes de dictar sentencia, y debe permitir aportar y controvertir la prueba. No

se invierte automáticamente toda la carga del proceso, sino que se distribuye respecto de hechos determinados. La carga dinámica y la falla presunta son figuras distintas.

EJEMPLO. Responsabilidad médica estatal: el Consejo de Estado abandonó la aplicación general de la falla presunta y regresó a la falla probada. Una sentencia clave es la del 31 de agosto de 2006, expediente 15772.

COMENTARIO. El fundamento de la falla del servicio fue el artículo 16 de la Constitución de 1886, que hoy corresponde, en términos bastante similares, al artículo 2.º de la Constitución de 1991 (ver Capítulo 6).

b) Riesgo excepcional

«Tiene ocurrencia cuando el Estado, en desarrollo de una obra de servicio público utiliza recursos o medios que colocan a los particulares o a sus bienes en situación de quedar expuestos a "un riesgo de naturaleza excepcional" (De Laubadère) el cual dada su gravedad, excede las cargas que normalmente deben soportar los mismos particulares como contrapartida de las ventajas que resultan de la existencia de ese servicio público. Si el riesgo llega a realizarse y ocasiona un daño, sin culpa de la víctima, hay lugar a responsabilidad de la Administración, así no haya habido falta o falla del servicio.»

Naturaleza: régimen objetivo. El fundamento de la responsabilidad es la materialización del riesgo, no la culpa de la Administración. Por eso, demostrar que el Estado actuó diligentemente no basta para exonerarlo. Aplica solo cuando el daño proviene de un riesgo.

Elementos que deben acreditarse:

- Un riesgo excepcional atribuible a la actividad estatal.
- Un daño antijurídico.
- La relación entre la materialización del riesgo y el daño.

EJEMPLO. Caso fundador: la muerte de los novillos (Consejo de Estado, 2 de febrero de 1984, Exp. 2744). Un cable de energía eléctrica cayó sobre un potrero de la finca La Camelia, en Quimbaya; por el cortocircuito murieron seis novillos y otro quedó herido. El Consejo de Estado explicó que la responsabilidad podía surgir del riesgo excepcional creado por la conducción de energía eléctrica, sin necesidad de demostrar una falla del servicio.

Casos típicos: lesiones por disparos accidentales de armas de dotación oficial, electrocuciones causadas por redes eléctricas a cargo de una entidad estatal y vehículos oficiales, siempre que el daño sea atribuible a esa actividad peligrosa. La responsabilidad no es automática: puede existir una causa extraña que exonere al Estado.

c) Daño especial Concepto. Se aplica cuando el Estado, obrando lícitamente, causa un daño que rompe el equilibrio de las cargas públicas.

Naturaleza: régimen objetivo, porque no exige demostrar culpa ni falla del servicio: la responsabilidad surge de imponer a la víctima una carga especial y anormal que no tiene el deber jurídico de soportar.

Requisitos:

- **Actividad lícita del Estado:** la Administración actúa conforme al ordenamiento jurídico.
- **Ruptura de la igualdad ante las cargas públicas:** por vivir en sociedad soportamos cargas e incomodidades ordinarias, como los impuestos o el tráfico, que no generan automáticamente responsabilidad estatal. Pero cuando el Estado, aun actuando lícitamente, impone a una persona o a unas pocas una carga muy superior a la que normalmente soportan los demás, puede generar responsabilidad extracontractual.
- **Daño especial y anormal:** la afectación supera las cargas ordinarias de la vida en sociedad y la víctima no está jurídicamente obligada a soportarla.
- **Nexo causal** entre la actividad lícita del Estado y el daño.

«De una parte, dice, ningún ciudadano debe sufrir otras cargas que las impuestas a los demás en interés social. De otra, las necesidades de la vida colectiva exigen que cada uno soporte sin indemnización los daños resultantes del ejercicio legal y regular de la potencia pública, a menos que el legislador no disponga otra cosa. Y el segundo así: El daño producido por la Administración no da lugar a reparación sino en el caso en que es anormal por su importancia y por su carácter excepcional. La Administración tiene el derecho de imponer este sacrificio especial como gestora suprema del interés público pero mediante indemnización, al efecto de restablecer la igualdad de las cargas.»

EJEMPLO. Caso El Siglo, «el caso de los censores» (Consejo de Estado, 29 de julio de 1947): turbación del orden público por la captura del Presidente en un alzamiento militar en Pasto. Se omitió designar al censor del periódico El Siglo, que por eso no pudo publicar desde el 11 de julio hasta el 6 de agosto de 1944.

«La acción armada ejercida para capturar a Efraín González en cumplimiento de una orden judicial expedida por funcionario competente no constituye falla del servicio y fue, por lo mismo, legítima, pero ella causó un perjuicio económico a un tercero ajeno a esos hechos, consistente en la destrucción de una casa de propiedad de ese tercero, razón por la cual al Estado corresponde indemnizar el perjuicio causado, lo que equivale a hacer una equitativa distribución de las cargas públicas entre todos los contribuyentes desde luego que tal indemnización deberá hacerse con cargo al presupuesto de la Nación.»

EJEMPLO. Caso Efraín González (Consejo de Estado, 23 de mayo de 1973, Exp. 978): destrucción de una casa en la captura de Efraín González. El Ejército destruyó una casa para capturar a Efraín González, y la propietaria demandó al Estado. El demandante había arrendado la casa y quien la tenía en arriendo refugió a Efraín González. La acción armada, ejecutada en cumplimiento de una orden judicial de funcionario competente, fue legítima y no constituyó falla del servicio, pero causó un perjuicio a un tercero ajeno a los hechos: el Estado debía indemnizar con cargo al presupuesto de la Nación, como distribución equitativa de las cargas públicas entre todos los contribuyentes.

«Se puso en evidencia que la obra del puente de la 53 con la carrera 30 produjo un daño de carácter excepcional a los dueños del inmueble aledaño a dicha obra (número 28A-05 de la calle 53). Daño o perjuicio que no surge de una falla del servicio (la actividad de la entidad demandada fue legítima) sino del hecho de habersele

impuesto a los demandantes una carga especial en beneficio de la comunidad. Carga que rompe el principio de la igualdad frente a las cargas públicas (forma del principio general de la igualdad ante la ley).»

EJEMPLO. Caso del puente de la calle 53 con carrera 30 (Consejo de Estado, 30 de enero de 1987): la obra causó un daño excepcional a los dueños del inmueble aledaño. El daño no surgió de una falla del servicio, pues la actividad fue legítima, sino de una carga especial impuesta en beneficio de la comunidad, que rompió la igualdad frente a las cargas públicas.

3.4 La Asamblea Nacional Constituyente de 1991

3.4.1 Antecedentes

La Constituyente de 1991 constitucionalizó el principio de la responsabilidad extracontractual del Estado. El artículo 90 se convirtió en la cláusula general de responsabilidad del Estado.

3.4.2 La ponencia del artículo 90

1. De la antijuridicidad de la conducta a la antijuridicidad del daño.

«(...) En otras palabras, se desplaza el soporte de la responsabilidad administrativa, del concepto subjetivo de la antijuridicidad de la acción del Estado al concepto objetivo de la antijuridicidad del daño producido por ella. Esta antijuridicidad habrá de predicarse cuando se cause un detrimento patrimonial que carezca de título jurídico válido y que exceda el conjunto de las cargas que normalmente debe soportar el individuo en su vida social. (...)» (Gaceta Constitucional No. 56, p. 14)

Antes, especialmente bajo el régimen de falla del servicio, el análisis se concentraba en la conducta de la Administración: había que determinar si el Estado había actuado irregularmente, tardíamente, de manera deficiente o había omitido actuar. Con la Constitución de 1991, el centro del análisis se desplaza hacia la víctima y el daño sufrido: lo determinante es si existe un daño antijurídico, entendido como aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar. Esto no significa que desaparezca la falla del servicio: el artículo 90 no adoptó un único régimen de responsabilidad; siguen existiendo títulos subjetivos, como la falla del servicio, y objetivos, como el daño especial y el riesgo excepcional.

COMENTARIO. Idea clave: antes el énfasis estaba en preguntar «¿el Estado actuó mal?»; a partir del artículo 90, el punto de partida es «¿la víctima sufrió un daño que jurídicamente no estaba obligada a soportar, y ese daño es imputable al Estado?».

2. Ampliación de la responsabilidad del Estado: responsabilidad por la actividad judicial y por el hecho del legislador.

«(...) Tal como se ha redactado el artículo, cabe perfectamente la posibilidad, hacia la cual claramente se está inclinando el derecho moderno, de extender el régimen de la responsabilidad patrimonial del Estado a aquella que se deriva de los yerros de la administración de justicia y eventualmente, en el futuro, también a la responsabilidad que pueda derivarse de la función legislativa. (...)» (Gaceta Constitucional No. 56, p. 14)

La cláusula constitucional permite comprender la responsabilidad estatal de manera general y no únicamente frente a la actividad administrativa: puede surgir por actuaciones u omisiones de las distintas autoridades públicas, incluidos supuestos relacionados con la actividad legislativa y la administración de justicia. La Corte Constitucional ha precisado además que el artículo 90 comprende ámbitos contractuales y extracontractuales (ver la objeción en la sección 3.4.3).

3. Responsabilidad patrimonial de la entidad y del agente estatal.

«(...) Finalmente, he estimado de suma utilidad acoger dos planteamientos contenidos en algunos proyectos: el de que, para proteger a las víctimas, se les permita demandar indistintamente al Estado o a la autoridad pública involucrada; y el de que, para proteger el patrimonio público y combatir la indolencia personal del grueso de los funcionarios públicos, se le imponga al Estado el deber de repetir contra el funcionario culpable por las sumas por las que aquél hubiera sido condenado. (...)» (Gaceta Constitucional No. 56, p. 14)

Se acogieron dos propuestas: permitir a las víctimas demandar indistintamente al Estado o a la autoridad involucrada, y obligar al Estado a repetir contra el funcionario culpable, para proteger el patrimonio público y combatir la indolencia de los funcionarios. El modelo constitucional distingue ambas responsabilidades: frente a la víctima responde patrimonialmente el Estado cuando se cumplen los presupuestos del artículo 90; si el Estado es condenado y el daño fue consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes, surge el deber de ejercer la acción de repetición contra este.

4. La culpa grave o el dolo como limitación para repetir.

«(...) El delegatario Ramírez Ocampo (...) insiste en reducir el artículo, agrega que la repetición contra el funcionario va a conducir a que no haya quien acepte desempeñar cargos públicos, el constituyente Uribe Vargas se muestra de acuerdo. (...)» (Gaceta Constitucional No. 132, p. 19)

Por eso la repetición quedó limitada al dolo o la culpa grave.

3.4.3 El artículo 90 de la Constitución Política

«ARTÍCULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.»

Estructura. El artículo 90 tiene dos incisos:

- **Primer inciso:** responsabilidad patrimonial del Estado frente a la víctima. De él salen los dos grandes elementos constitucionales de la responsabilidad del Estado: (1) el daño antijurídico y (2) la imputación al Estado.
- **Segundo inciso:** responsabilidad del agente estatal frente al Estado mediante la repetición, cuando actuó con dolo o culpa grave.

Víctima → demanda al Estado → el Estado indemniza → si hubo dolo o culpa grave del agente → el Estado repite contra el agente

Alcance. La Corte Constitucional tiene la posición de que el artículo 90 es una cláusula general que se aplica a toda la responsabilidad, extracontractual y contractual. Puede objetarse que no debería aplicarse a la responsabilidad contractual, porque allí no se miran daños antijurídicos sino el incumplimiento del contrato.

COMENTARIO. El primer inciso regula la responsabilidad patrimonial del Estado y el segundo la responsabilidad patrimonial del agente, es decir, la acción de repetición (ver Capítulo 10).

3.4.4 El daño antijurídico

DEFINICIÓN. Daño antijurídico: el daño que la víctima no está en el deber jurídico de soportar; el que rompe el equilibrio ante las cargas públicas. No significa necesariamente que la actuación estatal sea ilegal.

Para que el daño sea antijurídico se requieren tres elementos, cada uno frente a su opuesto:

El daño antijurídico es...	...y se opone al daño que se debe soportar, que es...
Particular: afecta a una persona en concreto	General: una carga de todos, como los impuestos o el pico y placa
Anormal o grave	Normal: por ejemplo, una revisión policial ordinaria (deja de serlo si, durante la revisión, el agente le rompe una pierna a la persona)
Sin título jurídico que obligue a la víctima a soportarlo (inexistencia de título jurídico)	Con título jurídico válido: por ejemplo, una sentencia condenatoria válida justifica la privación de la libertad; no hay título si la persona fue privada de la libertad sin justa causa

EJEMPLO. Caso del profesor privado de la libertad. Una menor fue víctima de un acto sexual en el colegio. Medicina Legal concluyó que hubo acto sexual y había una inferencia razonable en contra del profesor que justificaba detenerlo. El profesor duró siete meses privado de la libertad y luego fue absuelto por duda. ¿Sufrió un daño antijurídico?

Las dos posiciones en la Sección Tercera del Consejo de Estado:

- **Subsecciones A y C:** para obtener indemnización debe acreditarse una falla del servicio, que se presenta, por ejemplo, cuando la medida de aseguramiento fue ilegal, irrazonable, desproporcionada o no cumplía los requisitos legales. Si la medida fue legal, en principio el Estado no responde bajo este título.
- **Subsección B:** en algunos casos ha sostenido una posición de responsabilidad objetiva, aplicando el daño especial: aunque la medida de aseguramiento haya sido legal, puede haber responsabilidad si la persona finalmente absuelta soportó una carga particular y anormal que no estaba jurídicamente obligada a soportar.

¿Por qué daño especial? Porque, aunque el Estado pudo haber actuado lícitamente al imponer la medida de aseguramiento —en ese momento había elementos que permitían inferir razonablemente la participación del profesor—, finalmente fue absuelto y no se desvirtuó su presunción de inocencia; terminó soportando una carga particular, grave y anormal, superior a la que normalmente debe soportar cualquier ciudadano, lo que

rompe el equilibrio frente a las cargas públicas, aun cuando no necesariamente haya existido una falla del servicio.

COMENTARIO. Sobre la evolución de la jurisprudencia en privación injusta de la libertad (unificaciones de 2006 y 2018, SU-072 de 2018) y el caso de la trata de personas, ver Capítulo 7, sección 7.3.

3.4.5 Responsabilidad del Estado y culpa personal del agente

Regla general. Según el artículo 90, la víctima demanda al Estado y, si este resulta condenado porque su agente actuó con dolo o culpa grave, posteriormente ejerce la acción de repetición contra el agente. Los sujetos frente a la víctima de un daño antijurídico son tres: la víctima, la entidad estatal y el agente estatal.

DEFINICIÓN. Culpa o falta personal del agente: se presenta cuando el servidor público causa el daño actuando dentro de su órbita estrictamente personal o privada, sin ningún nexo con el servicio. En esos casos el daño no es imputable al Estado, porque la simple calidad de servidor público del autor no basta para comprometer la responsabilidad de la entidad.

El Consejo de Estado ha dicho que «la simple calidad de funcionario público que ostente el autor del hecho no vincula necesariamente al Estado», porque el funcionario puede actuar en su ámbito privado, completamente separado de la actividad pública.

EJEMPLO. Un soldado, estando fuera del servicio, se emborracha y, por una discusión personal relacionada con una mujer, usa un arma y mata a otra persona. Si el hecho obedeció exclusivamente a una venganza, riña o motivo personal y no tuvo relación con sus funciones, se configura una culpa personal del agente sin conexión con el servicio: el Estado no responde y la responsabilidad recae personalmente sobre el agente. Frente al Estado, ese hecho se trata como un hecho de un tercero que lo exonera de responsabilidad (ver Capítulo 5, sección 5.9).

Pregunta clave: ¿el agente produjo el daño con ocasión o por razón del servicio, o actuó exclusivamente como un particular?

- **Si existe nexo con el servicio:** responde el Estado frente a la víctima y, si hubo dolo o culpa grave, puede repetir contra el agente.
- **Si existe una culpa personal completamente desligada del servicio:** el daño no se imputa al Estado y la responsabilidad corresponde personalmente al agente; la demanda se dirige ante la jurisdicción ordinaria.

3.4.6 Solidaridad y responsabilidad

- **Responsabilidad:** se paga porque hay un daño y un nexo causal (una relación jurídica de imputación o causalidad).
- **Solidaridad:** el pago se da sin relación de causalidad; es una ayuda económica.

COMENTARIO. No debe confundirse con las obligaciones solidarias (art. 2344 del C.C.), en las que varios deudores pueden estar llamados a responder por la totalidad frente al acreedor (ver Capítulo 5, secciones 5.2 y 5.11.1).

3.5 La responsabilidad extracontractual del Estado después de 1991

¿Qué régimen de responsabilidad consagra el artículo 90? Se distinguen dos etapas:

Período	Postura
1991-1993	Plena aplicación del artículo 90
1993 a hoy	Regreso a los títulos de imputación preconstitucionales

3.5.1 Plena aplicación del artículo 90 (1991-1993)

Inicialmente se consideró que el artículo 90 establecía un régimen objetivo de responsabilidad, porque desplazó el análisis desde la conducta del Estado hacia el daño antijurídico.

«(...) es necesario dar aplicación al artículo 90 de la misma Carta que consagra la responsabilidad patrimonial del estado y la condiciona a la ocurrencia de un daño antijurídico que le sea imputable y que sea causado por la acción u omisión de las autoridades públicas. (...) Probados los dos elementos que exige la Constitución como necesarios para el compromiso de la responsabilidad estatal de carácter patrimonial, es irrelevante para ese solo efecto, que la acción dañosa sea constituida o no de falla del servicio; esa adquirirá importancia para el arreglo final de las cuentas entre la administración y el funcionario comprometido cuando esa circunstancia se presenta, que no es del caso. (...)» (Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 5946, sentencia del 29 de octubre de 1992)

En síntesis: probados el daño antijurídico imputable y su causación por la acción u omisión de las autoridades, es irrelevante que la conducta constituya o no falla del servicio; la falla solo importa para el arreglo de cuentas entre la administración y el funcionario.

«(...) se impone concluir que el centro de imputación jurídica demandado es responsable de los perjuicios causados con el incendio en la casa vecina con apoyo en el artículo 90 de la Constitución Nacional que en forma expresa dispone que el Estado debe responder "... patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas". Es esta responsabilidad, como reiteradamente lo ha dicho la Sala, la atención del constituyente no se fijó en el autor de la conducta causante del daño, sino en la víctima misma. Por ello importa más reparar el daño causado, que castigar una acción u omisión administrativa culpable. La finalidad de la responsabilidad patrimonial no consiste, pues, en BORRAR UNA CULPA, sino en hacer recaer sobre el patrimonio de la administración, el DAÑO SUFRIDO por el particular. La Culpa ha dejado de ser el FUNDAMENTO ÚNICO del sistema indemnizatorio, convirtiéndose simplemente en uno de los criterios jurídicos de imputación de daños a la administración. Esta verdad jurídica explica la razón por la cual en muchos casos ella deba responder de los daños patrimoniales ocasionados no obstante haber tenido una actuación lícita. La filosofía que informa todo este universo jurídico se apoya en el PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD, que se recoge también en el artículo 1o. de la Constitución Nacional cuando se refiere a Colombia como un Estado Social de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad de la persona humana y en LA SOLIDARIDAD DE LAS PERSONAS QUE LA INTEGRAN. (...)» (Consejo

de Estado, Sección Tercera, Expediente 7130, sentencia del 26 de noviembre de 1992)

En síntesis (caso del incendio de la casa vecina): el constituyente fijó su atención en la víctima, no en el autor de la conducta; importa más reparar el daño que castigar una acción culpable. La culpa dejó de ser el fundamento único y pasó a ser uno de los criterios de imputación; por eso el Estado responde incluso por actuaciones lícitas. Su base es el principio de solidaridad del artículo 1.º de la Constitución.

«(...) Se consagró entonces en la norma superior transcrita la responsabilidad patrimonial del Estado, por las acciones u omisiones de las autoridades públicas que ocasionen un daño antijurídico, régimen bajo el cual, para casos como el examinado, a la parte actora le corresponde demostrar que por parte de la autoridad respectiva se dio un comportamiento activo u omisivo, que le generó algún daño y que esa conducta y el daño respectivo se encuentran causalmente relacionados. Frente a esta situación el Estado podrá exonerarse de responsabilidad, solamente si acredita la fuerza mayor, el hecho exclusivo de la víctima o el hecho exclusivo de un tercero, sin que pueda alegar como eximentes el caso fortuito o una conducta diligente y cuidadosa, por cuanto en ese tipo de responsabilidad, antes que la antijuridicidad del actuar del ente administrativo, lo que importa es la antijuridicidad del daño, el cual, resulta antijurídico cuando a pesar de ser legítima la conducta de la administración, la misma causa un perjuicio a quien no estaba obligado a soportarlo. (...)» (Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 7340, sentencia del 17 de febrero de 1993)

En síntesis: la parte actora debe demostrar la conducta activa u omisiva de la autoridad, el daño y la relación causal. El Estado solo se exonera con la fuerza mayor, el hecho exclusivo de la víctima o el hecho exclusivo de un tercero; no puede alegar el caso fortuito ni su diligencia, porque importa la antijuridicidad del daño y no la de la conducta.

3.5.2 Regreso a los títulos de imputación preconstitucionales (1993 a hoy)

«(...) No es del todo exacto que luego de la expedición de la Carta de 1991 la responsabilidad estatal se volvió objetiva y que en ningún evento se pueda probar la conducta irregular de la administración que produjo el daño, aunque sí puede estimarse que la jurisprudencia deberá tener también en cuenta ese criterio objetivista para su interpretación. (...) En síntesis, la nueva Constitución, a pesar de su amplitud en materia de responsabilidad, no la hizo exclusivamente objetiva ni borró del ordenamiento la responsabilidad por falla del servicio, ni por cualquiera otra fuente de las aceptadas por el derecho administrativo. Las nociones de imputabilidad y de daño antijurídico así lo dan a entender. (...)» (Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 7429, sentencia del 2 de marzo de 1993)

A partir de 1993, el Consejo de Estado reinterpretó la norma: el artículo 90 no volvió objetiva toda la responsabilidad del Estado ni eliminó la falla del servicio ni las demás fuentes aceptadas por el derecho administrativo; las nociones de daño antijurídico e imputación permiten mantener los distintos títulos de imputación.

- Por la vía de la imputación, el Consejo de Estado volvió a aplicar los tres títulos tradicionales: falla del servicio, riesgo excepcional y daño especial.

- La falla del servicio es el principal título de imputación y corresponde a un régimen subjetivo, porque exige analizar la conducta irregular de la Administración. Excepcionalmente se aplican el riesgo excepcional y el daño especial, que corresponden a regímenes objetivos, en los que no es necesario demostrar que el Estado actuó mal.

COMENTARIO. Crítica: esta reinterpretación puede cuestionarse, porque ni el texto del artículo 90 ni los debates de la Gaceta Constitucional dicen expresamente que deban mantenerse esos tres regímenes. El artículo 90 simplemente establece que el Estado responde por los daños antijurídicos que le sean imputables; fue la jurisprudencia la que, mediante el concepto de imputación, reincorporó la falla del servicio, el riesgo excepcional y el daño especial.

Síntesis: la responsabilidad del Estado en la Constitución de 1991 El artículo 90 establece una cláusula general de responsabilidad patrimonial que se estructura sobre dos elementos:

- **Daño antijurídico:** una lesión que la víctima no tiene el deber jurídico de soportar; no significa necesariamente que la actuación estatal sea ilegal.
- **Imputación al Estado:** debe demostrarse que el daño es atribuible a una acción u omisión de una autoridad pública, bajo alguno de los títulos:
 - Falla del servicio: régimen subjetivo; se acredita el incumplimiento de un deber estatal.
 - Riesgo excepcional: régimen objetivo; el daño proviene de la materialización de un riesgo excepcional atribuible al Estado.
 - Daño especial: régimen objetivo; una actuación estatal lícita impone a la víctima una carga especial y anormal, rompiendo la igualdad ante las cargas públicas.

La Constitución de 1991 no convirtió toda la responsabilidad estatal en objetiva ni eliminó la falla del servicio: estableció como base el daño antijurídico y su imputación, bajo distintos títulos.

3.6 *Iura novit curia* y estudio de los títulos de imputación

Es necesario distinguir entre el principio de congruencia, el principio de jurisdicción rogada y el *iura novit curia*.

3.6.1 El principio de congruencia

DEFINICIÓN. **Principio de congruencia:** exige correspondencia entre lo pedido por las partes y lo decidido por el juez.

Clases de incongruencia:

- **Extra petita:** el juez concede algo distinto de lo solicitado.

EJEMPLO. Se pidieron únicamente daño emergente y lucro cesante (o solo daño emergente), pero la sentencia reconoce perjuicios morales no solicitados.

- **Ultra petita:** el juez concede más de lo pedido.

EJEMPLO. El demandante solicita \$100 millones por perjuicios y el juez reconoce \$150 millones.

- **Citra o infra petita:** el juez deja sin resolver lo que debía decidir.

La congruencia aplica con mayor rigor en los procesos donde se discuten derechos dispositivos. Se flexibiliza en algunos procesos, como los laborales, la tutela y las acciones de grupo (ciertos procesos colectivos), donde el juez puede tener facultades más amplias de protección según la naturaleza de los derechos involucrados.

3.6.2 El principio de jurisdicción rogada

DEFINICIÓN. **Principio de jurisdicción rogada:** el juez, especialmente en lo contencioso administrativo, solo puede pronunciarse sobre aquello que las partes le solicitan y dentro de los cargos planteados en la demanda.

Aplica especialmente en los medios de control contra actos administrativos, en los que el juez analiza la legalidad del acto con base en los cargos de violación formulados por el demandante.

EJEMPLO. Sale una reglamentación en materia de contratación estatal y se demanda su artículo 2. Por el principio de jurisdicción rogada, el juez, en principio, solo puede anular el artículo 2 (no el 5) y con los motivos alegados.

Excepciones (no aplica o se flexibiliza):

- **Nulidad por inconstitucionalidad (art. 135 del CPACA):** el juez puede anular por cargos distintos y normas que no fueron demandadas si considera que forman una unidad.
- **Control inmediato de legalidad:** el control puede ser más amplio u oficioso.

3.6.3 El principio *iura novit curia*

DEFINICIÓN. **Iura novit curia:** «el juez conoce el derecho». «Incumbe a las partes dar los hechos y al juez el derecho aplicable». El juez puede aplicar la norma o el título jurídico correcto aunque las partes hayan citado otro o ninguno, siempre que respete los hechos de la demanda, las pretensiones y el derecho de defensa.

Reglas:

- El juez no está atado al título de imputación invocado en la demanda.
- No puede modificar los hechos (la imputación fáctica) ni las pretensiones.
- Puede hacer un estudio sucesivo de los títulos de imputación.

EJEMPLO. En una reparación directa, el demandante sostiene que hubo falla del servicio, pero el juez concluye que, con los mismos hechos probados, el título correcto es el riesgo excepcional. Puede cambiar el título jurídico sin violar el principio de congruencia, porque no modifica los hechos, sino únicamente su calificación jurídica.

EJEMPLO. Caso de Pedro y Juan. Pedro y Juan eran ganaderos y no regresaron a su casa; al día siguiente aparecieron muertos. Sus familiares demandaron al Estado afirmando que habían sido víctimas de un falso positivo: que fueron presentados como muertos en combate dentro de un operativo que, según los demandantes, no había existido. Durante el proceso se probó que sí había existido un operativo militar,

de modo que no quedó demostrada la imputación fáctica planteada en la demanda. Si el juez, pese a ello, cambia los hechos y condena al Estado partiendo de una versión distinta —por ejemplo, que murieron durante un operativo real, pero por un uso desproporcionado de la fuerza—, ya no estaría aplicando el *iura novit curia*: no estaría cambiando solo el derecho aplicable, sino también la causa fáctica de la demanda.

EJEMPLO. Caso de los niños del accidente del Agustiniano. Sirve para estudiar cómo el Consejo de Estado puede escoger el título de imputación aplicable sin alterar la base fáctica. Al condenar hubo una dualidad de título de imputación y se condenó por falla del servicio «por la función».

COMENTARIO. Idea clave: el *iura novit curia* permite al juez cambiar la calificación jurídica, pero no inventar o sustituir los hechos que fundamentan la demanda. El juez es libre de escoger el título de imputación, pero no los argumentos fácticos.

3.6.4 Diferencias entre los tres principios

Principio	Qué controla
Jurisdicción rogada	Qué puede estudiar el juez (lo pedido y los cargos planteados)
Congruencia	La correspondencia entre lo pedido, lo debatido y lo decidido
Iura novit curia	La libertad del juez para escoger el derecho aplicable, sin cambiar los hechos

3.6.5 Oposición y excepciones

DEFINICIÓN. Oposición: es la defensa general del demandado frente a la demanda. Puede consistir en negar los hechos, controvertir las pruebas, discutir la interpretación jurídica o rechazar las pretensiones.

Tipos de oposición:

- **Fáctica:** se niegan o discuten los hechos.
- **Probatoria:** se controvierten las pruebas.
- **Jurídica:** se discute la consecuencia legal que pretende el demandante.

DEFINICIÓN. Excepciones: son defensas jurídicas concretas, dentro de la oposición, dirigidas a impedir, modificar o extinguir la pretensión del demandante.

Tipos de excepciones:

- **Previas:** cuestionan aspectos procesales, como la competencia, la indebida representación o la ineptitud de la demanda.
- **De mérito o de fondo:** atacan directamente el derecho reclamado; proponen un hecho nuevo que busca destruir la demanda. Ejemplos: prescripción, pago, inexistencia de la obligación, culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero o fuerza mayor.

COMENTARIO. En resumen: la oposición es el género; la excepción es una especie de defensa dentro de la oposición.

COMENTARIO. En materia de error judicial, el juez tampoco puede cambiar la imputación fáctica: si el demandante afirma que la fuente del daño es una providencia judicial, el caso debe estudiarse como error judicial; el juez no puede modificar los hechos ni «mover de título» el caso a partir de hechos distintos. Sobre el ejemplo de los antibióticos y el conocimiento privado del juez, ver Capítulo 5 (responsabilidad médica).

3.7 Función de la responsabilidad extracontractual del Estado

Fundamento	Función
Falla del servicio	Función demarcatoria
Daño antijurídico	Función indemnizatoria

3.8 Caso integrador: vehículo oficial y actividad peligrosa (el alcalde de Pinchote)

EJEMPLO. Hechos. El alcalde del municipio de Pinchote conduce un vehículo de propiedad del municipio, en desarrollo de una actividad misional. Sufrir un infarto, pierde el control del vehículo y ocasiona un accidente en el que mueren tres peatones.

- **Título de imputación:** en principio puede existir responsabilidad patrimonial del municipio bajo el título de riesgo excepcional, porque la conducción de vehículos es una actividad peligrosa, el vehículo pertenece al municipio y existe nexo con una actividad misional.
- **Exoneración:** el infarto no exonera automáticamente; debe analizarse si constituye una causa extraña con aptitud para romper la imputación.
- **Acción:** medio de control de reparación directa (art. 140 del CPACA). Los familiares o personas legitimadas demandan al municipio de Pinchote y solicitan la reparación de los perjuicios derivados del daño antijurídico.

COMENTARIO. Ejemplo análogo a propósito del requisito de exterioridad de la causa extraña: si mientras conduzco me da un paro cardíaco y atropello a un peatón, no me exonero, porque la salud del conductor no es externa al ámbito del deudor; en últimas, se responde por el riesgo (ver Capítulo 5, sección 5.8.3).

Capítulo 4

Primer elemento constante de la responsabilidad: el daño y el perjuicio

4.1 Los elementos constantes de la responsabilidad

Los elementos constantes de la responsabilidad son dos: el daño y el nexo causal. Se llaman «constantes» porque están presentes tanto en el régimen subjetivo como en el objetivo: siempre, sin excepción, se requiere acreditar el daño para que haya responsabilidad, y siempre se requiere acreditar el nexo causal.

4.2 Daño y perjuicio

4.2.1 Definiciones

DEFINICIÓN. **Daño:** es el hecho lesivo; la lesión a un bien jurídicamente amparado o protegido por el ordenamiento.

DEFINICIÓN. **Perjuicio:** son las consecuencias materiales o inmateriales que el daño ocasiona al demandante. Estas consecuencias pueden ser de carácter patrimonial (material) o de carácter inmaterial.

EJEMPLO. En un accidente de tránsito, el daño es el choque al vehículo (el hecho lesivo); el perjuicio es lo que cuesta volver a dejar las cosas en su estado inicial (la consecuencia del hecho lesivo).

4.2.2 Utilidad práctica de la distinción

La distinción entre daño y perjuicio no es solo doctrinaria: tiene implicaciones prácticas. Las principales son dos:

- El estudio de la caducidad del medio de control.
- La legitimación para demandar: la distinción entre víctimas directas e indirectas del daño.

4.3 Primera utilidad: la caducidad

4.3.1 La regla general

La caducidad se cuenta a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho (del daño), no desde que se consolidan los perjuicios. Hay situaciones en las que el daño y los perjuicios se consolidan en momentos distintos, pero esto de ninguna forma permite extender en el tiempo ni prolongar el término de caducidad: el término siempre se cuenta desde el día siguiente de la ocurrencia del daño. El hecho de que los perjuicios continúen en el tiempo no prorroga la caducidad.

COMENTARIO. La regla de caducidad de la reparación directa es: dos años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o desde cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia (ver Capítulo 8).

4.3.2 La regla del conocimiento del daño

Hay casos particulares en los que la víctima no tiene conocimiento inmediato del daño o de su atribución al Estado. Por eso la norma prevé que, en situaciones excepcionales, el término se cuente desde que la víctima conoció o debió haber tenido conocimiento del daño.

Filosofía de la regla. La norma se pone en el papel del demandante: sin conocer el daño, o sin conocer que el daño se le debe atribuir al Estado, es imposible que presente la demanda. Esta regla es especialmente válida en materia médica, donde muchas veces la víctima no conoce inmediatamente el daño.

EJEMPLO. Transfusión de sangre: una persona es contagiada de VIH en una transfusión. El día de la transfusión no sabe que ha sido contagiada; puede tener ese conocimiento meses o un año después. Lo mismo ocurre con el cáncer: la persona no lo sabe desde el mismo día en que ocurre el hecho dañoso.

Carga de invocarla desde la demanda. La regla del conocimiento debe plantearse con claridad desde la demanda. Lo que sucede hoy en día es que se presenta la demanda, se declara la caducidad y solo en el recurso el demandante invoca la regla del conocimiento. «Esa no es la forma.» La regla del conocimiento no es para salvarle el proceso a quien no la invocó: es para decir con claridad, desde la demanda, «conocí el daño en esta fecha, por esta razón».

4.3.3 Casos prácticos de caducidad

Primer caso: fechas de reingreso (desplazamiento) El primer caso involucra fechas de reingreso. Existe la tesis según la cual, en el desplazamiento, el daño es continuado: persiste en el tiempo y el término se cuenta cuando cesa, es decir, cuando la persona regresa o se restablece en condiciones similares a las que tenía, lo que permitiría demandar después del regreso. Es la posición mayoritaria, aunque es discutible que el daño se prorrogue en el tiempo (ver más adelante el debate sobre el desplazamiento forzado).

Segundo caso: el «falso positivo» En el segundo caso, los familiares recibieron una llamada en la que se les informaba de la muerte de la víctima, presentada oficialmente

como baja en combate. Podría pensarse en aplicar la regla de la desaparición forzada (el término corre desde que aparece la víctima o desde la sentencia penal). Esa regla no es aplicable, por las siguientes razones:

- La regla especial es para la desaparición forzada: en ella los demandantes están en la incertidumbre, y por eso se espera a que aparezca la persona o a que haya una sentencia. Aplicarla a un caso de homicidio es extender una regla excepcional a otro supuesto de hecho.
- En este caso, el daño es el homicidio y no la desaparición forzada; a los familiares se les comunicó la muerte.
- Los demandantes denunciaron penalmente a los soldados. Si tuvieron conocimiento suficiente para acudir al proceso penal, también lo tenían para presentar la demanda de reparación directa en ese mismo momento. «Es extraño decir: para el penal sí tenía conocimiento en esa época, pero para la reparación directa, diez años después.» Hay una contradicción en esa argumentación.
- No es cierto que haya que esperar al incidente de reparación en el proceso penal: quien inicia el proceso penal y espera, corre el riesgo de que opere la prescripción de la acción penal; por eso se inician simultáneamente ambos.

Hay quienes defienden otra lectura: que la sentencia sobre flexibilización probatoria en estos casos permitía contar el término desde la sentencia, que la Corte Constitucional ha dicho que la desaparición forzada solo cesa cuando aparece la persona, que en el caso no aparecieron los restos y que, si los familiares acudieran a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, allí lo seguirían buscando (por lo que la desaparición seguiría siendo permanente), y que una denuncia penal (cuyo deber de investigar recae en la Fiscalía) no equivale a tener los mínimos para demostrar el daño y el nexo causal en una demanda de reparación directa. Ninguna de las posturas es descabellada, y es probable que, por las reglas de flexibilización en materia de derechos humanos, un juez concluya que la plena certeza se tuvo con la sentencia; pero esa conclusión es muy controvertible: no tiene sentido que se pueda activar al juez penal y no al juez contencioso.

COMENTARIO. Crítica: hay una tendencia a flexibilizar reglas en casos de graves violaciones de derechos humanos en la que «se les olvida el derecho procesal». Las defensas procesales en materia de derechos humanos «están de moda», pero no pueden llevar a olvidarse del derecho procesal.

Tercer caso: la captura En el tercer caso se discutió desde cuándo se cuenta la caducidad cuando hay una captura: si desde la declaratoria de ilegalidad de la captura o desde que la persona queda en libertad. El problema es de antijuridicidad del daño: ¿en qué momento el daño es antijurídico?

- Una postura sostuvo que el daño es antijurídico desde que se declara la ilegalidad de la captura, porque se vulneraron los derechos de la persona, independientemente de que después se le declare penalmente responsable.
- Sin embargo, la detención en sí misma no es necesariamente antijurídica, por más ilegal que haya sido la captura: si la persona termina condenada (por ejemplo, a muchos años de cárcel), el tiempo que estuvo detenida se le descuenta de la pena. Solo cuando se la absuelve o se declara la prescripción de la acción penal se

sabe realmente que tenemos un daño antijurídico, porque la persona nunca debió haber estado privada de la libertad.

- Sobre el momento exacto, se cuenta desde lo último que ocurra entre la ejecutoria de la absolución y la libertad: si a la persona la absuelven y le dan la libertad cuatro o cinco días después, sería un error contar desde la absolución, porque esos días quedarían sin poder reclamarse; el término debe correr desde que la persona tiene derecho real a reclamar la totalidad del daño.

Cuarto caso: la obra de Transmilenio y el predio En el cuarto caso, la obra de Transmilenio afectó un predio. El daño se consolida cuando termina la obra: solo en ese momento se puede determinar qué tipo de daño hubo. Por ejemplo, el contratista puede usar el predio para almacenar ladrillos y material de obra durante un tiempo y luego retirarlo (ocupación temporal), o puede ocurrir que, al terminar la obra, el propietario pierda definitivamente parte de su propiedad (ocupación permanente). A partir de ese momento se cuenta la caducidad, aunque los perjuicios sigan causándose después.

EJEMPLO. ¿Qué ordena el juez si comprueba la ocupación? En la reparación directa se ordena reconocer al propietario el valor del predio. La sentencia condenatoria se vuelve un título: le pagan, por ejemplo, 100 millones de pesos, queda reparado integralmente y con esa sentencia se traslada la propiedad a favor de la entidad (en últimas, el Estado termina comprando el predio). No se ordena destruir la obra, porque sería más gravoso para el interés público. Otra cosa es que, antes o durante el proceso, se soliciten medidas cautelares para suspender la obra.

4.3.4 Caducidad, lesa humanidad y desplazamiento forzado

Durante muchos años el Consejo de Estado sostuvo que, como la acción penal por delitos de lesa humanidad (por ejemplo, la desaparición forzada) no prescribe, tampoco caducaba la reparación directa. Esa tesis se abandonó en la sentencia de unificación de 2019 sobre caducidad y lesa humanidad (sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, expediente 61033): el hecho de que la acción penal sea imprescriptible no quiere decir que no caduque la reparación directa. Lo único que interesa para la caducidad es la existencia de barreras que impidan el acceso a la administración de justicia: si el demandante tiene barreras que le impiden acudir al juez administrativo, eso permite extender el término.

EJEMPLO. Barreras: amenazas, estar secuestrado, estar en el exilio (asilo); cualquier situación que impida a la persona acudir al juez.

El debate actual sobre el desplazamiento forzado. Estas discusiones volvieron a surgir porque había consejeros que contaban la caducidad desde que ocurre el desplazamiento y otros que no. Se presentaron varias tutelas y la Corte Constitucional realizó una audiencia cuyas preguntas parecen orientadas a volver a la teoría anterior.

COMENTARIO. Crítica: volver a esa teoría sería grave, porque podría revivir hoy demandas por desplazamientos de los años 70 en las bananeras; el daño no se prorroga en el tiempo. Además, saber cuándo la persona volvió a tener el mismo estatus social o el mismo ingreso que tenía antes del desplazamiento es «absurdamente» difícil de sostener, y la caducidad tiene que ser clara para que haya seguridad jurídica. La jurisprudencia está generando así dos problemas: (i) la inaplicación del derecho procesal y (ii) la confusión entre el concepto de daño y la violación de derechos

(«hubo un daño porque se violó el derecho a la dignidad, hubo otro porque se violó el derecho a la vida...»). No se puede decir que hay distintos daños por cada derecho; se está aplicando mucho lenguaje constitucional y de derechos fundamentales a una disciplina que no necesariamente es para eso. Una cosa es proteger a la víctima y otra es el régimen de responsabilidad.

Temporalidad: ocupación temporal y permanente. El mismo problema se presenta con la ocupación: solo al finalizar la obra se sabe si el daño es temporal o permanente. En el desplazamiento ocurre algo parecido con los perjuicios: no es lo mismo desplazarse por dos semanas (se pierde un poco del cultivo) que por tres o seis meses.

4.4 Segunda utilidad: víctimas directas e indirectas

La distinción entre daño y perjuicio permite diferenciar, dentro del proceso de reparación directa, entre:

DEFINICIÓN. **Víctima directa:** la persona que padece el daño y padece los perjuicios.

DEFINICIÓN. **Víctimas indirectas:** quienes no padecen el daño, pero sí sufren perjuicios.

EJEMPLO. En un caso de privación de la libertad, el privado de la libertad es la víctima directa; sus familiares son víctimas indirectas. La distinción tiene repercusiones prácticas en la cuantificación de los perjuicios.

4.5 Características (requisitos) del perjuicio indemnizable

Para que un perjuicio pueda ser indemnizado en un proceso judicial debe cumplir cuatro requisitos:

- Ser **cierto**.
- Ser **personal**.
- Ser **lícito**.
- Ser **subsistente** (debe subsistir al momento de la sentencia).

4.5.1 El perjuicio cierto

DEFINICIÓN. **Perjuicio cierto:** es aquel que no es meramente eventual o hipotético.

EJEMPLO. Freddy, el futbolista. Freddy sale de la universidad y tiene un accidente de tránsito (el demandado puede ser un particular o el Estado). Tiene una incapacidad médica de 30 días que no le permite trabajar. Como es contratista, su lucro cesante cierto es el monto de los honorarios de su contrato de prestación de servicios, calculado por el término de la incapacidad. En cambio, Freddy no podría reclamar que, como todos los domingos es «el Messi del barrio», de no haber ocurrido el accidente estaría jugando en el Real Madrid ganando lo que gana Mbappé: ese perjuicio es meramente eventual, hipotético; existe en la mente de Freddy, pero no tiene ninguna base real de certeza.

a) **Certeza no es lo mismo que actualidad.** Que el perjuicio sea cierto no significa que deba estar consolidado al presentar la demanda. Es procedente reclamar perjuicios

futuros que son ciertos pero que aún no se han consolidado. El perjuicio puede ser pasado, presente o futuro.

EJEMPLO. Prótesis. Un soldado entra a un campo minado que no está debidamente señalizado, pisa una mina y pierde una pierna; debe usar una prótesis. Las prótesis tienen una vida útil: supongamos que deben cambiarse cada cinco años. Si el soldado tiene una expectativa de vida de 45 años, se calcula cuántas prótesis tendrá que comprar y ese gasto, que todavía no se ha hecho, se puede reclamar porque hay certeza de que se va a realizar. El reto es cómo calcularlo (por ejemplo, con el precio actual de la prótesis): lo ya pagado se indexa al momento de la sentencia; lo futuro no puede indexarse, pero sí se puede obtener su valor.

EJEMPLO. Junta médico laboral. Un soldado sufre un accidente y está en proceso de calificación de invalidez, pero aún no es claro el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. ¿Es un problema de daño o de perjuicio? La jurisprudencia ha concluido que la Junta Médico Laboral cuantifica el perjuicio, pero no el daño. En el caso del soldado que pisa la mina, el daño (la lesión a su integridad corporal) se consolidó cuando pisó la mina y perdió la pierna. Por eso debe demandar dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del daño; el dictamen de la Junta podrá aportarse como prueba sobreviniente si se expide durante el proceso (explicando que no podía aportarse con la demanda porque no existía). Ni siquiera es necesario ese dictamen para ganar: se puede pedir un dictamen pericial en el proceso para cuantificar el perjuicio.

EJEMPLO. Menores de edad y cirugías futuras. Los menores lesionados a veces no pueden ser operados de inmediato y se sabe que serán sometidos a una cirugía dentro de cinco u ocho años. En estos casos se recomienda formular las pretensiones previendo que la cuantía se ajustará a lo que se demuestre en el proceso y la posibilidad de aportar dictámenes que se produzcan durante el trámite.

b) La certeza recae sobre el perjuicio, no sobre su cuantía. Tanto en lo contencioso administrativo como en lo civil, los códigos prevén que cuando se demuestra el daño pero no la cuantía del perjuicio, el juez dicta una sentencia condenatoria en abstracto, que fija unas bases para que luego el demandante promueva un incidente de liquidación de perjuicios (un pequeño proceso dentro del mismo proceso), en el que solo se discute la cuantificación.

EJEMPLO. El vehículo embargado. En un proceso ejecutivo embargan y secuestran el vehículo del demandado. Cuando se paga la deuda y se lo devuelven, el vehículo está desvalijado porque no se ejerció su custodia. El dueño demanda, prueba el daño (tenía un buen vehículo y se lo devolvieron destruido), pero no prueba cuánto valía el motor, el radio o la pintura robados. El juez puede condenar porque está demostrado el daño, pero debe hacerlo en abstracto: la sentencia dirá, por ejemplo, que el daño emergente se liquidará en un incidente teniendo en cuenta que el vehículo era de tal marca, el motor de tal marca, la pintura de tal color, etc.

c) Certeza del nexo entre el daño y el perjuicio. La certeza también se predica de la relación que debe existir entre el daño alegado en la demanda y el perjuicio reclamado en las pretensiones. Muchas demandas no demuestran esa relación, lo que lleva al juez a desestimar esos perjuicios.

EJEMPLO. Privación injusta de la libertad. A Pedro lo privan de la libertad y luego lo absuelven porque se demostró que el delito lo cometió otra persona. Son perjuicios

ciertos: lo que dejó de trabajar, lo que pagó al abogado de la defensa y los gastos de transporte de la familia para visitarlo (si no hubiera estado privado de la libertad, la familia no habría tenido que hacer esos gastos). En cambio, el gasto en útiles de limpieza personal que usó en el centro de reclusión, aunque sea un gasto que efectivamente se causó, no tiene relación de certeza con la privación: no se deriva realmente del hecho dañoso (no es que la persona haya empezado a asearse por estar privada de la libertad).

4.5.2 Un punto intermedio: la pérdida de oportunidad

Entre los perjuicios ciertos y los meramente eventuales o hipotéticos se ubica la pérdida de oportunidad. Es un problema complejo, porque ni en Colombia ni en el derecho comparado hay acuerdo sobre si se trata de un problema del perjuicio o del nexo causal: algunos la tratan como problema del perjuicio, otros como problema del nexo causal, y hay países que la usan para ambas cosas. En Colombia hay jurisprudencia en los dos sentidos. Los franceses la utilizan para el nexo causal.

a) Enfoque desde el perjuicio. El primer caso que utilizó la figura en el ámbito de los perjuicios fue un caso del *common law*, de principios de 1900:

EJEMPLO. El concurso de belleza. Una empresa organiza un concurso de belleza; se inscriben 100 personas y el organizador escoge cinco finalistas, a quienes envía por correo físico la notificación para presentarse a la gran final en determinada fecha y ciudad. El premio es de 100.000 dólares. A cuatro finalistas la notificación les llega una semana antes; a la quinta le llega el día siguiente a la final, por lo que nunca pudo concursar. La quinta finalista demanda por pérdida de oportunidad y por primera vez se reconoce ese perjuicio. No se sabe si ella iba a ganar, pero sí que tenía una oportunidad cierta y seria de hacerlo: estaba entre las cinco finalistas, no en el puesto 99.

Requisitos de la pérdida de oportunidad:

- Una oportunidad cierta de obtener un beneficio (probabilidad de obtener un provecho).
- Una oportunidad seria.
- Que esa oportunidad se frustre como consecuencia del hecho dañoso.
- Que la frustración sea definitiva: el provecho no puede obtenerse de ninguna otra forma.

Tasación. Lo que sigue es la discusión de cómo se tasa: ¿hay que darle a la quinta finalista los 100.000 dólares o una parte? Es un tema de arbitrio judicial y de equidad. Una forma de hacerlo es dividir el premio entre cinco: la oportunidad perdida valía una quinta parte, 20.000 dólares. La consecuencia de este enfoque es una tasación porcentual del perjuicio.

b) Enfoque desde el nexo causal (materia médica).

EJEMPLO. A una persona le disparan tres veces (en la pierna, en el pulmón y en la mano). Llega al hospital y no la atienden de inmediato, sino dos horas después, y muere. ¿Hasta qué punto la demora contribuyó a la muerte o disminuyó la probabilidad de recuperación? Nunca se podrá determinar: quizás iba a morir de cualquier manera porque venía con lesiones muy graves. Aquí se ha usado la pérdida de oportu-

tunidad para preguntarse hasta qué punto la falla del servicio médico contribuyó a impedir que la persona sobreviviera.

COMENTARIO. Valoración: el enfoque más adecuado es el del perjuicio. En materia causal no parece adecuado hablar de pérdida de oportunidad: realmente es un tema de prueba indiciaria y de estándares probatorios (por ejemplo, discutir si en materia médica el estándar de causalidad debe ser de probabilidad preponderante y no absoluta). Con todo, es un tema con discusiones muy amplias; el riesgo de la figura es la confusión entre daño y causalidad.

4.5.3 El perjuicio personal

El carácter personal se relaciona con el tipo de obligación que nace de la responsabilidad extracontractual: obligaciones de carácter personal y no de carácter real. Esto significa que el único que puede reclamar un perjuicio es quien lo padeció.

- Quien reclama es quien sufre, no el daño, sino el perjuicio. Por ejemplo, el hijo puede reclamar perjuicios morales por la muerte de su padre porque es él quien padece el fallecimiento de su ser querido.
- Por eso hay que distinguir con toda claridad en qué condición actúa cada demandante: puede reclamar perjuicios propios (*iure proprio*) o perjuicios en calidad de heredero (*iure hereditario*). Ambas reclamaciones son procesalmente válidas, pero deben explicarse desde la demanda: hay que alegar y acreditar la calidad de heredero, además de probar el perjuicio.

EJEMPLO. Pedro privado de la libertad. Pedro es privado de la libertad, es absuelto y tiene dos años para demandar.

- **Escenario 1 – Pedro está vivo.** Demandan Pedro y sus familiares (A, B y C). Pedro reclama sus perjuicios personales (lucro cesante, perjuicios morales) y sus familiares reclaman sus propios perjuicios por la privación de su pariente. Todos actúan por derecho propio.
- **Escenario 2 – Pedro muere antes de la demanda.** Demandan solo A, B y C. Reclaman sus perjuicios morales propios, pero además los hijos pueden actuar como herederos de Pedro y reclamar el lucro cesante que sufrió Pedro, el daño emergente que pagó Pedro e incluso los perjuicios morales de Pedro. Esto hay que especificarlo en la demanda; muchas veces se olvida y en la sentencia solo se reconocen los perjuicios propios.
- **Escenario 3 – Pedro muere durante el proceso.** Es un tema netamente procesal: hay sucesión procesal. Lo que hacen los jueces es decretar la condena por lo reclamado por Pedro a favor de la masa sucesoral, o, si la sucesión ya terminó, a favor de quien corresponda, para que en el marco de la sucesión se adjudique ese crédito.

Daños a las cosas. El Código Civil establece que, cuando se trata de daños a las cosas, está legitimado en la causa por activa el propietario, poseedor o tenedor del bien al momento de la ocurrencia del daño. Debe demostrarse el derecho sobre la cosa, pero el derecho a reclamar no es un derecho real, sino personal.

EJEMPLO. En el proceso ejecutivo de A contra B se embarga y secuestra el vehículo de B, recién salido del concesionario. Cuando se lo devuelven, el vehículo está ab-

solamente destruido. Después B vende el carro a C. ¿Quién puede demandar al Estado? B, porque era el propietario cuando se causó el daño. C no puede demandar al Estado, porque la obligación de responsabilidad extracontractual es personal y no real: por el hecho de vender el carro no se transfiere el derecho a demandar. Lo que hay entre B y C es un problema contractual (C, a lo sumo, podría demandar a B por vicios ocultos).

4.5.4 El perjuicio lícito

DEFINICIÓN. **Perjuicio lícito:** aquel que es consecuencia de una afectación a un bien o interés amparado o protegido por el ordenamiento jurídico.

No confundir licitud con titularidad. La licitud del perjuicio no tiene nada que ver con la titularidad del derecho. En el ejemplo anterior, si C demanda, a veces los tribunales dicen que el perjuicio no es lícito; eso es un error: el perjuicio sí es lícito, el problema es que C no es el titular del derecho, que es un problema del carácter personal del perjuicio.

EJEMPLO. Hipótesis (hechos supuestos, con fines ilustrativos). Un criminal conocido es dado de baja estando ya esposado e inmovilizado, por un policía que actuó por rabia. Su hijo demanda al Estado. Puede reclamar los perjuicios morales por la muerte de su padre y el daño emergente por los gastos funerarios. Pero no puede reclamar, como lucro cesante, las utilidades que su padre dejó de recibir por el tráfico de cocaína: es un perjuicio absolutamente ilícito, porque la venta de cocaína no está permitida.

EJEMPLO. El caso de alias «Bonais» (caso real). La policía persigue a un hombre conocido con ese alias, al parecer armado, y lo mata. La familia reclama y se condena al Estado (no lo podían ejecutar). Uno de los puntos de mayor discusión en la Sala fue si había que reconocer lucro cesante, porque nunca quedó claro si era microtraficante o vendedor informal: había pruebas de que vendía de manera informal y no se demostró lo contrario. Se aplicó entonces la presunción de actividad económica: como se demostró que tenía una actividad, pero no su valor, se liquidó con el salario mínimo (ver reglas de la renta, sección 4.8).

4.5.5 El perjuicio subsistente

DEFINICIÓN. **Perjuicio subsistente:** el perjuicio debe seguir existiendo al momento del fallo; es decir, que no haya sido reparado con antelación y plenamente.

La lógica es clara: si cuando se va a dictar sentencia la víctima ya obtuvo la indemnización del perjuicio, el juez no puede volver a darle una indemnización.

EJEMPLO. En un accidente de tránsito, la víctima demanda al conductor y durante el proceso la aseguradora le paga. El juez no puede condenar por la totalidad de lo reclamado, porque parte ya fue pagada: el perjuicio no es subsistente, o lo es solo parcialmente (lo que no cubrió la aseguradora).

La *compensatio lucri cum damno*. Un autor italiano, De Cupis, escribió un libro sobre el daño en el que planteó un problema relacionado con la subsistencia del perjuicio: el principio de la *compensatio lucri cum damno*, definido como «la reducción del monto del daño resarcible por la concurrencia del lucro». Significa que a partir del daño el

demandante no puede obtener lucro o beneficio: si la aseguradora ya pagó, reconocer la totalidad le generaría un enriquecimiento sin causa real.

El origen del problema es la coexistencia de la reparación judicial del daño con su compensación por otro mecanismo no judicial distinto al directamente responsable (seguridad social, solidaridad, reparación administrativa): la responsabilidad no busca lucrar a la víctima. Las preguntas que plantea son:

- ¿Es posible el cúmulo de indemnizaciones?
- ¿Debe descontarse lo recibido en virtud del mecanismo no judicial de la reparación integral ordenada en sede judicial?
- ¿El tercero que realiza el pago de la compensación no judicial puede repetir contra el responsable (acción subrogatoria)?

Argumentos que se confrontan:

Argumentos para permitir la acumulación	Argumentos para descontar
Tienen una causa distinta (indemnización generada por responsabilidad patrimonial / seguridad social reglada por normas del derecho laboral)	Mismo hecho generador del daño
La compensación no judicial no se calcula con base en el daño, ni lo disminuye	Evitar una doble indemnización
Al tener fuente distinta, no se genera un enriquecimiento sin causa	Pueden coexistir porque la compensación no judicial es tarifada y la reparación judicial es integral, pero se deben aplicar los descuentos

Dos casos para analizar:

EJEMPLO. Caso 1 – El soldado y la pensión de sobrevivientes. El soldado pisa una mina en un campo no señalizado y muere. Su familia demanda al Ejército y reclama daño emergente, lucro cesante (los salarios por su expectativa de vida) y perjuicios morales. Paralelamente, a la cónyuge (también demandante) le reconocen una pensión de sobrevivientes. ¿Debe descontarse la pensión del lucro cesante?

EJEMPLO. Caso 2 – El maestro y la ARL. A un maestro de una escuela pública se le cae encima el tablero mientras dicta clase, porque la escuela no hizo el mantenimiento adecuado; sufre un accidente de trabajo. Durante la reparación directa, la ARL le reconoce una suma (por ejemplo, 10 salarios) por el accidente. ¿Debe descontarse de la indemnización?

Una primera respuesta es que no debe descontarse en ninguno de los dos casos (son causas y fuentes de obligación distintas; en el caso de la ARL se asegura un riesgo de manera objetiva). En contra, puede sostenerse que en el primer caso lo que se cubre es exactamente lo mismo.

COMENTARIO. Argumento a favor del descuento: el hecho dañoso es el mismo; con la pensión se está reconociendo, por vía del derecho laboral, parte del sueldo que recibía el soldado, y en el proceso también se reclama ese sueldo; por más que tengan naturaleza jurídica distinta, resulta redundante.

La sentencia de unificación 66841 (pensión de invalidez y de sobrevivientes de miembros de la fuerza pública). Esta sentencia de unificación resolvió que no hay que descontar. Sus criterios son:

Criterio	Lucro cesante	Pensión
Causa	Falla del servicio	Riesgos laborales inherentes a la prestación del servicio
Fuente jurídica	Art. 90 de la C.P.	Sistema de seguridad social (solidaridad)
Naturaleza del pago	Indemnizatorio	Contraprestación social (laboral) no indemnizatoria
Extinción de la obligación indemnizatoria	Sí	No

- **Subrogación:** no existe subrogación legal a favor de quien otorga la pensión. Se distinguen estos casos de aquellos en los que el Estado efectúa cotizaciones al sistema de seguridad social para trasladar los riesgos profesionales a una entidad diferente que los asegura (ISS, CAJANAL, ARP o ARL).
- **Conclusión:** la acumulación no genera enriquecimiento sin causa de la víctima.

COMENTARIO. Crítica a la sentencia: el criterio de la «extinción de la obligación» no es convincente, porque es precisamente lo que había que discutir (si pagar la pensión extingue o no la obligación); más que un criterio, es la conclusión. Además, la unificación solo se dio para pensiones de invalidez y de sobrevivientes de la fuerza pública.

El criterio decisivo: la subrogación. Lo realmente importante de la sentencia es la subrogación: si hay subrogación, hay que descontar; si no la hay, no. En el caso de las ARL hay norma especial de subrogación: la ARL puede subrogarse y después demandar al responsable para recuperar lo pagado. Como hay subrogación, el pago sí extingue la obligación y recibir dos veces generaría un enriquecimiento a partir del hecho dañoso. En los casos de ARL todavía no hay unificación, pero con el criterio de esa sentencia ya se puede entender hacia dónde va la jurisprudencia en accidentes de trabajo.

COMENTARIO. Otros argumentos. Que el Ejército tenga sus propias cajas y administradores de pensiones sería otro argumento para descontar, pero la unificación dice lo contrario y debe respetarse. Por otra parte, según la línea de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la indemnización por culpa patronal de un trabajador del sector privado no se descuenta lo que ya pagó la ARL por pérdida de capacidad laboral (por ejemplo, si se condena al empleador a 100 salarios y la ARL ya pagó 20 según la tabla, no se descuentan esos 20).

Lucro cesante por lesiones y la incapacidad. ¿Puede Freddy (contratista con incapacidad de dos meses, pagada al 66 % de su cotización por ser accidente común) reclamar la totalidad de sus honorarios? El Consejo de Estado, en lucro cesante por lesiones corporales, ha reconocido un porcentaje equivalente al de la incapacidad, con dos justificaciones:

- La lesión restringe la autonomía de la persona en cuanto al ejercicio de su profesión. Se citó una sentencia de los años 90 de un torero que recibe una cornada por una falla del servicio, deja de ser torero y tiene que emplearse en otra actividad.

- La segunda razón, más potente: al estar incapacitada, la persona tiene que hacer un doble esfuerzo para hacer lo mismo que hacen los demás; por eso se le reconoce el porcentaje de la incapacidad.

4.6 Tipologías de perjuicios en la jurisdicción de lo contencioso administrativo

Las tipologías de perjuicios de la jurisdicción de lo contencioso administrativo son distintas a las de la jurisdicción ordinaria civil. Aquí se expone la posición del Consejo de Estado, por ser la que corresponde a la responsabilidad del Estado, con algunas diferencias frente a la ordinaria. Recientemente, una sentencia importante de la Corte Suprema de Justicia intentó acercar la jurisdicción ordinaria a la contenciosa y acogió varios criterios de esta, pero siguen siendo disímiles. Ambas coinciden en el daño emergente, el lucro cesante y los perjuicios morales; de ahí en adelante las tipologías son distintas.

DEFINICIÓN. **Perjuicios materiales (patrimoniales):** los que se reflejan directamente en el patrimonio del demandante.

DEFINICIÓN. **Perjuicios inmateriales:** los que van más allá del patrimonio del demandante y afectan aspectos morales, espirituales, etc.

Categoría	Tipología
Patrimoniales o materiales	Daño emergente
Patrimoniales o materiales	Lucro cesante
Inmateriales	Perjuicios morales
Inmateriales	Daño a la salud
Inmateriales	Daños por la vulneración de bienes constitucional y convencionalmente protegidos

4.7 El daño emergente

«Art. 1614. Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento (...)» (Código Civil)

DEFINICIÓN. **Daño emergente:** la disminución del patrimonio; la pérdida patrimonial que sufre el demandante a raíz del hecho dañoso. El patrimonio era uno antes del daño y, al ocurrir el daño, baja.

El daño emergente puede ser:

- **Consolidado (pasado):** cuando se presenta la demanda ya se sufrió la pérdida patrimonial. Debe actualizarse a valor presente.
- **Futuro:** cuando se presenta la demanda aún no se ha sufrido la pérdida (el caso de las prótesis o de la operación del niño).

4.7.1 La actualización (indexación)

La fórmula de actualización no es solo del daño emergente: se aplica siempre para actualizar los perjuicios materiales. Actualizar es indexar, es decir, traer a valor presente, porque el dinero pierde valor con el paso del tiempo. Donde es más evidente y sencillo de ver es en el daño emergente.

$$Va = Vh \times (\acute{I}ndice\ final \div \acute{I}ndice\ inicial)$$

- **Va:** valor actualizado.
- **Vh (valor hist3rico):** el valor del dao al momento de su causaci3n.
- **ndice final:** IPC del mes de la presentaci3n de la demanda (o del mes de la sentencia, si se liquida la condena).
- **ndice inicial:** IPC del mes de la ocurrencia del dao (o de la fecha en que se hizo la erogaci3n de dinero).

D3nde se consulta el IPC? En la pgina del DANE hay un cuadro de Excel con los ndices hist3ricos del IPC (ndice de Precios al Consumidor). Se toma el ndice del mes para el cual se quiere hacer la actualizaci3n y se divide por el ndice vigente a la fecha en que se hizo la erogaci3n; el resultado se multiplica por el valor que se quiere actualizar.

4.7.2 Para qu se calculan los perjuicios? La lnea del tiempo del proceso

La liquidaci3n de perjuicios no es un problema solo del juez: es un problema del juez y de las partes. El abogado (del demandante o del demandado) tiene que verificar que la liquidaci3n est bien hecha, porque quizs deba apelarla («seor juez, usted me dio la mitad de lo que me tenan que dar, porque liquid3 mal»). Para entender esto hay que tener en cuenta la lnea del tiempo de un proceso de responsabilidad extracontractual del Estado:

- Ocurre el hecho daoso.
- Corren dos aos de caducidad (usualmente el demandante se los toma).
- **Primer momento de cuantificaci3n: la demanda.** El art. 162 del CPACA exige como requisito de la demanda la estimaci3n razonable de la cuanta: el demandante tiene que decir a cunto asciende el valor de los perjuicios.
- **Segundo momento de cuantificaci3n: la sentencia.** El juez condena y tasa el perjuicio; las partes deben revisar que la tasaci3n est bien hecha.

Por eso la primera pregunta que hay que hacerse es: para qu estoy calculando los perjuicios? Para presentar la demanda, para verificar la condena o, como juez, para hacer la condena? La respuesta cambia la actualizaci3n, la tasaci3n del perjuicio y las reglas que se aplican.

EJEMPLO. Gastos funerarios. Un soldado de 25 aos muere; deja una c3nyuge de 23 aos y dos hijos de dos aos y de un ao. El da de la muerte la familia paga gastos funerarios por cinco millones de pesos. Esos cinco millones, pagados hace dos aos, no valen cinco millones hoy, por lo que deben actualizarse para que las vctimas no

pierdan dinero y sean realmente reparadas. Si se está en la demanda: IPC vigente al momento de la demanda $\div$ IPC vigente al momento del pago, multiplicado por cinco millones. Si se está en la condena: IPC vigente al momento de la condena $\div$ IPC vigente al momento del pago, multiplicado por cinco millones.

Cada gasto se actualiza por separado. Si hubo varios gastos en fechas distintas (por ejemplo, los gastos funerarios pagados a los tres días y, a raíz de la muerte, consultas de la esposa con el psicólogo), cada uno debe actualizarse según la fecha en que se hizo. No se puede ser perezoso y actualizar todo desde una sola fecha: si no se actualiza cada gasto, el cliente pierde plata.

4.7.3 Consejos prácticos para la actualización

- **El resultado de la división siempre es positivo y mayor que uno.** Si da un número negativo o menor que uno, algo va mal: cinco millones de hace dos años no pueden convertirse en tres millones, porque el dinero no aumenta de valor; pierde valor.
- **El número tiene que ser razonable.** Siempre será «uno y algo chiquitico» (1,1; 1,2; 1,5). Si la división da 7, algo va mal: jamás cinco millones se convierten en 35 millones en dos años. «Si le da un número muy grande, preocúpese, porque o está tumbando al cliente o se está tumbando usted.»
- **El IPC se publica mensualmente.** El DANE tiene la obligación legal de publicar el IPC dentro de la primera semana de cada mes. Si hoy es 2 de octubre de 2026, todavía no está publicado el IPC de octubre (saldrá el 7 de octubre); por lo tanto, como índice final debe usarse el de septiembre, que es el último publicado.
- **Aunque el bien cueste lo mismo, el dinero vale menos.** Si algo que costaba cinco millones hace dos años sigue costando cinco millones hoy, de todos modos hay que actualizar, porque los cinco millones de hace dos años no son los mismos de hoy: con un millón de pesos hace dos años se podía hacer un mercado mucho más completo que el que se puede hacer hoy con la misma suma. El servicio fúnebre puede costar un millón antes y un millón hoy, pero el millón de hace dos años no es el mismo millón de hoy.

4.8 El lucro cesante

«Art. 1614. (...) Entiéndese (...) por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento.» (Código Civil)

4.8.1 Lucro cesante consolidado y futuro

El momento hasta el cual se extiende el lucro cesante consolidado, y desde el cual arranca el futuro, depende del momento procesal en el que se hace la liquidación:

Momento de la liquidación	Lucro cesante consolidado	Lucro cesante futuro
En la demanda	Desde los hechos hasta la presentación de la demanda	Desde la demanda hasta el vencimiento de la expectativa de vida
En la sentencia	Desde los hechos hasta la sentencia	Desde la sentencia hasta el vencimiento de la expectativa de vida

La distinción no es solo académica: el lucro cesante consolidado y el futuro tienen fórmulas distintas, porque los intereses que se aplican en uno y otro son diferentes.

4.8.2 Fórmula del lucro cesante consolidado

$$LCC = Ra \times [(1 + i)^n - 1] \div i$$

- **Ra:** renta mensual actualizada (el ingreso mensual actualizado de la víctima).
- **i:** interés puro o técnico mensual = 0,004867. Parece una variable, pero no lo es: es una constante que siempre es igual, tanto en el lucro cesante consolidado como en el futuro.
- **n:** número de meses que comprende el período a indemnizar. Como en la fórmula n es una potencia, se calcula $(1 + i)$ y se eleva a la n (se necesita calculadora científica).

Por eso, realmente, la fórmula solo tiene dos variables: n y Ra .

¿Cómo se determina n ? En meses. Por regla general, si se esperó todo el término de caducidad para demandar, son dos años: el lucro cesante consolidado será de 24 meses y $n = 24$. Si se liquida en la sentencia y han pasado, por ejemplo, 10 años, $n = 10 \times 12 = 120$. Si fueron 9 años y 5 meses, se redondea hasta obtener el exponente.

¿Por qué la renta debe ser mensual? Porque n está en meses; si no se usa el ingreso mensual, la fórmula no cuadra.

Orden de las operaciones: (1) se calcula $1 + i$; (2) se eleva a la potencia n ; (3) se le resta 1; (4) se divide por i ; (5) el resultado se multiplica por la renta mensual actualizada.

4.8.3 Fórmula del lucro cesante futuro

$$LCF = Ra \times [(1 + i)^n - 1] \div [i \times (1 + i)^n]$$

Tiene las mismas variables: Ra sigue siendo la renta mensual actualizada, $i = 0,004867$ y n sigue siendo el número de meses del período a indemnizar. Lo que cambia es la fórmula y el período que comprende n : desde la demanda (o la sentencia) hasta el vencimiento de la expectativa de vida.

Orden de las operaciones: (1) se calcula $1 + i$ y se eleva a la n ; (2) se le resta 1 (numerador); (3) se calcula de nuevo $(1 + i)^n$ y se multiplica por i (denominador); (4) se divide el numerador por el denominador; (5) el resultado se multiplica por Ra .

EJEMPLO. Supongamos una expectativa de vida de 30 años (dato inventado para el ejemplo). Si se liquida para la demanda: el consolidado es de 24 meses y el futuro de $28 \times 12 = 336$ meses. Si se liquida en una sentencia dictada a los 10 años: el consolidado es de 120 meses y el futuro de $20 \times 12 = 240$ meses.

4.8.4 Reglas jurisprudenciales comunes: la renta (Ra)

1. **Incremento del 25 % por prestaciones sociales.** Primero hay que preguntarse si la persona recibía prestaciones sociales, lo que ocurre cuando tiene contrato de trabajo o es empleado público (no así el contratista por prestación de servicios ni el independiente). Si las recibía, se suma un 25 % a la renta.

EJEMPLO. El soldado ganaba tres millones de pesos mensuales y, como estaba nombrado mediante acto administrativo, recibía prestaciones sociales: $3.000.000 \times 1,25 = 3.750.000$. Si fuera contratista, no se suma el 25 %.

2. **Actualización de la renta.** Por la pérdida de valor del dinero, la renta debe actualizarse a la fecha de la presentación de la demanda o a la fecha de la sentencia, según el momento de la liquidación ($\text{IPC final} \div \text{IPC inicial} \times 3.750.000$).

3. **Piso del salario mínimo.** Si después de actualizarla la renta es inferior al salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV), se liquida con el SMLMV vigente a la fecha de la liquidación, porque se presume que nadie en Colombia devenga menos del salario mínimo.

4. **Presunción del salario mínimo cuando no se prueban los ingresos.** Si se acredita que la víctima ejercía una actividad económica productiva, pero no se prueba el valor de sus ingresos, se liquida con el salario mínimo (fue lo que ocurrió en el caso de alias «Bonais»).

EJEMPLO. El abogado privado injustamente de la libertad. En las profesiones liberales es frecuente que los demandantes se concentren en demostrar que la víctima era un abogado muy bueno, que estaba litigando, pero olviden probar el monto de sus ingresos. Resultado: se liquida con el salario mínimo. ¿Qué debió aportarse? Las declaraciones de renta del año anterior o de los últimos años, para sacar un promedio. Si la víctima era empleada, se aporta la certificación del último empleador sobre el salario o la remuneración que recibía (si la víctima directa murió, la familia debe aportarla).

5. **Amas y amos de casa.** La jurisprudencia de unificación ha reconocido que ser ama o amo de casa equivale a un trabajo: la dedicación al hogar ocupa el mismo tiempo laboral. Se liquida con base en el salario mínimo.

4.8.5 Reglas comunes: las víctimas indirectas

Cuando la víctima directa no muere (por ejemplo, un soldado que gana tres millones y es privado injustamente de la libertad durante seis meses), el lucro cesante se le reconoce a ella, que era quien ejercía la actividad económica. ¿Qué pasa cuando quien ejercía la actividad productiva muere y reclaman sus familiares?

- **Solo pueden reclamar quienes tenían dependencia económica con la víctima directa,** y esa dependencia debe probarse en el proceso.
- **Presunción a favor de los hijos menores de 25 años:** los hijos solo tienen que demostrar que son hijos y que eran menores de 25 años; se presume que dependían económicamente del padre.
- **A la cónyuge no se le presume la dependencia económica:** debe demostrarla (pruebas de que el esposo ayudaba en la casa, de que recibía parte de lo que él ganaba, etc.). Si no la prueba, no puede reclamar lucro cesante.

- **Cualquier persona puede probar dependencia económica**, sea o no familiar: la cónyuge, los padres, los sobrinos e incluso el compadre o el amigo con el que la víctima jugaba billar, si demuestra que mensualmente la víctima le pagaba algunos gastos o lo ayudaba con los pagos de la casa. Es un problema de prueba.

La «bolsa» de dinero y los gastos personales. El lucro cesante es una bolsa de dinero de la que se alimentaban varias personas. La víctima directa tenía gastos personales (se alimentaba, salía a comer) que, habiendo muerto o no, nunca habrían llegado a la familia. Por eso no se liquida con toda la bolsa:

- Si solo hay un demandante (por ejemplo, solo la cónyuge), los gastos personales son el 50 %: se liquida sobre el 50 % restante.
- Si hay más demandantes (cónyuge e hijos), los gastos personales se reducen al 25 %. Tiene lógica: entre más grande la familia, la persona gasta menos en sí misma y destina más dinero a la familia.
- Después de descontar los gastos personales, la renta se divide: 50 % para la cónyuge y 50 % para los hijos (que se reparte entre ellos).

EJEMPLO. Distribución en el caso del soldado (renta de 3.750.000; cónyuge y dos hijos). Se descuenta el 25 % de gastos personales; queda el 75 %. La mitad, 37,5 %, es para la cónyuge (1.406.250); el otro 37,5 % se distribuye entre los dos hijos: 18,75 % para cada uno (703.125).

En el ejemplo no se aplica la actualización de la renta, para simplificar las cifras.

4.8.6 Reglas comunes: el período indemnizable

- **Consolidado:** desde la ocurrencia del daño hasta la presentación de la demanda o hasta la sentencia.
- **Futuro:** desde la presentación de la demanda (o la sentencia) hasta la expectativa probable de vida.
- **Acrecimiento:** liquidación por períodos.

La expectativa de vida. Se usa la tabla de la Superintendencia Financiera (Resolución 0110 del 22 de enero de 2014), con las tasas de mortalidad y expectativa de vida probable que se usan en materia de seguros y también en responsabilidad extracontractual. La tabla indica, por sexo y edad, cuántos años de vida probable le quedan a una persona.

EJEMPLO. En el caso del soldado (hombre de 25 años), la tabla arrojó una expectativa de 52,9 años; para la cónyuge (mujer de 23 años), 60,6 años.

Regla: siempre se toma la menor expectativa de vida. El razonamiento es: si el soldado no hubiera pisado la mina, ¿cuándo habría muerto? Si habría muerto antes que su cónyuge, sus ingresos solo habrían llegado hasta los 52,9 años. Y si el resultado fuera al revés (el soldado con 60 y la cónyuge con 52,9), también se toma 52,9: si el soldado no hubiera muerto, de todos modos la cónyuge habría muerto antes y no se le puede dar algo que nunca habría devengado o aprovechado.

Son presunciones que admiten prueba en contrario. Tanto la regla de los 25 años de los hijos como las tablas de mortalidad son estimaciones:

- Un hijo con algún tipo de discapacidad, si la prueba, puede recibir lucro cesante no hasta los 25 años, sino según su expectativa de vida probable.
- El demandado puede probar, por ejemplo, que el soldado tenía un cáncer muy agresivo y que el médico le había dicho que solo viviría cinco años; en ese caso se reduce el período n .

4.8.7 Ejercicio completo: liquidación con acrecimiento (para la demanda)

EJEMPLO. Datos: soldado de 25 años (expectativa 52,9 años), cónyuge de 23 años (expectativa 60,6 años), hijo 1 de dos años e hijo 2 de un año. Renta: 3.750.000 (con prestaciones). Se liquida para la presentación de la demanda (24 meses después de los hechos).

Período	Meses (n)	Beneficiarios	Distribución de la renta	Ra por beneficiario
Lucro cesante consolidado	24	Cónyuge, hijo 1 e hijo 2	25 % gastos personales; 37,5 % cónyuge; 18,75 % cada hijo	Cónyuge: 1.406.250 / cada hijo: 703.125
Lucro cesante futuro (hasta que el hijo 1 cumple 25 años)	252 (= 276 - 24)	Cónyuge, hijo 1 e hijo 2	Igual a la anterior	Cónyuge: 1.406.250 / cada hijo: 703.125
Lucro cesante futuro (hasta que el hijo 2 cumple 25 años)	12	Cónyuge e hijo 2	25 % gastos personales; 37,5 % cónyuge; 37,5 % hijo 2 (acrecentamiento)	Cónyuge: 1.406.250 / hijo 2: 1.406.250
Lucro cesante futuro (resto de la expectativa de vida)	346,8	Solo la cónyuge	50 % gastos personales; 50 % cónyuge	Cónyuge: 1.875.000

Cálculos:

- Período total: $52,9 \text{ años} \times 12 = 634,8 \text{ meses}$.
- El hijo 1 (dos años) recibe hasta los 25 años: $23 \text{ años} \times 12 = 276 \text{ meses}$. El hijo 2 (un año) recibe 12 meses más.
- Último período: $634,8 - 24 - 252 - 12 = 346,8 \text{ meses}$. Verificación: $346,8 + 12 + 252 + 24 = 634,8$.

Operaciones: en el consolidado se hacen tres liquidaciones (cónyuge, hijo 1 e hijo 2) con $n = 24$. Luego se aplica la fórmula del lucro cesante futuro con $n = 252$ para los tres. En los 12 meses siguientes la bolsa cambia: como hay un hijo menos, «la bolsa vuelve a crecer» y se le puede dar más al otro hijo (esto es el acrecimiento). Finalmente, cuando solo queda la cónyuge, los gastos personales vuelven a ser del 50 % y a la cónyuge le corresponde el otro 50 % (1.875.000), con $n = 346,8$.

COMENTARIO. Como la bolsa de dinero se modifica a medida que avanza el tiempo, para verificar si el juez liquidó bien hay que hacer toda esta serie de cálculos.

4.9 Los perjuicios morales

4.9.1 Antecedentes: la irreparabilidad de los perjuicios morales

Inicialmente, ni la jurisdicción ordinaria ni la contencioso administrativa reconocían perjuicios morales, por dos razones:

- **«Las lágrimas no se monetizan»** (o «las lágrimas no se monedean»). Era una teoría francesa: el dolor no se puede convertir en dinero.
- **La imposibilidad de calcular su valor:** es imposible determinar cuánto sufrió una persona por la pérdida de un ser querido. Se trata de la imposibilidad de ordenar una reparación equivalente, debido a que «el dinero no serviría para reemplazar un bien que no tiene valor pecuniario».

4.9.2 El fallo Villaveces (CSJ, 21 de julio de 1922)

EJEMPLO. Los hechos. El señor Villaveces era viudo y visitaba periódicamente la tumba de su esposa. En una visita descubrió que habían exhumado el cadáver sin su consentimiento. Reclamó perjuicios morales: «¿Cómo así que ustedes retiran la tumba de mi esposa, la exhuman y no me piden ni permiso ni consentimiento?». Por primera vez, la Corte Suprema de Justicia reconoció los perjuicios morales.

La reparación de los perjuicios morales se dedujo de los arts. 2341 y 2356 del C.C.:

«Tanto se puede dañar a un individuo menoscabando su hacienda, como infligiéndole ofensa en su honra o en su dignidad personal o causándole dolor o molestia por obra de malicia o negligencia en el agente.»

«Todo derecho lesionado requiere una reparación.»

«Si en muchos casos es difícil determinar el quantum de la reparación, esa circunstancia no puede ser óbice para fijarlo aunque sea aproximadamente.»

DEFINICIÓN. **Perjuicios morales:** buscan reparar —en estricto sentido, compensar— la zozobra, el dolor y la angustia causados por el hecho dañoso.

Cómo superó la Corte las dos críticas:

- **Compensar no es indemnizar.** Indemnizar es restituir las cosas al estado anterior al hecho dañoso: dejar a la persona en la misma situación en la que estaba, pagándole el valor en dinero de lo que perdió o dejó de ganar. Los perjuicios morales no indemnizan, porque no hay valor económico que reemplace la muerte de un ser querido; lo que hacen es compensar: mitigar, ayudar a una persona en dificultad a salir adelante. Nunca buscan que las cosas vuelvan al estado anterior, sino reducir la aflicción para que la persona pueda superar su estado de zozobra. El dolor, en efecto, no se monetiza, pero una ayuda económica puede ayudar a salir adelante.
- **Fórmulas de equidad.** Es imposible saber a cuánto asciende el dolor, pero pueden usarse fórmulas de equidad y de arbitrio judicial para determinar una compensación económica suficiente.

4.9.3 La analogía con el artículo 95 del Código Penal de 1936

Inicialmente, tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado aplicaron, como tope para tasar los perjuicios morales, el artículo 95 del Código Penal de 1936:

«Cuando no fuere fácil o posible avaluar económicamente el daño moral, ocasionado por el delito, el Juez puede fijar prudencialmente la indemnización que corresponda al ofendido, hasta la suma de dos mil pesos.»

El tope era, entonces, de 2.000 pesos.

4.9.4 El abandono de la analogía en la Corte Suprema (CSJ, 27 de septiembre de 1974)

«Esta limitación sólo tiene cabida en los precisos eventos de regulación del "daño moral ocasionado por el delito"; además, el precepto está dirigido a los jueces penales y no a los de otras jurisdicciones.»

Razones: el código ya había sido derogado (¿cómo seguir aplicando un código derogado?) y era una norma penal que no tenía sentido aplicar a la responsabilidad civil extracontractual.

Los topes jurisprudenciales. Desde 1974 y hasta hace poco, la Corte Suprema fijó, mediante sentencias, sumas sin un criterio objetivo de actualización: hacia 2007 el tope era de alrededor de 14 millones de pesos; luego se reconocieron 44 millones, 75 millones hacia 2018, y se llegó hasta unos 78 millones. Cada cierto tiempo se expedía una sentencia actualizando el tope; era un máximo (podía reconocerse menos) y nunca se actualizaba automáticamente. Excepcionalmente, se llegaron a reconocer 150 millones.

4.9.5 Los gramos oro y el salario mínimo en el Consejo de Estado

- **CE, 9 de febrero de 1978:** abandono de la analogía del art. 95 del Código Penal de 1936, por la desvalorización del monto señalado en la norma y por su aplicación limitada al derecho penal. Se adopta la tasación en gramos oro, con un tope de 1.000 gramos oro (equivalente a los 2.000 pesos). La ventaja era que el gramo oro sube de valor con el tiempo, de modo que la indemnización no pierde valor.
- **CE, Sección Tercera, 6 de septiembre de 2001 (ponencia del doctor Alier Hernández):** se abandonan los gramos oro —una figura «anacrónica», propia «del viejo oeste»— y se pasa al salario mínimo, que se actualiza automáticamente y es más fácil, claro y moderno. El tope de 1.000 gramos oro se reemplazó por un tope de **100 SMLMV**, que es el que principalmente se aplica hoy.

COMENTARIO. La Corte Suprema adopta el salario mínimo. En una sentencia reciente, con ponencia del magistrado Octavio Tejeiro, la Corte Suprema de Justicia se acercó a la posición del Consejo de Estado y estableció como tope de los perjuicios morales 100 salarios mínimos. Es un cambio muy importante porque: (i) no tenía justificación usar sumas fijas que no se actualizaban; y (ii) rompe una lógica «nefasta»: el mismo daño generaba una indemnización distinta según lo causara un particular o una entidad estatal (por ejemplo, si un paciente con dolor abdominal moría en una clínica privada, cada familiar recibía unos 74 millones; si moría en un hospital público, recibía 100 salarios mínimos, mucho más). La equivalencia es más justa y equitativa.

4.9.6 Finalidad de los perjuicios morales

- **Satisfactoria o compensatoria, no reparatoria** (CSJ, 27 de septiembre de 1974 / CE, S3, 20 de abril de 2005): no dejan indemne a la víctima ni devuelven las cosas al estado anterior.
- **No buscan el enriquecimiento de la víctima** (CSJ, 21 de febrero de 2018).
- **No tienen finalidad sancionatoria ni son daños punitivos** (Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez): no buscan castigar al demandado.

COMENTARIO. «No hay muerto malo.» En la responsabilidad extracontractual, cuando muere alguien, no solo aparecen la esposa y los hijos: aparecen tíos, tatarabuelos y primos terceros, todos describiendo a la víctima como el familiar ejemplar; muchas demandas «parecen más herencias». Consejo práctico: una buena puerta de entrada con el juez es ser moderado con los perjuicios. Una demanda con la esposa, los hijos, los hermanos, los padres e incluso los abuelos es completamente razonable; cuando aparecen primos segundos y terceros, el juez intuye que no se busca una reparación. Además, si se pierde el proceso, la condena en costas es proporcional a la cuantía de los perjuicios reclamados.

4.9.7 Las sentencias de unificación de 2014 y 2021

El 28 de agosto de 2014 el Consejo de Estado expidió nueve sentencias de unificación sobre perjuicios inmateriales en tres hechos dañosos —muerte, lesiones personales y privación injusta de la libertad— y unificó dos asuntos: la cuantificación y la prueba de los perjuicios morales. En privación injusta de la libertad, las reglas de 2014 fueron modificadas en 2021 mediante una nueva unificación, porque tenían varios errores que hacían injustas las tasaciones.

Sentencias de unificación de perjuicios morales:

- Muerte: CE, S3, 26251, 28 de agosto de 2014 / CE, S3, 27709, 28 de agosto de 2014.
- Lesiones: CE, S3, 31172, 28 de agosto de 2014.
- Privación injusta de la libertad: CE, S3, 46681, 29 de noviembre de 2021.

4.9.8 Perjuicios morales en casos de muerte (26251 y 27709)

Dependen de la cercanía del demandante con la víctima directa: entre más cercano, mayor el perjuicio; entre más lejano, menor.

Nivel	Relación con la víctima directa	Porcentaje	SMLMV
Nivel 1	Relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales (padres, hijos, cónyuge, compañeros permanentes)	100 %	100

Nivel	Relación con la víctima directa	Porcentaje	SMLMV
Nivel 2	Relación afectiva del 2.º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	50 %	50
Nivel 3	Relación afectiva del 3.º de consanguinidad o civil	35 %	35
Nivel 4	Relación afectiva del 4.º de consanguinidad o civil	25 %	25
Nivel 5	Relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados)	15 %	15

¿Quién puede reclamar? Cualquier persona que acredite haber sufrido por la muerte de la víctima directa; lo que cambia es la cuantía, según la cercanía.

Prueba: en los niveles 1 y 2 los perjuicios morales se presumen a partir de la prueba del parentesco: con los registros civiles se tiene por probado el dolor y no hay que probar nada más. En los demás niveles no opera la presunción: hay que demostrarle al juez la cercanía con la víctima y el dolor que su muerte produjo.

Nota 2 (26251):

«En casos excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos humanos, entre otros, podrá otorgarse una indemnización mayor de la señalada en todos los eventos anteriores, cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral, sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda superar el triple de los montos indemnizatorios antes señalados. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño.»

COMENTARIO. ¿Función sancionatoria encubierta? El tope es de 100 salarios, pero cuando el hecho dañoso proviene de una grave violación de derechos humanos puede triplicarse hasta 300. Esto tiene un componente sancionatorio: la muerte de una persona, independientemente de cómo se cause, debería producir el mismo dolor; si lo que permite incrementar el perjuicio no es la intensidad del dolor sino la gravedad de la conducta del demandado, se está sancionando. No es contrario a la igualdad (se aplica a todos los que estén en esa situación) ni supone excusar las violaciones de derechos humanos, pero sí tiene «un tinte sancionador», en contravía de lo dicho por la Corte Interamericana.

4.9.9 Perjuicios morales en casos de lesiones (31172)

Hay dos variables: (i) el grado de cercanía con la víctima directa (los mismos niveles, con la diferencia de que en el nivel 1 se incluye también la víctima directa, que en las lesiones sigue viva y puede reclamar); y (ii) la gravedad de la lesión, determinada por el porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

Gravedad de la lesión	Nivel 1 (víctima directa y relaciones conyugales y paterno-filiales)	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Igual o superior al 50 %	100	50	35	25	15
Igual o superior al 40 % e inferior al 50 %	80	40	28	20	12
Igual o superior al 30 % e inferior al 40 %	60	30	21	15	9
Igual o superior al 20 % e inferior al 30 %	40	20	14	10	6
Igual o superior al 10 % e inferior al 20 %	20	10	7	5	3
Igual o superior al 1 % e inferior al 10 %	10	5	3,5	2,5	1,5

Valores en SMLMV (Gráfico No. 2 de la sentencia).

Para saber el valor, se ubica qué tan lejano es el demandante de la víctima y cuál fue el porcentaje de pérdida de capacidad, y se busca en la tabla. **Prueba:** la sentencia no fija regla expresa sobre la presunción derivada del parentesco, pero en el caso concreto la aplica para los niveles 1 y 2; opera la misma lógica que en muerte: en los niveles 1 y 2 se presume el dolor con la prueba del parentesco; en los demás, debe probarse.

¿Cómo se prueba el dolor fuera de los niveles 1 y 2? Con el testimonio del psicólogo que atendió a la persona (por ejemplo, para acreditar que el amigo de la víctima asistió a terapia a raíz de su muerte); incluso la prueba testimonial podría ser suficiente. El problema es la cuantía: un amigo, tanto en muerte como en lesiones, está en el nivel de tercero damnificado (15 salarios). La prueba psicológica puede ayudar a justificar un valor más alto cuando había una relación muy cercana.

Relaciones de crianza. En el nivel 1 también se encuentran los hijos y padres de crianza: en responsabilidad extracontractual, las relaciones de crianza son equivalentes a las biológicas.

Autodeclaraciones. ¿Puede un amigo acreditar la amistad con una declaración juramentada? No: las autodeclaraciones no sirven: ir a una notaría y rendir una declaración extrajuicio diciendo «yo era el mejor amigo» es certificar uno mismo lo que quiere probar, y la contraparte debe poder contradecir la prueba. De lo contrario, cualquiera declararía extrajuicio que ganaba 800 millones de pesos mensuales.

El cargo de la víctima no altera los perjuicios morales. Los morales son los mismos si muere el Presidente de la República o un desempleado: el dolor no depende del cargo de la persona, sino de la cercanía con ella. En cambio, en el lucro cesante sí son relevantes los ingresos (la variable Ra depende del cargo).

4.9.10 Perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad (46681, 2021)

- Se presumen los perjuicios morales para la víctima directa.
- A partir de la prueba de la relación o parentesco con la víctima directa, se presumen los perjuicios morales para los cónyuges, compañeros/as permanentes y parientes hasta el primer grado de consanguinidad.
- **Cuantificación para la víctima directa:**
 - Un mes o menos: 5 SMLMV.
 - Si la privación dura más de un mes: $PM = (\text{número de meses} \times 5 \text{ SMLMV}) + (\text{fracción adicional de días} \times 0,166 \text{ SMLMV})$.
 - Tope: 100 SMLMV; excepcionalmente, 300 SMLMV.
 - Descuento en casos de detención domiciliaria: hasta el 50 %.
- **Víctimas indirectas cercanas** (padres, hijos, cónyuges y compañeros permanentes): hasta el 50 % de lo que corresponda a la víctima directa.
- **Otras víctimas indirectas:** hasta el 35 % de lo que corresponda a la víctima directa.

COMENTARIO. Para la tasación en privación injusta deben consultarse la sentencia de unificación de 2021 (perjuicios morales) y la de 2019 (perjuicios materiales). En estas reglas ya no es relevante, para los morales, el ingreso que tenía la persona; eso era antes y cambió.

4.10 El daño a la salud

4.10.1 Antecedentes: del perjuicio fisiológico al daño a la vida de relación

Antes de hablarse de daño a la salud, solo existían los tres perjuicios clásicos: daño emergente, lucro cesante y perjuicios morales.

EJEMPLO. Freddy deja de jugar fútbol. Freddy no puede reclamar lucro cesante por el fútbol porque no es futbolista profesional. Pero si a raíz de un accidente de tránsito deja de jugar fútbol, que era su pasión y su pasatiempo de fin de semana, ¿qué perjuicio sufre? La jurisprudencia dijo que no es en estricto sentido un perjuicio moral (no es dolor ni zozobra), sino la afectación del ejercicio de actividades placenteras de la vida.

- **Perjuicio fisiológico:** derivado de una lesión física o corporal; afecta los placeres de la vida.
- **Daño a la vida de relación:** la jurisprudencia consideró que el concepto de perjuicio fisiológico era demasiado estrecho porque lo ataba a lesiones físicas o

corporales, y no siempre hay una lesión corporal que afecte los placeres de la vida o la relación con el mundo exterior: puede tratarse de afectaciones emocionales que afectan la autoestima. Va más allá de las lesiones físicas o corporales; comprende las actividades cotidianas y las relaciones con otros seres y los actos individuales.

EJEMPLO. La cicatriz. Una persona es atropellada al salir de clase y, tras la operación, queda con una cicatriz. No pierde capacidad laboral, pero la cicatriz afecta su autoestima: le encantaba ir a la playa y asolearse, y ya no puede hacerlo porque siente vergüenza de su cuerpo. Además de los perjuicios morales por el dolor del accidente, puede pedir daño a la vida de relación por la afectación de su relación con el mundo exterior.

4.10.2 El daño a la salud (unificación de 2014)

En 2014 se abandona el daño a la vida de relación y se adopta el concepto actual de daño a la salud (CE, S3, 31170, 28832 y 28804, todas del 28 de agosto de 2014).

DEFINICIÓN. **Daño a la salud:** según las sentencias de unificación, es el perjuicio inmaterial que se ocasiona por lesiones psicofísicas que sufre la víctima directa y que no se encuentran inmersas dentro del perjuicio moral. Solo lo sufre la víctima directa.

Gravedad de la lesión	Víctima directa
Igual o superior al 50 %	100 SMMLV
Igual o superior al 40 % e inferior al 50 %	80 SMMLV
Igual o superior al 30 % e inferior al 40 %	60 SMMLV
Igual o superior al 20 % e inferior al 30 %	40 SMMLV
Igual o superior al 10 % e inferior al 20 %	20 SMMLV
Igual o superior al 1 % e inferior al 10 %	10 SMMLV

- En casos de extrema gravedad y excepcionales se podrá aumentar hasta 400 SMMLV, siempre que esté debidamente motivado.
- En casos de daño a la salud por lesiones temporales, para su tasación debe establecerse un parangón con el monto máximo que se otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter permanente y, a partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (28832).
- No solo procede en casos de incapacidad: hay otras variables, de carácter cualitativo (28804). Si no hubo pérdida de capacidad laboral, el juez debe acudir a factores cualitativos que le permitan tasar el daño a la salud con arbitrio judicial, pero siempre debe tratarse de una lesión psicofísica que produzca algo distinto del daño moral.

COMENTARIO. Crítica: el daño a la salud «es un enredo», porque su definición no es clara ni precisa. Primero, si se trata de una lesión psíquica, ¿qué lesiones psíquicas no quedan dentro de los perjuicios morales? Es un problema conceptual imposible de escindir. Segundo, si es una lesión física, para tasarlo se usa el grado

de incapacidad laboral, lo que lo confunde con el lucro cesante. La sensación es que el daño a la salud es redundante con los perjuicios morales o con el lucro cesante: cuando hay pérdida de capacidad laboral, se indemniza dos veces lo mismo. Al parecer, los jueces contencioso administrativos consideraron insuficientes los topes y se inventaron estas tipologías para dar más dinero («démosle además de 100 salarios por morales, otros 100 por daño a la salud»). Sería más fácil volver a un esquema con solo daño emergente, lucro cesante y perjuicios morales, y decir abiertamente que el perjuicio moral puede ir hasta 300, 400 o 500 salarios cuando se pruebe algo extremo.

EJEMPLO. Privación injusta y estrés postraumático. A una persona privada injustamente de la libertad durante 20 meses o más se le reconocen 100 salarios por perjuicios morales (el tope). Si además aporta un dictamen psiquiátrico que muestra estrés postraumático, se le reconocen otros 100 (o 50, o lo que estime el juez) por daño a la salud. ¿Hasta qué punto ese estrés postraumático o las citas al psiquiatra no son simplemente la prueba de un perjuicio moral muy intenso, pero no de un perjuicio distinto?

COMENTARIO. Precisiones. ¿Ya no se habla de daño a la vida de relación en lo contencioso administrativo? Respuesta: se subsume en los perjuicios morales y en el daño a la salud (principalmente en los morales). Por otra parte, la indemnización objetiva que pagan las ARL por pérdida de capacidad laboral se parece al daño a la salud: hay un puente común entre ambos escenarios.

4.11 Daños por la vulneración de bienes constitucional y convencionalmente protegidos

Sentencia de unificación: CE, S3, 32988, 28 de agosto de 2014.

4.11.1 Origen: el Sistema Interamericano

A principios de los años 2000 muchas víctimas del conflicto armado acudieron al Sistema Interamericano: habían ganado su proceso ante la jurisdicción contenciosa (por ejemplo, por un falso positivo o una desaparición causada por el Estado), pero consideraban que esa indemnización no era suficiente porque no garantizaba sus derechos a la verdad, la justicia y la no repetición. La Corte Interamericana condenó al Estado colombiano, principalmente con condenas de carácter no pecuniario (por ejemplo, construir un monumento en honor a las víctimas para que los hechos no se repitan, o publicar la sentencia y hacer un libro a partir de ella). Ante esto, el Consejo de Estado creó una tercera tipología de perjuicio inmaterial diseñada para esos casos, con el fin de evitar que las víctimas demandaran luego al Estado ante el Sistema Interamericano.

4.11.2 Reglas

- **A solicitud de parte o de oficio:** es la única clase de perjuicio que el juez puede reconocer de oficio, aunque no se haya pedido en la demanda.
- **Se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario:** actos de conmemoración, disculpas públicas, monumentos, difusión y publicación de la sentencia, etc.

- **Indemnización excepcional:** en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sea suficiente, pertinente, oportuna o posible, podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud.
- En caso de ordenarse esa indemnización excepcional, no debe estar comprendida dentro de los perjuicios materiales e inmateriales ya reconocidos.

COMENTARIO. Crítica: el estándar para la medida pecuniaria es muy difícil de argumentar. En un falso positivo en el que ya se triplicaron los morales hasta 300 salarios, se reconoció daño a la salud y lucro cesante, y se ordenó publicar la sentencia en la página del Ejército, que todos los soldados la leyeran y que se hiciera un acto de conmemoración y disculpas, ¿cómo justificar además 100 salarios? Es una carga argumentativa que el juez debe cumplir, pero hay jueces de reparación directa «súper flexibles» que dicen que todo es insuficiente sin justificarlo. La tendencia es que la excepción se está volviendo la regla general: ante cada grave violación de derechos humanos se triplican los morales, se dan medidas no pecuniarias, medidas pecuniarias y, además, daño a la salud. Es una manifestación del «discurso del constitucionalismo» en la responsabilidad.

Capítulo 5

Segundo elemento constante de la responsabilidad: la causalidad

5.1 El problema: causa material y causa jurídica

EJEMPLO. El caso de Pedro. De manera accidental, a un soldado se le dispara un arma mientras vigilaba un batallón del Ejército. El disparo le causa una herida en la pierna a Pedro, quien iba caminando cerca del batallón. A raíz de la herida, Pedro es llevado al hospital más cercano, donde es intervenido quirúrgicamente. A la semana, Pedro empieza a sentir dolores y fiebre. En consecuencia, acude nuevamente al hospital, al servicio de urgencias. Cuando está siendo atendido, Pedro sufre un shock séptico y muere como consecuencia de una infección.

¿Cuál es la causa material de la muerte de Pedro? El shock séptico: una infección. Pero saber eso no permite saber quién es el responsable jurídico del daño ni a quién demandar. La causa podría estar en el disparo, en la atención médica, en una bacteria del hospital o incluso en un hecho de la propia víctima (por ejemplo, que no se hizo las curaciones que le exigió el hospital). Jurídicamente puede haber otras causas relevantes.

Ese es el problema del nexo causal: se necesita una metodología o teoría que permita saber no solo cuál es el origen material del daño, sino cuál es su causa jurídica, es decir, a quién se le puede atribuir jurídicamente.

5.2 La causalidad como elemento constante

- La causalidad es un elemento constante de la responsabilidad extracontractual: está presente en los regímenes subjetivos y en los objetivos.
- No puede haber responsabilidad sin causalidad: siempre hay que demostrar que el daño fue causado por el demandado. También en la responsabilidad contractual siempre hay causalidad.

Responsabilidad y solidaridad. Si no se exige causalidad, ya no estamos en el mundo de la responsabilidad, sino en el de la solidaridad.

EJEMPLO. Juliana pierde el celular y Vanessa le da dinero para ayudarla a superar esa situación. ¿Hay responsabilidad? No: es solidaridad, porque ese pago no lo hace quien causó el daño, sino alguien que actúa por altruismo.

EJEMPLO. El reciente terremoto (Pereira, Cali, Chocó): muchas personas han contribuido a las víctimas e incluso el Estado ha reconocido auxilios a su favor. Eso no es responsabilidad, es solidaridad; y en la solidaridad no hay causalidad.

5.3 Los dos niveles de imputación

Nivel	Contenido
Causalidad material / imputación fáctica o de primer nivel (primer grado)	Busca la causa material del daño, desde el punto de vista de la ciencia, la naturaleza, la física o la biología. Es la causalidad como fenómeno natural o físico (acción / reacción). No tiene alcance jurídico: no es suficiente para condenar al demandado.
Causalidad jurídica / imputación jurídica o de segundo nivel (segundo grado)	Busca la causa jurídicamente relevante para atribuir el daño: la relevancia jurídica de una conducta (acción u omisión) frente al daño.

5.4 Teorías sobre la causalidad

Para la imputación jurídica se han desarrollado distintas escuelas:

- Equivalencia de las condiciones.
- Causa próxima.
- Causalidad adecuada.
- Imputación objetiva (más recientemente).

Estas teorías se originaron en el derecho penal, porque allí existe la misma dificultad de saber a quién se le atribuye jurídicamente la comisión de un delito, especialmente cuando participan muchas personas, algunas sin relevancia jurídica en la causación del daño. Por eso fueron primero los penalistas quienes estudiaron con más detenimiento la causalidad, y luego estas teorías fueron trasladadas a la responsabilidad extracontractual por los civilistas y en lo contencioso administrativo. Un ejemplo claro es la imputación objetiva, creada por penalistas y que ahora se usa en algunos casos de responsabilidad extracontractual.

5.4.1 Equivalencia de las condiciones

- Todo antecedente del daño es una condición del mismo, y todas las condiciones tienen igual peso: «faltando cualquiera de ellas, el daño no se habría producido».
- Se aplica el ejercicio mental hipotético de la *conditio sine qua non* (la condición sin la cual no se habría producido el resultado): se suprime mentalmente un antecedente y se pregunta si el daño se habría producido.
 - Si el daño se produce de todas formas, ese antecedente no es causa.
 - Si el daño desaparece, ese antecedente sí es causa.

Problemas:

- Resuelve un problema de causalidad material y no de causalidad jurídica: no aporta ninguna idea jurídica novedosa (enfoque estrictamente natural).
- Es casi un ejercicio de inventario y permite el regreso al infinito (extensión del nexo *ad infinitum*).

EJEMPLO. En el caso de Pedro: si Pedro no va al hospital, sobrevive; si al soldado no se le dispara el arma, Pedro no muere; si el Estado no compra el arma, Pedro no muere; si el soldado no nace, Pedro no muere; si Pedro no nace, no muere... Uno se puede devolver hasta el infinito sin esclarecer nada.

5.4.2 Causa próxima

Surge como respuesta a la equivalencia de las condiciones: no hay que irse hacia atrás hasta el infinito.

«(...) la causa es el antecedente o factor temporalmente inmediato al resultado (...)»

«(...) los demás hechos que influyen más lejanamente en la producción de ese resultado, son sus "condiciones" pero no su "causa" (...)»

- No se puede remontar a acciones más remotas.
- **Problema:** no siempre la causa más próxima es la jurídicamente relevante o determinante.

EJEMPLO. En el caso de Pedro, la causa más cercana sería la atención de urgencias, lo último que pasó antes de su muerte. Pero no es claro, jurídicamente, que por ser el evento más cercano en el tiempo sea la causa jurídica.

5.4.3 Causalidad adecuada

Es la teoría preponderante hoy en día y la que se usa comúnmente.

- Causa adecuada es la que previsible o probablemente puede causar el daño; se mira el grado de eficiencia en el resultado.

«No todas las causas que intervienen en la producción de un efecto son equivalentes. En consecuencia, solo las que se consideran adecuadas tienen incidencia causal desde el punto de vista jurídico.»

«Sólo pueden estimarse a efectos de una causa aquellos que según las reglas del sentido común y de la experiencia suelen ser su resultado normal.»

- El juez debe estudiar la probabilidad que tiene un hecho en la materialización del daño, ayudándose de la sana crítica, las reglas de la experiencia y el material probatorio: ¿la causa más probable de la muerte fue el disparo en la pierna, la atención médica tardía u otra?
- **Problema:** en estricto sentido tampoco introduce componentes jurídicos: resuelve las discusiones sobre causalidad material, pero no sobre causalidad jurídica (el segundo nivel de imputación).

5.4.4 Crisis de los sistemas anteriores

- La identificación empírica de la causa no es suficiente; el problema es la relevancia jurídica de la causa.
- Se necesitan criterios normativos o jurídicos de atribución en los casos en que intervienen varios sujetos en la causación del daño o varias causas.

EJEMPLO. El caso del talio y las frambuesas (caso real). Un señor, cuya hija estaba en el colegio, invita a otros compañeritos a la casa. Llegan unas frambuesas intoxicadas; varios niños mueren y uno sobrevive. Con el tiempo se descubre que el señor tenía una amante que, al terminar con ella, sabía que a los niños les gustaban esas frambuesas: compró talio (un veneno), lo aplicó y las envió por domicilio. En la cadena de hechos intervienen el vendedor del talio, el domiciliario, quien hizo las frambuesas, los padres que cuidaban a los niños... ¿Quién es penalmente responsable? Es el problema de imputación: ni el vendedor del talio ni el domiciliario tenían idea de nada. Se ha señalado, además, que la mujer habría envenenado también a otras personas (la esposa, que murió y en cuya sangre se encontraron rastros de talio, un cuñado y una amiga); viajó a Argentina y luego a Londres, y, con circular roja de Interpol, terminó lanzándose al Támesis.

También en materia penal se pregunta qué pasa cuando hay varias causas: si a cinco personas les cae mal el mismo sujeto y cada una le pone un poco de talio en el café, ¿todos son responsables?, ¿el que puso más?, ¿el que dio la dosis letal? Para estos casos, la causalidad adecuada no sirve.

5.5 La teoría de la imputación objetiva

Roxin y Jakobs desarrollan la teoría de la imputación objetiva.

COMENTARIO. Advertencia: no confundir la imputación objetiva con la responsabilidad objetiva. La imputación objetiva es una teoría de la causalidad, aplicada primero en el derecho penal y ahora en ciertos ámbitos de la responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad objetiva se refiere a los títulos de imputación que la permiten: por ejemplo, el riesgo excepcional y el daño especial son títulos de imputación en virtud de los cuales se aplica responsabilidad objetiva.

Fundamento:

- Vivir en sociedad implica aceptar una distribución de roles sociales y estándares de conducta, fijados por el ordenamiento jurídico. Esa distribución genera confianza en que cada persona cumplirá el rol que le ha sido asignado.
- La responsabilidad surge de la defraudación de la expectativa que suscitan los roles sociales y los estándares de conducta: de la defraudación del rol esperado.
- Para saber si alguien defraudó su rol se usan criterios jurídicos objetivos, no subjetivos, para evitar la subjetividad del juez.
- La pregunta es: **¿quién quebrantó el rol social esperado (el estándar de conducta esperado)?**

EJEMPLO. Un paciente es operado en una clínica y contrae una infección porque los instrumentos quirúrgicos no fueron esterilizados adecuadamente. ¿Responde el

cirujano? No: el cirujano confiaba en que el instrumentador cumpliría su rol, que era limpiar el bisturí. Haría mal condenar penalmente al cirujano por homicidio culposo; responde el instrumentador. (Distinto es el caso de la bacteria intrahospitalaria, que se estudia con los títulos de imputación.)

5.5.1 Factores normativos de atribución

a) Omisión. No es suficiente determinar quién podía evitar el daño: solo está obligado quien tiene la posición de garante en el contexto determinado.

EJEMPLO. Si a un profesor le da un infarto mientras dicta clase y ninguno de sus estudiantes lo socorre, estos no son penalmente responsables de homicidio, porque ninguno tiene un rol de garante. La situación cambia si uno de ellos (Gabriel) es médico: si se va a comer en lugar de socorrerlo, responde por homicidio culposo por omisión, porque como médico tiene un rol de garantía de socorro.

b) Riesgos permitidos y no permitidos. ¿Quién quebrantó su rol obrando por fuera del riesgo socialmente permitido? Esta teoría presenta problemas de aplicación en los casos de responsabilidad objetiva.

EJEMPLO. Si Freddy le pega una patada a alguien jugando fútbol (una patada normal, una barrida, no una patada «asesina» en la cara), no es penalmente responsable de lesiones: actúa dentro del riesgo permitido. Lo que genera responsabilidad es salirse del riesgo permitido, como pegar una patada a la salida de clase.

c) Principio de confianza. Vivimos en sociedad bajo una división del trabajo y confiamos en que cada persona cumpla su rol social. Responde quien rompe esa confianza (el ejemplo del cirujano y el instrumentador).

d) Prohibición de regreso. Es la interrupción del nexo causal por la intervención dolosa o gravemente culposa de un tercero: cuando en la cadena causal ocurre una conducta dolosa o gravemente culposa, el juzgador no puede irse hacia atrás en el tiempo a buscar responsables anteriores a ese suceso.

EJEMPLO. El vehículo incautado (caso real del Consejo de Estado). En un proceso ejecutivo se embarga el carro de B; se entrega al secuestre, quien lo deposita en el parqueadero ABC. En la noche, una persona que no se sabe quién es se roba el carro y atropella a un ciclista, que iba con licor en la sangre (no borracho, pero sí «licorado»), y huye. ¿A quién demanda la víctima? Demandó al Estado (Rama Judicial) por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque el secuestre es un agente del Estado que tenía a cargo la custodia del vehículo y el Estado falló en esa custodia. El Consejo de Estado condenó, con posible reducción de la indemnización por la concurrencia del ciclista. Hubo salvamento de voto: había una acción dolosa (el robo) y una omisión gravemente culposa; no es posible retrotraerse jurídicamente hasta el Estado, porque entonces el Estado se vuelve garante de absolutamente todo; propuso aplicar la prohibición de regreso, teoría del derecho penal sobre causalidad, en lo contencioso administrativo.

e) Inevitabilidad del riesgo. El daño se produce incluso si se hubiera cumplido el rol esperado.

EJEMPLO. Un crucero se detiene en alta mar para que los pasajeros se bañen. Un pasajero muere ahogado porque el crucero no tenía chalecos salvavidas. En principio hay una omisión (una culpa, en lenguaje civil) jurídicamente atribuible. Pero si el pasajero pesaba 140 kilos y los chalecos solo soportaban hasta 100 kilos, el juicio

cambia: el riesgo era inevitable, con o sin chaleco. Llevado a la responsabilidad estatal, la pregunta es: ¿el daño habría ocurrido de todas maneras, hubiera o no ocurrido la falla del servicio?

f) Acción a propio riesgo (y provocación). ¿La víctima incumplió su rol social? Es lo que en la responsabilidad extracontractual se llama hecho exclusivo de la víctima.

EJEMPLO. Una persona sale de una fiesta y se sube al carro de un amigo sabiendo que va completamente borracho; tienen un accidente. No puede denunciar al amigo por lesiones culposas: fue ella misma quien se sometió al riesgo.

g) Fin de protección de la norma. No basta preguntar si se infringió la norma: hay que preguntarse qué finalidad de protección busca la norma infringida. ¿La norma incumplida que establece el rol o el estándar realmente busca evitar el daño?

EJEMPLO. El bachiller y la vaca (caso real). En unas ferias patronales hay una exposición ganadera; la acompaña un bachiller que presta servicio militar obligatorio. Mientras bajan las reses del camión, una vaca le cae encima y le causa lesiones graves (supongamos una pérdida del 30 % de su capacidad). Demanda a la Policía Nacional con base en una norma según la cual los bachilleres deben estar en todo momento acompañados de un superior jerárquico, y está probado que estaba solo. ¿Se condena? Quien diseñó esa norma no lo hizo para evitar que a los bachilleres les cayeran vacas encima, sino por otras razones (orden público, operaciones). El Consejo de Estado condenó; el salvamento de voto dijo que ese no es el fin de protección de la norma: hay falla del servicio, pero la falla no es la causa del daño.

COMENTARIO. Valoración: es un típico caso donde hay falla del servicio, pero la falla no causó el daño; el hecho de que haya falla no quiere decir que haya causalidad. Debíó absolverse al Estado: la violación de la norma ni evitaba ni causaba el daño; es un problema de exposición de la víctima al peligro (un bachiller mayor de edad tenía la capacidad de saber que no era prudente ponerse debajo del camión). Podría argumentarse que, analizado como omisión, cabría condenar porque el superior es garante del bachiller, pero esa argumentación no convence.

EJEMPLO. Contraste: en las instituciones del ICBF para menores, los educadores deben estar en todo momento al cuidado de los niños. Si un niño pequeño se atraganta con una galleta y muere ahogado porque el cuidador no estaba, esa norma sí está diseñada para evitar ese tipo de daño (socorrer al niño). En cambio, si la educadora se resbala con un juguete y golpea al niño, para eso no está la norma. Además, las lógicas son distintas: un niño de cinco años frente a un policía de 18.

COMENTARIO. El problema de las teorías de la causalidad es interesante, pero no siempre es un problema práctico: los temas de causalidad se resuelven muchas veces como un tema probatorio. Su estudio sirve para comprender su evolución.

5.6 Problemáticas reales en el estudio de la causalidad

Los verdaderos problemas de causalidad en la responsabilidad son principalmente tres: la omisión, la responsabilidad médica y la tendencia a condenar por culpa (o falla del servicio) sin causalidad.

5.6.1 La responsabilidad del Estado por omisión

Cuando se habla de omisión del Estado, usualmente es porque hubo una acción de alguien o de algo que produjo el daño. El primer problema es por qué se le imputa al Estado, por omisión, un daño que un tercero causó por acción (por ejemplo, un acto terrorista imputado al Estado en lugar de al grupo que lo cometió; hay razones que lo justifican en ciertos casos, que se ven en los títulos de imputación).

El fuero de atracción. El problema de fondo nace de una figura procesal (existente en el código anterior y en el actual): cuando el daño fue causado tanto por el Estado como por un particular, se puede demandar a ambos y la jurisdicción contenciosa conoce de la demanda contra los dos. En la práctica, casi siempre se puede involucrar al Estado por omisión, porque el Estado tiene funciones de inspección, vigilancia y control, o es quien autoriza la actividad. Por eso los litigantes siempre buscan «meter» al Estado por la vía de la omisión.

EJEMPLO. El circo de los hermanos Gasca. En un circo muy famoso, el tigre se come a un espectador. En principio se demanda al circo; pero si los dueños del circo están quebrados, el litigante dirá que el Estado responde por omisión porque no ejerció la inspección, vigilancia y control sobre el espectáculo. ¿Qué tan fuerte es esa argumentación? Si el Estado dio el permiso, ¿por qué tendría que responder? Y si no lo dio, la actividad era ilegal y deberían responder los dueños del circo... pero luego se dirá: «¿y usted, Estado, por qué permitió que funcionara?». Siempre hay una forma de involucrar al Estado. ¿Qué tan justo es?

EJEMPLO. La lotería sin fondos (caso real). Un señor se gana la lotería y todo el barrio se entera. La lotería no tenía fondos: la Superintendencia encargada no la vigiló adecuadamente. El señor demandó al Estado por perjuicios económicos y morales; sus testigos declararon que en el barrio le decían «medio millón» y que su nombre quedó afectado. El Consejo de Estado condenó a la Superintendencia a pagar el valor total del premio: la Superintendencia está creada para vigilar que quien vende loterías tenga fondos, y a pesar de que había noticias y hallazgos administrativos de que la lotería no tenía fondos, permitió que siguiera funcionando. La posición del fallo es comprensible, pero genera dudas: ¿hasta qué punto el Estado es garante de una lotería fallida y debe pagar el premio que la lotería quebrada no pagó? (Por los perjuicios morales, «vaya y venga».)

EJEMPLO. Colegios ilegales. A las alcaldías llegan casos de colegios sin licencia de funcionamiento cuyos estudiantes, al llegar a la universidad, no ven acreditada su educación, y los padres quieren demandar al municipio por no ejercer la inspección y vigilancia. Pero con muchos colegios (18 oficiales y 35 privados), ¿cómo enterarse si la ciudadanía no presenta quejas? La falla del servicio por omisión se configura cuando la entidad sabía o debía saber (en este caso, del funcionamiento del colegio ilegal). La pregunta es si ya había quejas sobre ese colegio en particular. Si cualquier persona u otra autoridad ya había denunciado ese colegio ilegal y la entidad permitió que siguiera funcionando, la demanda de un padre que reclama lo que pagó tiene una alta probabilidad de prosperar, porque hay una omisión real. Respondería el Ministerio de Educación, si se trata de una competencia nacional, o la entidad territorial correspondiente; son casos que deben estudiarse con detenimiento.

EJEMPLO. Medidas de protección. Una persona recibe amenazas de un grupo armado y la matan, pero nunca solicitó medidas de protección ni puso las amenazas en

conocimiento del Estado. El Estado no responde: no tenía conocimiento ni debía tenerlo, porque nadie le dijo nada. Distinto es el supuesto de la persona que sí puso las amenazas en conocimiento del Estado. Ver Capítulo 6, sección 6.4.6, sobre la omisión en medidas de protección.

5.6.2 La responsabilidad médica

Son casos difíciles porque son problemas de causalidad que requieren conocimiento técnico.

- **El dictamen pericial.** El medio de prueba para acreditar hechos que requieren conocimientos técnicos, científicos o artísticos es el dictamen pericial; en materia contenciosa, además, se puede solicitar su práctica. Los jueces saben derecho, no medicina, biología, física o ingeniería. Por eso, por regla general, para que haya una sentencia condenatoria en responsabilidad médica tiene que haber un dictamen pericial (aportado o practicado) que permita concluir que hubo culpa o falla del servicio médico. Un proceso de responsabilidad médica sin dictamen, en un 95 %, está perdido.
- **El conocimiento privado del juez.** Un paciente es operado y no le suministran antibióticos; la historia clínica lo demuestra. ¿Basta eso para condenar? No: ¿cómo sabe el juez si se requerían antibióticos? Hay jueces que citan en la sentencia artículos académicos de internet o libros de medicina que leyeron por su cuenta. Ese fallo viola el derecho de defensa y de contradicción: el juez acude a un conocimiento propio que no llegó al proceso por un medio de prueba, y nadie tuvo oportunidad procesal de controvertirlo.
- **El «testigo experto».** El demandante no trae dictamen, pero pide la declaración de un médico experto (por ejemplo, el mayor experto del país en apendicitis) que no atendió al paciente. En Colombia no existe la figura del testigo experto: un testigo solo puede narrar lo que presencié directamente. Por esa vía se intentan «colar» pseudodictámenes, saltándose los requisitos del dictamen (perito idóneo, con determinada especialidad y títulos, metodología científica, bases, etc.). Si se quiere usar el conocimiento de ese médico, hay que pedirle que rinda un dictamen pericial con todas las de la ley.
- **Las conductas procesales como indicios graves.** Como contrapeso, la jurisprudencia ha dado valor a las conductas procesales: si el demandado, que tiene la historia clínica, aporta una historia ilegible o indescifrable, o incompleta (por ejemplo, va del día 1 al día 90, pero falta el día 100, cuando ocurre la muerte), eso es un indicio grave de responsabilidad en su contra.

5.6.3 Condenar por falla del servicio sin estudiar la causalidad

Muchas veces el Consejo de Estado no estudia la causalidad: se limita a estudiar la falla del servicio y, de la prueba de la falla, infiere la causalidad (como en el caso del bachiller y la vaca). Eso no es adecuado: primero hay que demostrar la causalidad y solo después estudiar si hubo o no falla del servicio.

5.7 Causales de ruptura del nexo causal: la causa extraña

El nexo causal se destruye a través de la causa extraña. Sus eventos son:

- **El hecho exclusivo de la víctima.** Se usa a propósito ese lenguaje y no se habla de «culpa» de la víctima: no importa si la víctima obró con culpa, porque no se valora su conducta; lo que interesa es qué incidencia causal tuvo el hecho de la víctima. Y debe ser exclusivo para exonerar al demandado. (Se usan ambas denominaciones: hecho exclusivo de la víctima / culpa exclusiva de la víctima.)
- **El hecho exclusivo de un tercero.** No exonera el hecho parcial del tercero, sino el exclusivo.
- **La fuerza mayor o el caso fortuito.**

5.7.1 Fuerza mayor y caso fortuito: Corte Suprema y Consejo de Estado

Corporación	Tesis	Contenido
Corte Suprema de Justicia	Tesis monista	Caso fortuito y fuerza mayor son sinónimos; el Código Civil no los distingue (art. 64 del C.C.). Lo importante es que cumplan los requisitos para exonerar, en especial que sean externos a la actividad del deudor.
Consejo de Estado	Tesis dualista	Caso fortuito: es interno; ocurre por la conducta de quien ejerce la actividad o proviene de la propia estructura de la actividad riesgosa; no exonera de responsabilidad. Fuerza mayor: es un hecho externo o exterior; es causa extraña y rompe el nexo causal. En estricto sentido, solo la fuerza mayor exonera.

COMENTARIO. En realidad, como dice la expresión popular, «es el mismo indio con otra ruana»: ambas corporaciones dicen lo mismo. Lo que exonera es lo externo; lo interno no exonera. La Corte Suprema exige que sea externo, sin importar cómo se le llame; el Consejo de Estado llama «caso fortuito» a lo interno (que no exonera) y «fuerza mayor» a lo externo (que sí exonera).

5.8 Requisitos de la causa extraña

Para que cualquiera de las causas extrañas exonere de responsabilidad, deben cumplirse requisitos conjuntos:

- Ser **irresistible** (inevitable).

- Ser **imprevisible**.
- Ser **externa** (exterior a la actividad del deudor).
- Cuando se trata del hecho del tercero o del hecho de la víctima, ser **exclusiva**.

5.8.1 La irresistibilidad (inevitabilidad)

La irresistibilidad se predica de los efectos del hecho, no del fenómeno en sí mismo. Y depende del contenido y la relatividad de la obligación.

EJEMPLO. El tsunami. El Estado no puede evitar un tsunami, pero sí sus consecuencias adversas: si hay un terremoto (en Japón, en el Pacífico o en Capurganá), debe emitir alertas tempranas («población costera del Pacífico, hay un tsunami en una hora, evacúen la zona»).

EJEMPLO. El volcán (el Puracé, que estuvo en alerta amarilla). Primer escenario: el Estado declara alerta amarilla y naranja, ordena evacuar y crea refugios; el volcán explota y mueren personas. Hay fuerza mayor: hecho imprevisible, irresistible y externo; el Estado hizo lo que tenía que hacer para evitar los efectos. Segundo escenario: el Estado sabe que el volcán está en alerta, pero no publica las alertas, no evacúa, no informa a la población del riesgo ni genera un plan de contingencia; el volcán explota y mueren varias personas. El Estado responde: el hecho de la naturaleza no reúne los requisitos de la fuerza mayor, porque sus efectos eran resistibles y el Estado no hizo nada para resistirlos.

Aquí entra el carácter relativo de la falla del servicio: hay que preguntarse hasta qué punto el Estado podía prevenir; es una obligación de medio, no de resultado (la misma discusión que se tuvo sobre el desplazamiento forzado en el Alto Baudó, cuando el Estado creó un batallón de montaña e hizo operaciones).

5.8.2 La imprevisibilidad

La imprevisibilidad indica si el hecho dañoso era o no previsible para el demandado, y está estrechamente ligada a la irresistibilidad: si el hecho era previsible, el demandado podía hacer algo y no lo hizo.

- Se refiere a hechos imaginables antes de la ocurrencia del daño.
- Debe analizarse desde una probabilidad real de ocurrencia. (¿Es previsible ganarse la lotería por comprar un billete? Es posible, pero no probable.)
- **La previsibilidad y la resistibilidad se estudian *ex ante* y no *ex post*:** hay que ponerse en los zapatos del Estado en el momento anterior a la ocurrencia del hecho dañoso y preguntarse si en ese instante podía saber o resistir lo que iba a ocurrir.

EJEMPLO. La analogía del fútbol. ¿Cómo se juzga al técnico de la Selección (Néstor Lorenzo) antes del partido contra Paraguay? Con la información que tiene antes del partido. Si pone al mejor delantero del momento (el que está en el mejor club y el mejor nivel) y el jugador falla todas las oportunidades y Colombia pierde, no se le puede reprochar con lo que se supo después del partido. Otra cosa es que lo alinee sabiendo que estuvo de rumba la noche anterior o que está lesionado: eso sí era información disponible antes. Lo mismo ocurre en la responsabilidad

extracontractual: se analiza con la información que tenía la entidad antes del daño, no con la que se conoció después.

EJEMPLO. El atentado contra el Club El Nogal (Bogotá, 7 de febrero). En el expediente había tres pruebas para acreditar que el Estado tenía o debió tener conocimiento:

- **Primera prueba:** un panfleto anual de las FARC anunciando que ese año se dirigirían contra los clubes de la gente rica del país. Es demasiado general y abstracto: puede haber cientos de clubes; no permite inferir que se atentaría contra El Nogal.
- **Segunda prueba:** un documento de un agente del DAS, aportado al proceso penal, fechado el 8 de febrero (el día siguiente al atentado), en el que dice que sabía que iba a ocurrir un atentado. Como los comentaristas de fútbol después de perdido el partido: lo importante es qué sabía el Estado antes del atentado.
- **Tercera prueba (la más importante):** la declaración en el proceso penal de una agente de la Fiscalía o del CTI, quien trabajaba con un informante de las FARC que había dado información confiable en el pasado. Entre noviembre y diciembre de 2000 y enero de 2001, en reuniones con fiscales y autoridades, el informante dijo que las FARC planeaban un atentado grande en Bogotá, que sería contra el Congreso de la República o contra el Banco Agrario, y que un miembro de las FARC con el alias de «Hermínul» estaba consiguiendo dinamita para un carro bomba.

Con esa información, el atentado contra El Nogal no era previsible para el Estado: los objetivos señalados eran otros. Por eso hay que estudiar las cosas *ex ante*: *ex post* se supo que «Hermínul» era el tío del instructor de tenis del club, que fue quien consiguió la dinamita, y que su sobrino puso el carro bomba en El Nogal. Leído después, parecería que el Estado sabía y no hizo nada; pero con la información previa, de ninguna manera era previsible. El Estado fue exonerado.

5.8.3 La exterioridad

El hecho debe ser externo a la actividad del deudor.

EJEMPLO. Los frenos. Voy manejando, el vehículo se queda sin frenos y atropello a un peatón. Alego que llevé el vehículo a revisión técnico-mecánica el día anterior. No me exonera: el mantenimiento del vehículo no es externo a mi actividad como dueño del vehículo.

EJEMPLO. El paro cardíaco. El vehículo está perfecto, pero mientras manejo me da un paro cardíaco y atropello a un peatón. Tampoco me exonera: la salud del conductor no es externa al ámbito del deudor. En últimas, aquí se responde por el riesgo, no por haber manejado bien o mal.

5.9 ¿Toda acción del agente estatal genera responsabilidad del Estado? La culpa personal del agente

- **Culpa personal del agente:** el agente causa el daño en su esfera más privada, en su órbita estrictamente personal, y no en ejercicio de sus funciones. En ese

caso la causa del daño no es la actuación del Estado.

- **Nexo con el servicio o con ocasión del servicio:** solo entonces el daño es imputable al Estado.

Según la posición jurisprudencial mayoritaria, si el daño es causado por un agente estatal en el ámbito de su vida personalísima, el Estado no puede ser demandado y, si lo es, el evento se trata como un hecho exclusivo de un tercero: el juez debe declarar probada esa excepción y exonerar al Estado; la víctima debía demandar al agente como individuo, como particular. Hay críticas y controversias, pero esa es la posición mayoritaria.

EJEMPLO. Un agente dispara a alguien en una fiesta, o toma el vehículo oficial en sus vacaciones y atropella a una persona.

COMENTARIO. Este tema se explicó también el jueves (ejemplo del soldado que, fuera del servicio y por un motivo personal, mata a otra persona): ver Capítulo 3, sección 3.4.5.

5.10 ¿Los daños causados por particulares son imputables al Estado?

Art. 140 del CPACA: «(...) el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.»

Es decir, cuando el particular obra siguiendo instrucciones expresas de una entidad estatal, quien responde no es el particular, sino la entidad que dio la instrucción.

Finalidad de la norma. La comisión redactora del CPACA quiso delimitar la responsabilidad del Estado por actos de particulares, especialmente de los contratistas. Antes, la tesis mayoritaria era que si el Estado contrata a alguien y este causa un daño extracontractual, se demanda al Estado. La norma buscaba evitarlo: por ejemplo, si la ANI contrata la construcción de una carretera y una piedra cae y mata a alguien, quien decide con autonomía cómo ejecutar la obra es el contratista; el Estado solo traza un diseño y fija obligaciones. Solo si hay una instrucción expresa debería responder el Estado.

La interpretación de la Corte Constitucional (C-644 de 2011). Desafortunadamente, ese no ha sido el entendimiento de la jurisprudencia, que sigue aplicando el mismo criterio de antes del CPACA. Al estudiar la constitucionalidad de la expresión, la Corte dijo:

«La administración pública responderá por los daños causados a terceros siempre que sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, bien sea en el caso especial que la ejecución de las obras públicas las adelante con servicios y medios propios, o bien mediante el concurso de un contratista, ya que no debe olvidarse que el titular de la obra pública es siempre la administración y que ejercita sobre ella sus potestades, por lo cual debe cargar con la responsabilidad y la obligación de reparar los daños derivados de dicha actividad. Por el contrario, cuando el contratista ocasiona daños a terceros ajenos por completo a la ejecución de la obra, debe asumir exclusivamente la indemnización por los

perjuicios, sin que la administración tenga que responder por ello directa y subsidiariamente, ya que tales actos o hechos no son susceptibles de serle imputados, en razón a que se ha roto el nexo causal, es decir, por cuanto se evidencia que el contratista obró en desarrollo de actividades personales desvinculadas con las de la administración.»

La Corte no le dio relevancia a la limitación de la instrucción expresa, y hoy la jurisprudencia sigue atribuyendo al Estado los daños causados por particulares vinculados contractualmente con él.

5.11 Concurrencia de causas en la producción del daño

5.11.1 Concurrencia con un tercero: la solidaridad (art. 2344 del C.C.)

Art. 2344 del C.C.: «Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvo las excepciones de los artículos 2350 y 2355. Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso.»

Obligaciones divisibles y solidarias. No se trata del principio de solidaridad, sino de las obligaciones solidarias. En las obligaciones divisibles (un acreedor y varios deudores), cada deudor responde por su parte. En las solidarias, el acreedor puede demandar a uno o a todos los deudores, y cualquiera de ellos debe responder por la totalidad (el ejemplo típico es el codeudor). El art. 2344 establece la solidaridad por pasiva en el derecho de daños: si dos o más personas intervienen en la causación de un daño, la víctima puede reclamar a cualquiera de ellas o a todas, y cualquiera responde por la totalidad.

EJEMPLO. El edificio que se derrumba. Usted compra un apartamento y el edificio se derrumba. Se descubren dos problemas: el diseñador diseñó mal (los diseños tenían muchas falencias) y el constructor, otro sujeto, usó materiales inadecuados para abaratar el proyecto. Por el art. 2344 hay solidaridad: puede demandar solo al diseñador, solo al constructor o a ambos, y cualquiera responde por la totalidad. Si solo demanda al diseñador, este no puede exonerarse diciendo «yo me equivoqué un poquito, pero el constructor se equivocó más».

Por esta regla el hecho del tercero debe ser exclusivo. Si no lo es, se activa la solidaridad: el demandado nunca puede exonerarse diciendo que participó «solo un poquito». Lo que viene después es un problema posterior de repetición entre los responsables, según la incidencia de cada uno; pero frente a la víctima, el Código establece una protección: obtendrá el 100 % de la indemnización, demande a uno o a todos.

Esta regla se aplica tanto en lo civil como en lo contencioso administrativo: si varias entidades estatales participan en la causación del daño, hay solidaridad.

EJEMPLO. La vivienda en la ladera. En pleno invierno, los habitantes de una vivienda en una ladera ven que, por las lluvias, el piso se agrieta, la estructura se afloja y aparecen fisuras. Envían peticiones a la CAR, al Ministerio de Vivienda, a la entidad de prevención de desastres y a otras autoridades, todas con competencia en la materia, advirtiéndoles que el terreno no es estable. Ninguna hace nada; la casa se derrumba y mueren personas. Por la solidaridad, los demandantes pueden demandar a una, a varias o a todas.

5.11.2 El hecho de la víctima y los menores de edad

Hay una norma del Código Civil según la cual los menores de diez años y los dementes no son capaces de cometer delito o culpa (pero de los daños por ellos causados serán responsables las personas a cuyo cargo estén, si a tales personas pudiere imputarse negligencia). Con base en ella, en algún momento la Corte Suprema de Justicia dijo que no existía culpa exclusiva de la víctima en menores de diez años, por imprudentes que fueran.

Luego eso se modificó: en el mundo del nexo causal no se habla de culpa de la víctima, sino de hecho de la víctima. La norma que habla de culpa está enfocada en la responsabilidad del menor (sus efectos penales o como causante); lo que interesa en la causalidad no es si el menor fue imprudente, sino si tuvo o no incidencia causal en la materialización del daño. Por eso hoy se admite que un menor puede incurrir en hecho exclusivo de la víctima. El problema es determinar hasta qué punto ese hecho es exclusivo.

EJEMPLO. La niña electrocutada (caso de riesgo excepcional). Una niña de siete años está en un balcón cerca de una red eléctrica; se le cae una prenda y toma un listón de metal para alcanzarla, entra en contacto con la red, se electrocuta y muere. En primera instancia se consideró que había culpa de la víctima; el demandante replicó que a los menores no se les aplica. El Consejo de Estado concluyó que no había responsabilidad del Estado: en materia de redes eléctricas la responsabilidad gira en torno a un elemento muy particular: la distancia técnica a la que debe estar la red eléctrica, que fija el reglamento técnico (RETIE). Si la distancia está dentro de la reglamentaria, se entiende que la instalación de la red no incidió en el daño; si es menor, sí hay responsabilidad, porque la red se expuso a una distancia anormal. En el caso se demostró que la distancia era la reglamentaria. Queda una duda que el caso no abordó: ¿qué pasa si el listón era más largo que la distancia reglamentaria? En ese caso también incide el listón en la causación del daño.

5.11.3 Concurrencia con la víctima: reducción de la indemnización (art. 2357 del C.C.)

Art. 2357 del C.C.: «La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente.»

Es lo que la doctrina llama «concurrencia de culpas». Si la víctima contribuye a la causación del daño (hay un hecho de la víctima que no es exclusivo), se condena al demandado, pero se reduce la tasación de los perjuicios en proporción a la incidencia que tuvo la víctima en la causación del daño.

EJEMPLO. La defensora y el escolta (caso real). Una defensora en materia penal (contratista) había recibido muchas amenazas y la Policía le asignó un escolta. Un día, el escolta no llega porque tenía una cita médica y no alcanzó a pedir reemplazo; le pide que no salga. Ella va a un almuerzo de trabajo y, a la salida, decide no esperar al escolta y toma un taxi; un sicario le dispara tres tiros (uno en la cabeza). Sobrevive. Hubo falla del servicio de la Policía (debió asignarle otro escolta), pero también un hecho parcial de la víctima. El Consejo de Estado condenó, pero aplicó el art. 2357: estimó la incidencia de la víctima en un 20 %, de modo que si correspondían 100 salarios, se reconocieron 80.

EJEMPLO. El choque. Si yo me paso el semáforo, pero el otro conductor va borracho y me choca, hay concurrencia: si el daño era de 100 millones y el juez estima que mi participación fue del 50 %, solo se reconocen 50 millones.

5.11.4 Concurrencia del Estado con un particular (art. 140 del CPACA, último inciso)

Antes del CPACA, por el art. 2344, si el Estado había participado en el daño, aunque su incidencia fuera mínima, la víctima demandaba solo al Estado (que sí tiene con qué pagar) y este respondía por el todo. Como siempre se puede encontrar una omisión estatal (como en el ejemplo de los colegios: se demanda a la Secretaría de Educación porque el colegio está quebrado), el CPACA buscó evitarlo, con éxito:

Art. 140 del CPACA: «En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño.»

- Cuando hay dos entidades estatales en la causación del daño: solidaridad (art. 2344).
- Cuando intervienen una entidad estatal y un particular: no hay solidaridad; la obligación es divisible. Si el juez concluye que quien participó mayoritariamente fue el particular, pondera: si el daño era de 100 salarios, quizás al Estado solo le corresponda pagar 5.

EJEMPLO. Retomando el edificio: hay tres posibles responsables, el diseñador, el constructor y el curador urbano (por haber dado la licencia; supongamos que el curador no tenía por qué saber que el constructor estaba abaratando los materiales). El juez podría estimar que el 50 % de la causa fueron los diseños y el 50 % la construcción, y que, dentro de lo de los diseños, el 25 % fue responsabilidad de la curaduría y el 25 % del diseñador. Así, al curador se le condenaría por 25 millones (de 100), y frente a los otros 75 millones habría solidaridad entre el constructor y el diseñador. La obligación solo se divide entre el Estado y el particular; entre los particulares sigue operando la solidaridad.

5.12 Mecanismos de compensación de daños

La responsabilidad extracontractual es solo uno de los mecanismos para compensar daños. Se dividen en dos categorías:

Reparación judicial del daño extracontractual	Otros mecanismos de compensación del daño
Dirigida contra el causante o responsable (individual)	Para la compensación de riesgos sociales (anónimos o colectivos)
Reparación integral del daño	Socialización del daño sin pasar por el causante o responsable del daño; sistemas de reparación tarifada o <i>a forfait</i>

Reparación judicial del daño extracontractual	Otros mecanismos de compensación del daño
La víctima tiene la carga de la prueba (que puede invertirse excepcionalmente): debe acreditar el daño, el nexo causal y, en los regímenes subjetivos, la culpa; es un proceso que dura muchos años	Pueden operar sin prueba de la causalidad o de la culpa; exigen menores cargas probatorias
Función: indemnizatoria y/o demarcatoria	Función: indemnizatoria (parcialmente) y distributiva

La lógica: en el proceso judicial la víctima asume muchas cargas probatorias y un proceso largo, pero en contrapartida obtiene la reparación integral: quiere quedar indemne. Los mecanismos no judiciales le facilitan la vida a la víctima porque le exigen menos, pero en contrapartida no hay reparación integral.

Otros mecanismos de compensación:

- **Seguridad social** (por ejemplo, la pensión de sobrevivientes del soldado).
- **Sistemas de seguros obligatorios y no obligatorios, y fondos de garantías** (por ejemplo, el seguro que cubre parcialmente un accidente de tránsito).
- **Solidaridad** (desastres naturales, conflicto armado).
- **Reparación administrativa del daño:** indemnizar por vía administrativa, mediante un procedimiento más expedito, con perjuicios más limitados.

EJEMPLO. El Fondo pro víctimas del Puracé. Si explota el volcán Puracé y el Estado, mediante un decreto legislativo de estado de excepción, crea un fondo que da a cada persona que perdió su casa una ayuda solidaria (por ejemplo, 50 salarios) con la sola certificación de la entidad de gestión del riesgo, la víctima no tiene que probar el nexo causal ni mucho sobre el daño, ni exponerse a un proceso de diez años. La contrapartida: si la casa valía 500 millones, igual solo recibe la ayuda; y si murió un familiar, no se le repara, porque el Estado no causó el daño. La existencia del mecanismo de compensación no implica reconocimiento de responsabilidad.

EJEMPLO. La ARL. En los accidentes de trabajo la carga probatoria es menor; ni siquiera hay que probar la cuantía, porque el perjuicio está pretarifado por la ley. Se obtiene una compensación más rápida, pero se sacrifica la reparación integral.

EJEMPLO. La aspersión aérea con glifosato. La Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos, tenía un procedimiento administrativo de reparación de daños: si el propietario acreditaba que su finca fue asperjada, se le reconocían indemnizaciones pretarifadas por hectárea, según lo sembrado.

¿Pueden coexistir ambos mundos? ¿Debe descontarse? Sí pueden coexistir, y en principio debe descontarse lo recibido, pero hay que mirar en cada caso qué dice la regulación específica.

EJEMPLO. Retomando el Puracé: una damnificada recibe 50 salarios del fondo y, simultáneamente, demanda al Estado porque, a pesar de tener la información (alerta amarilla y naranja), no informó a la población ni adoptó medidas de evacuación. Puede demandar, porque si prueba la falla del servicio el Estado causó el daño. Si gana, en principio deben descontarse los 50 salarios.

Art. 20 de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas): «La indemnización recibida por vía administrativa se descontará a la reparación que se defina por vía judicial. Nadie podrá recibir doble reparación por el mismo concepto.»

Si una víctima de desplazamiento recibe la indemnización administrativa y luego gana un proceso de reparación directa por omisión del Estado, el descuento es indiscutible, porque hay norma especial; el Estado debe pedirle al juez que, si condena, descuento lo pagado. Es la misma lógica de la *compensatio*: la víctima no puede obtener doble compensación.

COMENTARIO. La discusión real se da cuando la ley no dice nada. Es razonable sostener que también debe operar el descuento si la fuente del daño es la misma, porque no hacerlo implicaría enriquecer a la víctima; pero la discusión está abierta. (En el caso de la seguridad social de la fuerza pública ya se vio que, según la unificación, no opera el descuento.)

Capítulo 6

Títulos de imputación

6.1 Factores de atribución en la responsabilidad extracontractual civil

- **Art. 2341 del C.C.: la culpa** (regla general).
- **Art. 2356 del C.C.: actividades peligrosas** (excepción). Se discute: ¿riesgo (responsabilidad objetiva) o presunción de culpa?
- **Otros criterios de atribución objetivos** (excepción): custodia y obligaciones de resultado.

COMENTARIO. Síntesis: en materia civil el fundamento general es la culpa; excepcionalmente el riesgo, cuando se trata de actividades o instrumentos peligrosos, lo que permite aplicar un régimen objetivo. En el ámbito contractual, la responsabilidad objetiva se aplica ante obligaciones de custodia o de resultado. La lógica en la responsabilidad estatal es bastante parecida.

6.2 Factores de atribución en la responsabilidad extracontractual del Estado (posición mayoritaria)

- **Falla del servicio:** regla general. Es un régimen subjetivo de responsabilidad.
- **Títulos o factores de imputación objetivos:** excepcionales. Son el riesgo excepcional (ante actividades peligrosas) y el daño especial (ante actividades lícitas del Estado que rompen el equilibrio frente a las cargas públicas).

6.3 La falla del servicio

6.3.1 Fundamento constitucional

«ARTÍCULO 16. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.» (Constitución de 1886)

Este artículo corresponde hoy, en términos bastante similares, al artículo 2.º de la Constitución de 1991.

6.3.2 Características de la falla del servicio

a) **Estándar del servicio (funcionamiento normal).** Al igual que la culpa, la falla del servicio se estudia por vía de comparación: se compara el estándar exigible del servicio con lo que hizo el demandado. Ese estándar está fijado por las normas aplicables a la entidad (de rango legal, reglamentario, normas internas, manuales de operación, etc.); la falla consiste en la violación de obligaciones legales. Se concreta en:

- Falta de prestación (omisión).
- Prestación tardía.
- Prestación defectuosa.

b) **Carácter relativo de la falla del servicio.** Las obligaciones del Estado son, por regla general, obligaciones de medio y no de resultado, y eso incide en la forma de estudiar la falla.

EJEMPLO. El desplazamiento en el Alto Baudó (ejemplo de una clase anterior): ¿hasta qué punto responde el Estado si creó dos batallones e hizo cien misiones? Hay que preguntarse qué podía hacer razonablemente.

c) **Carácter anónimo de la falla del servicio.** No es relevante identificar al agente concreto que causó el daño; basta explicar que fue ocasionado por la entidad.

6.4 Regímenes de responsabilidad basados en la falla del servicio

La falla del servicio es la regla general. Estos son los principales casos en que se aplica (no son todos):

6.4.1 Responsabilidad médica

Por regla general, en responsabilidad médica se exige la falla del servicio: si no está demostrada en el proceso, no se puede condenar a la entidad prestadora del servicio. Se abandonó el régimen de falla presunta (la falla médica presunta se aplicó hasta antes de 2006). Esta regla tiene tres excepciones, en las que se aplica responsabilidad objetiva:

a) **Ginecobstetricia.** Si en el parto fallece la mujer o la persona que está naciendo, no se exige falla del servicio. La lógica del Consejo de Estado: las mujeres han podido dar a luz desde la prehistoria sin médicos ni hospitales; hoy, con médicos, hospitales y avances tecnológicos, no debe existir ningún riesgo para la madre ni para quien va a nacer. Se asimila casi a una obligación de resultado.

b) **Cirugías estéticas.** Por la misma razón: lo que se busca con una cirugía estética es un resultado; si no se obtiene, hay responsabilidad objetiva.

EJEMPLO. Un ejemplo popular es el programa de televisión «Cambio extremo» y la cirugía de René Higuita, cuyo resultado muchos no notaron, pero a quien su amigo, el «Bolillo» Gómez, le dijo en pleno programa que se veía «como un holandés»: «uno necesita en la vida un amigo así».

c) **Infecciones nosocomiales (intrahospitalarias).** Son bacterias intrahospitalarias altamente resistentes a la limpieza y a los procedimientos de asepsia de los quirófanos. La persona va, por ejemplo, a que le saquen una muela, contrae la bacteria y esta le genera complicaciones muy graves, incluso la muerte.

- **Consejo de Estado:** desde hace muchos años aplica responsabilidad objetiva. Es la solución correcta y justa: si la bacteria no puede ser erradicada por los procedimientos de limpieza, exigirle a la víctima que pruebe la falla del servicio es injusto, porque no es un problema de falla: por más limpieza que se haga, la bacteria sigue activa en el quirófano; es de su esencia. La diligencia no importa; no es elemento de la responsabilidad: el hospital nunca se exonera mostrando diligencia.
- **Corte Suprema de Justicia:** exige la culpa: hay que demostrar que la clínica no limpió bien. Pero ¿cómo se demuestra la culpa si la bacteria es resistente a la limpieza? Si el quirófano se limpia cada semana, no habría culpa.

COMENTARIO. Existe la posibilidad de que el tema se lleve a unificación en el Consejo de Estado para cambiar la posición y exigir la falla del servicio, lo que resultaría inadecuado y sin fundamento. Habrá que esperar a que se expida el auto que avoque conocimiento para unificar y a que la Sala Plena de la Sección Tercera unifique la materia.

6.4.2 Daños sufridos por miembros de la fuerza pública (soldados regulares)

Hay que distinguir entre los miembros profesionales de la fuerza pública y los conscriptos:

- **Miembros profesionales (ingreso voluntario):** llegan por decisión propia («mi sueño toda la vida era ser policía»). Cuando ingresan, son conscientes de los riesgos: saben que serán enviados a misiones en las que exponen su vida y su integridad para mantener el orden público. Si sufren un daño (lesión o muerte) dentro del riesgo propio de la actividad, el Estado no responde. Solo responde cuando incrementa el riesgo al que está expuesto el soldado, lo que ocurre cuando incurre en falla del servicio.

EJEMPLO. Un soldado muere en una operación de desmantelamiento de un laboratorio de coca en la que se cumplieron todos los requisitos (hubo inteligencia, apoyo militar y acompañamiento de la Fuerza Aérea) durante un enfrentamiento con el grupo armado que protegía el laboratorio. No hay responsabilidad: es un riesgo propio de su actividad. En cambio, si se le envía sin inteligencia previa, sin apoyo del batallón y sin las armas adecuadas («con un simple bolillo») y lo matan, hay falla del servicio y responsabilidad del Estado.

- **Conscriptos (servicio militar obligatorio):** no deciden voluntariamente someterse al riesgo; prestan el servicio porque es una obligación legal. Por eso se les aplica responsabilidad objetiva (ver 6.5).

6.4.3 Colisión de actividades peligrosas

Si un vehículo del Estado atropella a un peatón, se aplica el riesgo excepcional (responsabilidad objetiva), sin discusión. Pero cuando tanto la víctima como el responsable ejercen una actividad peligrosa, se anula la aplicación de la responsabilidad objetiva.

EJEMPLO. Mariana y John Jairo chocan, cada uno en su vehículo. No se puede aplicar responsabilidad objetiva, porque ambos podrían demandarse mutuamente

con ese fundamento y no se sabría quién es el responsable. La pregunta no es quién causó el daño (ambos lo causaron, porque ambos conducían), sino quién incurrió en culpa: ¿quién violó las normas de tránsito, se pasó el semáforo o el pare, o iba con exceso de velocidad?

Lo mismo ocurre en materia estatal: si un vehículo del Estado choca con el mío, el caso debe fallarse con base en la falla del servicio. Cuando hay colisión de actividades peligrosas se vuelve al régimen subjetivo: culpa en lo civil, falla del servicio en lo estatal.

COMENTARIO. ¿Qué ocurre cuando hay culpas compartidas entre la víctima y el demandado? Es un problema de nexo causal y se aplica el art. 2357 del C.C. (concurrency), como en el caso de la defensora que no esperó al escolta o en el del choque en el que uno se pasa el semáforo y el otro va borracho (se reduce la indemnización según la participación de la víctima). Y si la concurrencia es con un tercero, no exonera, por la solidaridad (ver Capítulo 5).

6.4.4 Daños causados por actos terroristas

La lógica. El daño lo causa, por acción, un grupo al margen de la ley: en principio es un hecho de un tercero, porque el Estado no es el terrorista. El Estado responde porque es un hecho de un tercero que no cumple los requisitos de la causa extraña: no es imprevisible o no es irresistible. Si el acto terrorista es imprevisible e irresistible, hay hecho exclusivo de un tercero y el Estado no responde. Si era previsible o resistible, el Estado responde por omisión, porque incurrió en falla del servicio (sabía que iba a haber un ataque y no hizo nada, o podía resistirlo y no lo hizo).

EJEMPLO. El Palacio de Justicia (6 y 7 de noviembre de 1985). El M-19 ingresó al Palacio de Justicia. Los familiares de los magistrados que murieron demandaron al Estado y este fue condenado porque se demostró la falla del servicio con dos hechos: (i) un mes antes, en octubre, durante los operativos de seguridad por la visita a Bogotá de Mitterrand, mandatario de Francia, el Ejército encontró una guarida del M-19 con los planos del Palacio de Justicia, y no se hizo nada para reforzar su seguridad; (ii) por el contrario, se retiró la seguridad del Palacio. Según la versión oficial, el viernes anterior al ataque los organismos de seguridad se habrían reunido en el Palacio con el presidente de la Corte Suprema, Reyes Echandía (quien murió en los hechos), y él habría dado la instrucción de retirar la seguridad. Esa versión se demostró falsa en el proceso de reparación directa: a la hora de la supuesta reunión, Reyes Echandía estaba en Bucaramanga dictando clase en una especialización. El atentado era previsible y resistible, y no se hizo nada.

EJEMPLO. El Club El Nogal: el Estado fue exonerado porque se demostró que el ataque no era resistible y, sobre todo, no era previsible (ver Capítulo 5, imprevisibilidad).

Primera discusión: la flexibilización probatoria y el «contexto de orden público». La jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte ha dicho que en estos casos es posible inferir la falla del servicio —la previsibilidad del ataque— a partir del contexto de orden público de la zona. La pregunta normal sería: ¿el Estado tenía conocimiento de que iba a haber una bomba?, ¿recibió amenazas?, ¿alguien pidió medidas de protección? Si la respuesta es no, en principio el Estado no responde. Con la tesis del contexto, aunque no haya amenazas ni solicitudes, se pregunta si la situación de orden público (por ejemplo, en Ipiales) era tan grave que el Estado debía saber que

pondrían una bomba; si la respuesta es sí, se condena.

COMENTARIO. Crítica: eso no es adecuado. Colombia ha vivido un contexto de guerra de 60 años; si el contexto de orden público bastara para demostrar la falla, en el Catatumbo (donde incluso hubo estado de excepción) el Estado debería responder por cualquier robo o muerte. Esa no puede ser la lógica. Aun defendiendo la responsabilidad objetiva del Estado, el problema de la «quiebra» del Estado no está en si el régimen es objetivo o subjetivo, sino en flexibilizar las pruebas y crear reglas de contexto que protegen a las víctimas sin ser juiciosos con el estudio de la falla ni de la causalidad: aunque el discurso defienda la falla del servicio, se condena con reglas flexibles en las que ni siquiera hay una falla clara. ¿Cómo aplicar entonces el artículo 90? Lo que sucede en el Catatumbo es un problema de hecho de un tercero: incluso con responsabilidad objetiva, si el ataque era imprevisible e irresistible, el Estado no responde; si el Estado sabía que pondrían una bomba y no hizo nada, responde. Si uno estudia con juicio la causa extraña, el Estado no tiene que responder por muchas cosas. La pregunta no es si en términos generales y abstractos el Estado podía prever o resistir ataques (por ejemplo, porque se le recortó el presupuesto al Ejército), sino qué podía hacer frente a ese ataque concreto y qué información previa tenía.

COMENTARIO. La resistibilidad del ataque también depende de la capacidad del Estado frente a los grupos armados: cabe preguntarse hasta qué punto puede resistir si el otro lo supera en tecnología.

COMENTARIO. Sobre la reserva de la información: la norma del CPACA que enumera las informaciones con reserva incluye en su numeral 1 la relacionada con la seguridad nacional, pero esa reserva cubre información como la contratación de armamento o la tecnología usada. Sobre hechos ya ocurridos y objeto de investigación no hay reserva: después de un atentado se puede pedir a la Fiscalía o al Ministerio de Defensa información sobre si antes del atentado alguien solicitó medidas de protección o radicó amenazas, o si se hicieron escaneos del espectro, lo que ayuda a determinar la responsabilidad.

Segunda discusión: ¿riesgo excepcional en ataques terroristas? Todo el Consejo de Estado está de acuerdo en que a los ataques terroristas se les aplica la falla del servicio (la única discusión es si puede inferirse del contexto). Lo que sí está en discusión es si puede aplicarse el riesgo excepcional.

EJEMPLO. Un grupo armado pone una bomba contra una estación de Policía y en el atentado muere un civil. Quienes defienden el riesgo excepcional dicen que el Estado responde porque el atentado iba dirigido contra una infraestructura representativa del Estado (o contra una figura representativa del Estado): la presencia de esa infraestructura o persona generó un riesgo excepcional y se rompió el equilibrio. La jurisprudencia está muy dividida: otros dicen que, contra quien sea que vaya dirigido, sigue siendo un problema de hecho de un tercero, y lo importante es si el ataque era previsible y resistible.

COMENTARIO. Crítica: esa teoría no es consecuente con la causa extraña y genera una discriminación «completamente odiosa e injustificada»: si alguien lanza una granada en un salón de clase y todos mueren, sin información previa de amenazas, el Estado no responde; pero si en el salón estuviera estudiando un ministro, según esa tesis el Estado sí respondería por todos. Habría víctimas de primera y de segunda

categoría. La presencia del ministro no cambia en nada el hecho dañoso: el problema debe girar en torno a si el atentado era o no previsible y resistible.

EJEMPLO. En el caso de El Nogal también se propuso esa segunda imputación: los demandantes alegaron que allí solía hospedarse la entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, que hacía reuniones con la cúpula militar, de modo que el ataque iba realmente contra la cúpula. No fue necesario estudiarlo, porque se demostró que ni el día del atentado ni en los días previos la ministra estuvo alojada en El Nogal.

6.4.5 Daños causados en enfrentamientos armados

Hay que ser muy cuidadoso con el contexto específico: el hecho de que el daño provenga de un arma oficial no activa automáticamente el régimen objetivo.

EJEMPLO. Caso 1. Un soldado que patrulla en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, dispara por accidente su arma y hiere a un peatón. Se aplica el riesgo excepcional: daño causado por un arma de dotación oficial; responsabilidad objetiva.

EJEMPLO. Caso 2. En una situación de orden público complicada, una persona armada se enfrenta con la Policía, que le pide entregar el arma, y la Policía la mata. Como ambos estaban armados, hay un enfrentamiento: se aplica la falla del servicio (¿la respuesta fue proporcional?, ¿se ajustó a los manuales?, ¿dispararon primero sin pedirle que entregara el arma?). Es la misma lógica de la colisión de actividades peligrosas: ambos usan instrumentos peligrosos, se anula el régimen objetivo y se vuelve a la falla.

EJEMPLO. Caso 3. Hay un enfrentamiento entre el Ejército y un grupo armado, y una bala del Estado hiere a un campesino que pasaba por el lugar. Se ha dicho que la responsabilidad es objetiva: es un daño colateral que el campesino no está en el deber de soportar. Se llega por cualquiera de los dos caminos: riesgo excepcional (arma oficial) o daño especial (ruptura del equilibrio ante las cargas públicas).

6.4.6 Daños causados por omisión en la prestación de medidas de protección

Es un típico caso de falla del servicio, similar a los actos terroristas. Si un líder social recibe amenazas y lo matan en un atentado, el Estado solo responde si se demuestra la falla: que antes del atentado la persona solicitó medidas de protección o puso las amenazas en conocimiento del Estado. La gran pregunta, como en los actos terroristas, es si el contexto de orden público permite imputar responsabilidad: ¿por el solo hecho de ser líder social o de vivir en el Catatumbo, el Estado debía saber que tenía un riesgo más alto? Esas son las discusiones en este tipo de casos.

6.4.7 Daños relacionados con la prevención de desastres

El Estado no puede prevenir ni resistir un desastre natural (un terremoto, una erupción volcánica, una inundación, un tsunami), pero sí puede evitar sus consecuencias adversas si tenía información previa. El caso Armero, el volcán que explota sin que se activen las alertas o el tsunami del que no se informó a la población son típicos casos de falla del servicio. En los desastres naturales, la responsabilidad gira en torno a la falla del servicio.

6.5 Regímenes de responsabilidad objetiva

6.5.1 Actividades peligrosas (riesgo excepcional)

Se aplica el riesgo excepcional ante actividades e instrumentos peligrosos, salvo que haya enfrentamiento o colisión de actividades peligrosas.

6.5.2 Daños causados por armas de dotación oficial (excepto enfrentamientos)

Ver los casos de la sección 6.4.5.

6.5.3 Daños sufridos por internos

No se trata de la privación injusta de la libertad ni del daño causado por la detención, sino del daño que sufre el interno estando recluso. Si en un motín apuñalan a un interno, se aplica responsabilidad objetiva, porque el Estado tiene una obligación de custodia de la persona privada de la libertad: custodia la cárcel, revisa si ingresan armas y tiene a los guardianes rondando.

La problemática de los suicidios. En principio podría pensarse que el suicidio es un hecho exclusivo de la víctima, pero no todos los suicidios son imprevisibles ni irresistibles para el Estado.

EJEMPLO. Primer caso: un privado de la libertad con problemas de comportamiento (seguramente psicológicos) es enviado a una celda de aislamiento y allí se golpea la cabeza durante dos horas hasta morir, sin que nadie lo detenga. Se condenó al Estado: podía evitarlo.

EJEMPLO. Segundo caso: un interno sin ningún antecedente psicológico o depresivo se lanza de un cuarto piso de la cárcel. El Estado no tenía ninguna información previa de que atentaría contra su vida: hay hecho exclusivo de la víctima.

6.5.4 Daños sufridos por conscriptos

Al conscripto se le aplica responsabilidad objetiva: es irrelevante si hubo o no falla del servicio. El Consejo de Estado lo funda en un discurso similar al de la obligación de custodia del derecho civil: es el Estado quien custodia al conscripto durante la prestación del servicio, y debe devolverlo en las mismas condiciones físicas y mentales en que ingresó.

COMENTARIO. ¿El título es daño especial o riesgo excepcional? Habría que verlo caso a caso; el Consejo de Estado es impreciso en eso y lo ha fundado más en la custodia (si el daño lo causa un arma, podría pensarse en riesgo excepcional).

6.5.5 Daños causados por actividad lícita del Estado (daño especial)

Son los daños causados por la actividad lícita del Estado que rompen el equilibrio ante las cargas públicas: el típico caso de daño especial.

6.5.6 Daños causados por ocupación permanente (o temporal)

No es relevante si hubo o no falla del servicio: lo importante es que el Estado construyó una obra en un predio sin permiso del propietario, y eso genera automáticamente responsabilidad objetiva.

6.5.7 Daños causados por la ejecución de obra pública

Construir puentes o hidroeléctricas son obras públicas que se consideran actividad peligrosa; por eso permiten imputar responsabilidad bajo un régimen objetivo.

6.5.8 Daños causados por la revocatoria de actos administrativos

La revocatoria de actos preparatorios en actuaciones administrativas es un caso de daño especial.

EJEMPLO. Los huevos incautados. Usted es dueño de una empresa de alimentos y vende huevos en todo el país. La DIAN incauta un camión de huevos porque considera que no pagó determinado impuesto, contribución o tema aduanero. Los huevos duran incautados un año y el procedimiento administrativo concluye a su favor: sí había pagado. El procedimiento fue completamente lícito (la DIAN podía ordenar la incautación), pero los huevos eran perecederos y ya no sirven para nada: hay daño especial y responsabilidad objetiva.

Capítulo 7

Otros temas relacionados con la responsabilidad extracontractual del Estado

7.1 Daños antijurídicos causados por la acción u omisión de los agentes judiciales

El artículo 65 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) prevé tres supuestos de responsabilidad del Estado por la actividad judicial:

- Error judicial (jurisdiccional).
- Privación injusta de la libertad.
- Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Todos parten de la noción de daño antijurídico (C-037 de 1996).

7.2 El error judicial

DEFINICIÓN. **Error judicial:** daño causado por una providencia judicial que contiene un error.

7.2.1 Primer presupuesto: el agotamiento de los recursos legales

Si quien sufre el error no recurre la providencia y demanda al Estado, perderá el proceso por no cumplir el requisito del agotamiento de los recursos. Este requisito tiene una vinculación con el problema de la causalidad: la ley (art. 70 de la Ley 270 de 1996) establece que no agotar los recursos configura culpa exclusiva de la víctima. Tiene mucha lógica: si lo que causa el daño es una providencia equivocada, la víctima tiene un remedio para evitar el daño, que es recurrirla. El recurso es el instrumento procesal que busca la corrección del error y, desde el punto de vista de la responsabilidad, la herramienta para evitar que el daño se consume. Si la víctima no recurre, el daño ya no proviene de la decisión judicial, sino de su propia conducta omisiva.

EJEMPLO. Freddy y Daniela. Freddy le vende un computador a Daniela por un millón de pesos mediante un contrato verbal y Daniela no le paga. Freddy demanda:

pide que se declare la existencia del contrato y que se condene a Daniela. Gabriel, que estuvo presente en la venta, declara que escuchó toda la conversación y que fue clarísimo el precio. El juez niega las pretensiones porque el contrato no constaba por escrito. Hay dos errores judiciales claros: (i) en materia civil se acepta el contrato verbal, no tenía por qué constar por escrito (defecto sustantivo); y (ii) el juez no valoró la declaración de Gabriel (defecto fáctico o probatorio). ¿Puede Freddy demandar por error judicial? No, si no apela: tenía un camino para evitar que el error se consumara. Si no apela, hay culpa exclusiva de la víctima, porque con su omisión permitió que se configurara el daño.

¿Qué recursos deben agotarse? La ley no indica qué tipo de recursos.

- **Recursos ordinarios:** son abiertos; permiten formular cualquier reparo (normativo, probatorio, por cualquier razón).
- **Recursos extraordinarios:** tienen causales taxativas (por ejemplo, la casación).

El Consejo de Estado ha dicho que, en principio, solo debe exigirse el agotamiento de los recursos ordinarios: no se exige tutela ni la interposición de recursos extraordinarios. La lógica es que, como los recursos extraordinarios tienen causales taxativas, no tiene sentido exigirle a Freddy que presente casación si ninguna causal le permite enmendar el error concreto.

EJEMPLO. Si Freddy apela y el tribunal vuelve a negar —ahora reconociendo que el contrato puede ser verbal, pero diciendo que no demostró el acuerdo y otra vez sin valorar el testimonio de Gabriel—, el problema es de valoración probatoria, y las causales de casación no están diseñadas para volver a cuestionar la valoración de las pruebas. Sería un error exigirle agotar la casación para demandar al Estado, porque no serviría para corregir el error que causa el daño.

Excepción: cuando el recurso extraordinario sí sirve para enmendar el error. Algunos fallos han dicho que los extraordinarios sí deben agotarse cuando la situación específica permite que el recurso extraordinario enmiende el error judicial que es la fuente del daño.

EJEMPLO. Supongamos que el tribunal le da la razón a Freddy y condena a Daniela a pagar 1.200.000 pesos, aunque en las pretensiones Freddy pidió con toda claridad solo 500.000. Hay un problema de congruencia: se le reconoció más de lo pedido. Daniela podría demandar por error judicial, pero tiene un recurso específico: el recurso extraordinario de revisión, por nulidad originada en la sentencia por violación del debido proceso por incongruencia (la Corte Suprema de Justicia ha dicho que puede invocarse esa causal cuando se viola la congruencia). Si Daniela no interpone la revisión, hay culpa exclusiva de la víctima: podía cuestionarlo y no lo hizo.

COMENTARIO. La tutela. El Consejo de Estado, en su posición mayoritaria, ha dicho que no es necesario agotar la tutela. Esto es discutible, porque hoy la tutela contra providencias judiciales permite discutir prácticamente todos los errores (defecto sustantivo, procedimental, orgánico o de competencia, error inducido, violación directa de la Constitución, desconocimiento del precedente: las causales de procedencia de la tutela contra providencias). No exigirla equivale casi a decirle al demandante: «no haga nada y demande al Estado cuando se equivoque».

7.2.2 Segundo presupuesto: la providencia debe estar en firme

La Ley 270 exige que la providencia que contiene el error esté en firme para poder demandar. Por eso, si se apeló, hay que esperar a que se resuelva la apelación: mientras la providencia no esté en firme, no produce efectos y, en consecuencia, no hay daño que pueda demandarse.

Efectos de los recursos:

- **Efecto suspensivo:** se suspende el cumplimiento de la providencia y el proceso no puede avanzar hasta que se resuelva el recurso.
- **Efecto devolutivo:** la providencia se cumple y el proceso continúa.
- **Efecto diferido:** la providencia recurrida no se cumple, pero el proceso continúa.

7.2.3 Problemáticas del error judicial

a) **Providencias que no están en firme, pero que produjeron efectos.** Hay casos en los que la lógica de la firmeza pierde su razón de ser. El Consejo de Estado ha reconocido dos excepciones:

EJEMPLO. Primera excepción – El caso Telecom (recurso concedido en efecto distinto al suspensivo). Después de la liquidación de Telecom, unos 120 extrabajadores presentaron una tutela contra el patrimonio remanente de Telecom reclamando una prima o bonificación laboral nunca reconocida. El juez de primera instancia concedió el amparo y ordenó pagar una indemnización muy alta. Como las tutelas se cumplen de inmediato, Telecom pagó e impugnó, alegando que la tutela era improcedente por falta de inmediatez (Telecom se había liquidado cinco o diez años antes) y de subsidiariedad (debían demandar ante la jurisdicción laboral). El tribunal revocó y la Corte Constitucional confirmó la improcedencia y compulsó copias, porque se descubrió un escándalo de corrupción (varios jueces habían expedido sentencias similares). Telecom demandó al Estado, porque pagó una plata que nunca le devolvieron. El tribunal negó la demanda porque la providencia que contenía el error no estaba en firme (había sido revocada). El Consejo de Estado dijo que, aunque la providencia no estuviera en firme, en este caso la exigencia no tenía sentido, porque la impugnación no se concede en efecto suspensivo y la providencia produjo efectos.

EJEMPLO. Segunda excepción – La medida cautelar revocada. En un proceso ejecutivo de Freddy contra Daniela se embargan la casa de Daniela y parte de su sueldo o de su cuenta bancaria. La medida cautelar dura seis meses, hasta que el juez la revoca reconociendo que Daniela ya había pagado y lo había demostrado oportunamente con la excepción de pago (o que no existía título ejecutivo). Si se aplicara la ley al pie de la letra, Daniela no podría demandar porque la medida ya no está en firme; pero el Consejo de Estado dijo que esa providencia produjo efectos durante seis meses, y eso es lo que le causó el daño.

COMENTARIO. Precisiones. ¿Es necesario que comparezca el juez que profirió la providencia? No: la providencia habla por sí sola; los razonamientos internos del juez son irrelevantes. ¿Qué se pediría en el caso del embargo? Los perjuicios que causó la medida (por ejemplo, el dinero que se dejó de recibir o el préstamo que hubo que pedir por no tener liquidez).

b) **Individualización del daño y el problema de la cosa juzgada: la «dura realidad» del error judicial.** El error judicial siempre se origina en un proceso

judicial con dos partes (A contra B), civil, laboral o de cualquier tipo. Hay casos en que el error es claro (como el de Freddy). Pero la «dura realidad» del 90 o 95 % de los casos es otra: A pierde en primera instancia y pierde con razón; apela y vuelve a perder con razón. Sin embargo, el litigante le dice al cliente que todo es «súper arbitrario», le sigue cobrando honorarios, propone casación, luego tutela, y cuando se la declaran improcedente, demanda al Estado por error judicial ante el juez de reparación directa. Ha sido incluso un tema del Sistema Interamericano: «es el abuso más grande del derecho». El error judicial se ha convertido en la vía para generar una tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima instancia.

La respuesta del Consejo de Estado: la identidad de pretensiones. Ante esa realidad, el Consejo de Estado adoptó una posición muy cerrada: si A perdió el proceso y demanda al Estado, las pretensiones de la reparación directa no pueden ser las mismas del proceso original. Si A reclama al Estado el mismo millón de pesos que reclamaba a la otra parte, evidencia que está usando la reparación directa como una instancia más para volver a discutir lo que perdió; cuando hay identidad de pretensiones, se cierra el camino de la responsabilidad por error jurisdiccional.

COMENTARIO. Valoración: la salida tiene sentido para evitar el abuso, pero corta demasiado fuertemente la responsabilidad del Estado. ¿Qué pretensiones distintas va a formular quien sí tenía derecho, si su daño consiste justamente en no haber podido acceder a sus pretensiones? En la práctica, si quien pierde es el demandante A y luego demanda al Estado, casi siempre le dicen que no. El error jurisdiccional suele prosperar cuando se condena injustamente a B (el demandado), porque como B no formuló pretensiones puede alegar que le impusieron una condena sin sentido; es lo que ocurrió en el caso Telecom. Si los extrabajadores de Telecom hubieran tenido razón y demandaran al Estado por lo mismo, muy seguramente les dirían que no.

c) Error judicial contenido en providencias de altas cortes (C-037 de 1996). La Ley 270 tuvo control de constitucionalidad. La Corte Constitucional declaró exequible el régimen de responsabilidad por error judicial, pero lo moduló: siempre y cuando el error no provenga de una providencia de una alta corte. Afortunadamente, el Consejo de Estado, en todas sus subsecciones, no ha aplicado esa modulación y ha dicho expresamente que es equivocada: las cortes también cometen errores judiciales, porque sus magistrados son jueces como cualquier otro ser humano; no importa que sea la Corte Suprema o un juzgado.

d) Cómputo de la caducidad cuando se ha interpuesto tutela. Retomando el caso de Freddy: le negaron sus pretensiones en primera y segunda instancia porque, equivocadamente, le exigieron un contrato escrito. Antes de demandar al Estado, Freddy, diligente, presenta una tutela por defecto sustantivo (aplicaron mal o inaplicaron la norma del Código Civil) y por defecto fáctico (no valoraron los testimonios). En primera y segunda instancia la tutela se declara improcedente por falta de relevancia constitucional. ¿Desde cuándo se cuenta la caducidad? El Consejo de Estado la cuenta desde la ejecutoria de la providencia que contiene el error (la fuente del daño), no desde la tutela, lo que equivale a castigar a Freddy por haber sido un buen litigante. En cambio, si la tutela prospera y deja sin efecto la providencia, el Consejo de Estado sí cuenta la caducidad desde la sentencia de tutela, porque en ese momento se conoce la antijuridicidad del daño. En ese escenario, los perjuicios reclamables serían los que no se reconocieron luego en la sentencia ordinaria, la demora del proceso, los honorarios

adicionales, etc. La regla resulta injusta: si la tutela revoca, se extiende la caducidad; si no revoca, no se extiende.

e) La incidencia material del error. ¿Qué pasa si en el proceso de reparación directa se evidencia que el demandante de todos modos iba a perder por otra razón? El juez no puede cambiar la imputación fáctica ni «mover de título» el caso, pero dentro del análisis del error, incluso si se supera el problema de la identidad de pretensiones, el demandante debe acreditar que habría ganado el proceso. Si el tribunal negó por exigir una prueba solemne y, además, porque no había ninguna prueba sobre el precio del computador, el error no basta: había otra razón para negar. El solo error judicial no permite indemnizar automáticamente; hay que demostrar que tuvo una incidencia material en la decisión.

COMENTARIO. La tensión del error judicial. En la práctica, incluso en la tutela contra providencias se han llegado a exigir estándares muy altos (como demostrar la mala fe de los jueces), y si el error no se logra demostrar por esa vía, es aún más difícil hacerlo luego como error judicial. Se entiende por qué la jurisprudencia es tan restrictiva: el error judicial no es una instancia más y los procesos deben tener cierre por seguridad jurídica. Pero pueden darse casos de errores reales: el juez debe ser muy cuidadoso para descartar los casos en los que el error judicial se usa como séptima, octava o novena instancia, y tener la sensibilidad de identificar los casos en que sí hubo un error y estudiarlos con juicio. Como estos casos llegan masivamente, es probable que, por ser tan restrictivos, algunos errores reales no se estudien adecuadamente.

f) Error judicial contenido en decisiones arbitrales. Es otra de las problemáticas de la responsabilidad del Estado por error judicial.

7.3 La privación injusta de la libertad

En privación injusta de la libertad hay (o había) tres discusiones:

- El régimen de responsabilidad aplicable.
- El estudio de la culpa exclusiva de la víctima (la Ley 270 habla de culpa de la víctima, no de hecho de la víctima).
- La liquidación de perjuicios.

7.3.1 Normas

Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal), art. 414: «Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.»

El art. 414 tenía dos partes y, por tanto, dos reglas: (i) quien fue privado injustamente de la libertad puede demandar; (ii) quien fue absuelto porque el hecho no existió, porque el sindicado no lo cometió o porque la conducta era atípica, tiene derecho a ser indemnizado y solo exonera al Estado la culpa de la propia víctima (dolo o culpa grave).

Ley 270 de 1996, art. 68: «PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.»

7.3.2 Evolución del régimen de responsabilidad aplicable

a) Régimen objetivo para los casos del art. 414 y subjetivo para los demás.

El Consejo de Estado interpretó que en los tres eventos del art. 414 la responsabilidad es objetiva: el demandante no tiene que demostrar la ilegalidad de la medida de aseguramiento; solo exonera la culpa de la víctima. En todos los demás casos debe probarse la falla del servicio, esto es, la ilegalidad de la medida de aseguramiento; especialmente cuando la absolución se daba por duda (*in dubio pro reo*).

EJEMPLO. El hecho no existió (es el supuesto menos frecuente). Un ciudadano israelí está en Santa Marta y su familia denuncia que fue secuestrado porque no saben dónde está. En un operativo, la Fiscalía lo encuentra en una finca con un mayordomo, a quien capturan y le imputan secuestro. El mayordomo dura privado de la libertad tres o cuatro meses. En el proceso, el israelí declara que estaba feliz: el mayordomo le conseguía trago y lo invitaba a fiestas. Lo absuelven porque el secuestro no existió: el israelí nunca estuvo allí contra su voluntad.

EJEMPLO. El sindicado no lo cometió. Un abuelito se encuentra en la calle al novio de su nieta, varado en una camioneta, y lo ayuda. En ese momento llega la Policía: la camioneta era robada. Ambos son detenidos; el abuelito dura privado de la libertad unos tres meses y luego se precluye la investigación a su favor, porque el propio novio declara que el abuelito no tenía nada que ver.

EJEMPLO. La conducta es atípica. Unos italianos que vivían en Cartagena se dedicaban los fines de semana a la caza deportiva en la Ciénaga de la Virgen y cazaron un pato. La Policía consideró que era un animal en peligro de extinción y que su muerte constituía delito. Duraron privados de la libertad tres o cuatro meses; luego se precluyó la investigación, porque la autoridad ambiental, citada al proceso penal, aclaró que ese pato no era de la especie en peligro de extinción y sí podía cazarse.

b) La Ley 270 de 1996. La privación injusta como fuente de responsabilidad surge del art. 90 de la Constitución; luego vienen el Decreto 2700 de 1991 y la Ley Estatutaria 270 de 1996. Pero la Ley 270 solo reprodujo la primera parte del art. 414, no la segunda. El Consejo de Estado se preguntó entonces si en todos los casos debía exigir falla del servicio o aplicar responsabilidad objetiva. Durante muchos años siguió aplicando la regla del art. 414, incluso después de su derogatoria con el siguiente Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000): objetiva en los tres eventos; falla del servicio en los demás, especialmente en las absoluciones por duda.

COMENTARIO. Caso: una persona condenada había informado su cambio de domicilio, pero la siguieron notificando en la dirección anterior; no pudo ejercer su defensa y su defensor público fue negligente. La Sala declaró la violación del debido proceso por indebida notificación y dejó sin ejecutividad la sentencia condenatoria, pero la persona sigue privada de la libertad porque el proceso volvió al juzgado de conocimiento y sigue en curso. ¿Opera la privación injusta? Hasta que no termine el proceso no se puede saber; mientras no haya una sentencia que absuelva (por duda, por prescripción, porque no cometió el delito o por cualquier razón) o su equivalente, todavía no hay antijuridicidad del daño. Que se haya retrotraído el proceso no

convierte la privación en injusta: hay que esperar la sentencia, porque la persona podría ser condenada.

c) Unificación de 2006: responsabilidad objetiva en todos los casos. La sentencia del Consejo de Estado (Sección Tercera) del 4 de diciembre de 2006 dijo que en todos los casos de privación injusta, incluidos los de *in dubio pro reo* o cualquier otra razón, la responsabilidad es objetiva y se fundamenta en el daño especial: la mayor ruptura del equilibrio ante las cargas públicas es dejar a una persona privada de la libertad, independientemente de que la providencia que impuso la medida de aseguramiento sea o no legal. Esta tesis se aplicó hasta 2018.

d) Unificación de 2018: regreso a la tesis anterior (CE, S3, 15 de agosto de 2018). El Consejo de Estado volvió a aplicar la responsabilidad objetiva solo cuando el hecho no existió, la conducta es atípica o el sindicado no la cometió; en los demás casos hay que probar la falla del servicio. Hubo dos razones de fondo:

- La primera, «que obviamente no está escrita en la sentencia»: pasó lo mismo que con el daño antijurídico; se empezó a decir que cualquier persona absuelta obtenía automáticamente su indemnización y que eso quebraba al Estado («ya se nos fue la mano»).
- La segunda: casos en los que el juez de la reparación directa no estaba convencido de la inocencia de quien fue absuelto («a mí no me suena que sea tan inocente»; «creo que no se estudiaron bien las pruebas»), de modo que el juez de reparación directa vuelve a estudiar la conducta de quien fue declarado inocente en el proceso penal.

EJEMPLO. El caso de la unificación de 2018: trata de personas. Un señor tenía un apartamento que, al parecer, se usaba como «puente» en una red de trata de personas: las víctimas se alojaban allí una noche antes de ir a Bogotá y viajar al exterior. Fue absuelto por duda, porque nunca se demostró si sabía o no que esas personas iban a ser víctimas de trata. Como fue absuelto por duda, el demandante debía probar la ilegalidad de la medida de aseguramiento y no la probó; el Consejo de Estado pudo haber cerrado ahí la discusión. Pero, además, se metió en el problema de la culpa exclusiva de la víctima: dijo que había culpa exclusiva porque el señor no fue lo suficientemente cuidadoso al determinar a quién le prestaba el apartamento y sus conductas no fueron del todo adecuadas al ordenamiento.

La línea del tiempo. Para entender el problema hay que tener clarísima esta línea: (1) ocurren unos hechos, que son el objeto de la investigación penal (los hechos «delictivos»); (2) inicia la investigación penal; (3) se dicta la decisión absolutoria. La absolución abarca realmente esos hechos: el juez penal absuelve porque lo que pasó le parece irrelevante penalmente o porque no se llegó a una conclusión certera. El problema surge cuando el juez de la reparación directa vuelve sobre esos mismos hechos para encontrar una culpa de la víctima.

EJEMPLO. El Airbnb. Usted es dueño de un apartamento que alquila por Airbnb en Medellín y alguien lo usa para cometer actos sexuales con una menor. Se inicia un proceso penal contra el agresor y contra el dueño del apartamento, a quien se absuelve por duda porque no hay pruebas. ¿Cómo podía saber el dueño? Según el razonamiento de la sentencia, se le negaría la indemnización por no haber sido lo suficientemente cuidadoso para saber que los huéspedes usaban el apartamento para esos fines.

COMENTARIO. Duda e inocencia. La ausencia de pruebas no es duda, sino inocencia: si no se demostró nada que permitiera concluir que la persona sabía, debe absolverse por inocencia. Sin embargo, en la práctica la Fiscalía, casi siempre por instrucciones y directrices internas, pide absolver por duda, precisamente para evitar las demandas contra el Estado.

e) La Corte Constitucional (SU-072 de 2018). Meses después, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación, dijo que en privación injusta de la libertad hay *iura novit curia*: cada juez decide el título de imputación que considera procedente. Pero agregó que realmente solo hay dos casos en los que debería aplicarse la responsabilidad objetiva, ni siquiera tres: cuando el hecho no existió y cuando la conducta es atípica.

Sobre el régimen aplicable y la culpa exclusiva de la víctima son relevantes también: CE, S3, Subsección B, sentencia del 15 de noviembre de 2019, y Corte Constitucional, Sentencia SU-363 de 2021.

7.3.3 Perjuicios en la privación injusta de la libertad

Las sentencias de unificación aplicables son:

- CE, S3, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014.
- CE, S3, sentencia de unificación del 18 de junio de 2019 (perjuicios materiales).
- CE, S3, sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021 (perjuicios morales; ver Capítulo 4, sección 4.9.10).

7.4 Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia

Ley 270 de 1996, art. 69: «Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación.»

Comprende los daños causados por acciones u omisiones de los agentes judiciales que no son causados por una providencia judicial: mora judicial, ejecución de medidas cautelares, notificaciones indebidas, remates judiciales.

EJEMPLO. Un ejemplo es el caso del vehículo secuestrado en un proceso ejecutivo que fue robado del parqueadero y atropelló a un ciclista: se demandó al Estado por defectuoso funcionamiento, porque el secuestro tenía la custodia del vehículo (ver Capítulo 5, prohibición de regreso). También el del vehículo devuelto desvalijado tras el embargo (ver Capítulo 4).

7.5 Responsabilidad por el hecho del legislador y del constituyente

7.5.1 De la irresponsabilidad al daño especial

- La tesis inicial era la irresponsabilidad, basada en el carácter general de la ley.
- **Fallo La Fleurette (Consejo de Estado francés, 14 de enero de 1938):** rompimiento del equilibrio ante las cargas públicas.

EJEMPLO. La Fleurette. En Francia, en 1938, el legislador expide una ley que prohíbe la producción, comercialización y exportación de ciertos productos lácteos para proteger la industria nacional. La Fleurette era la única empresa que producía y comercializaba ese producto: una ley general, abstracta e impersonal que en realidad solo afectaba a una empresa. La Fleurette demandó al Estado sin cuestionar la ley («la ley está muy bien»), pero alegó un daño especial: una ley impersonal y general solo la afectaba a ella, lo que rompía el equilibrio ante las cargas públicas. A partir de este caso se acepta en Francia la responsabilidad por el hecho del legislador.

Requisito: debe haber una ley válida que genere un daño especial.

7.5.2 El hecho del constituyente: irresponsabilidad (CE, S-470, 13 de diciembre de 1995)

EJEMPLO. Con la Constitución de 1991 se convocaron nuevas elecciones y a los congresistas que venían ejerciendo se les recortó el período. Demandaron al Estado. El Consejo de Estado dijo en 1995 que no hay responsabilidad por el hecho del constituyente: la Constitución es un acto tan general que su expedición no puede generar daño.

7.5.3 El hecho del legislador: daño especial (CE, IJ-001, 25 de agosto de 1998)

EJEMPLO. La inmunidad de los agentes diplomáticos. Un agente diplomático de la embajada de Estados Unidos atropella a un peatón. El peatón no puede demandarlo porque el diplomático tiene inmunidad de jurisdicción en materia civil, en virtud de la Convención de Viena, incorporada al ordenamiento colombiano mediante una ley. La solución: demandar al Estado por el hecho del legislador. La aprobación de la Convención de Viena es constitucionalmente válida e impecable, pero genera una ruptura del equilibrio ante las cargas públicas: un daño especial, porque la víctima se quedó sin poder demandar. Por primera vez en Colombia se condenó al Estado por el hecho del legislador. Se reconocen los perjuicios del caso (daño emergente, lucro cesante, etc.).

7.5.4 Daño causado por una ley declarada inexecutable

Sería el equivalente a la falla del servicio por el hecho del legislador. Ocurre especialmente en materia tributaria: ¿qué pasa si se paga un impuesto y luego la ley que lo creó es declarada inconstitucional? Depende de los efectos de la declaratoria de inexecutable. La regla general es que, si la Corte no señala nada sobre los efectos del fallo, estos son hacia el futuro: la ley se entiende válida hasta la sentencia.

Supuesto	Consecuencia
Inexecutableidad con efectos hacia el futuro	No hay daño antijurídico: cuando se hizo el pago, la ley era válida; había un título jurídico válido que imponía el deber de pagar (es un pago de lo debido).
Inexecutableidad con efectos retroactivos y con orden de la Corte sobre los efectos producidos	No hay daño antijurídico (no hay daño).

Supuesto	Consecuencia
Inexequibilidad con efectos retroactivos sin orden de la Corte sobre los efectos producidos	Hay que provocar un pronunciamiento de la Administración.

EJEMPLO. Pago después de la sentencia. Si alguien paga cuando ya todo el mundo sabe que la ley fue declarada inexecutable, hay un pago de lo no debido (y cierta culpa de quien paga). Si quien paga no se entera del fallo, lo usual es que se liquide el impuesto y se expida la factura correspondiente; si se paga después del fallo, es un problema de los efectos en el tiempo.

EJEMPLO. La reforma tributaria declarada inexecutable. En el gobierno de Duque se presentó una reforma tributaria que eliminó unas exenciones que favorecían a quienes trabajaban en la Rama Judicial, por lo que esos servidores tuvieron que pagar más en su declaración de renta. Tres o cuatro meses después, la Corte Constitucional declaró inexecutable la reforma, pero se pronunció expresamente sobre los efectos: lo pagado se tendría como saldo a favor en las siguientes declaraciones de renta. No hay responsabilidad, porque no hay daño. En los últimos fallos tributarios, la Corte suele pronunciarse expresamente sobre los efectos para evitar demandas contra el Estado.

El caso problemático: efectos retroactivos sin orden sobre lo pagado. El Consejo de Estado ya unificó la materia: no es un problema de responsabilidad extracontractual. Quien pagó debe provocar un acto administrativo ante la DIAN, porque el Estatuto Tributario tiene procedimientos administrativos para reclamar la devolución. Si la DIAN no devuelve el dinero, se demanda ese acto administrativo ilegal, no por la vía de la reparación directa, sino por la de nulidad y restablecimiento del derecho.

7.6 El favorecimiento de la víctima (*favor victimae*)

7.6.1 La tensión de origen: el Fallo Blanco

«(...) Que dicha responsabilidad no es ni general ni absoluta; que se rige por normas especiales que varían en función de las necesidades del servicio y de la necesidad de conciliar los derechos del Estado con los derechos privados; (...)» (Tribunal de Conflictos, 8 de febrero de 1873)

Tensión entre:

- Las necesidades del servicio (Estado prestador de servicios públicos).
- Los derechos privados (de las víctimas).

7.6.2 Manifestaciones sustanciales del *favor victimae*

- Surgimiento de regímenes objetivos de responsabilidad (industrialización / daño antijurídico).
- Solidaridad del artículo 2344 del C.C.
- Proliferación de tipologías de perjuicios para romper los baremos jurisprudenciales.

7.6.3 Aplicaciones procesales del *favor victimae*: la caducidad

- Ocurrencia del daño (desde la Ley 167 de 1941: daños por obras públicas).
- Regla especial para la desaparición forzada (Ley 589 de 2002): aparición de la víctima / fallo penal.
- Conocimiento del daño (jurisprudencia / CPACA).

Corte Constitucional, SU-254 de 2013: «los términos de caducidad para población desplazada, en cuanto hace referencia a futuros procesos judiciales ante la jurisdicción contencioso administrativa, sólo pueden computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en cuenta trascurros de tiempo anteriores, por tratarse, como antes se explicó, de sujetos de especial protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta».

Consejo de Estado, Sección Tercera, SU 61033 del 29 de enero de 2020: inaplicación «cuando [se] advierta que la no comparecencia ante la administración de justicia se encuentra justificada por razones materiales, pues el paso del tiempo no puede empezar a correr contra quien no goza del acceso efectivo a la administración de justicia, lo cual, se insiste, depende de las circunstancias especiales de cada sujeto».

7.6.4 Aplicaciones procesales del *favor victimae*: las pruebas

- Regímenes de falla presunta del servicio (falla médica hasta antes de 2006).
- Carga dinámica de la prueba.
- Presunción de perjuicios morales derivada del parentesco.
- Presunción de ingresos equivalentes al salario mínimo.
- «Flexibilización» probatoria en casos de graves violaciones de derechos humanos.

COMENTARIO. Varias de estas aplicaciones son objeto de crítica: la flexibilización de la caducidad en casos de derechos humanos y de desplazamiento (Capítulo 4, sección 4.3), la presunción del parentesco y del salario mínimo (Capítulo 4) y la flexibilización probatoria por el «contexto de orden público» en actos terroristas (Capítulo 6, sección 6.4.4).

7.6.5 Reflexiones: ¿quién debe crear las reglas?

- **Reglas sustantivas:** el favorecimiento de la víctima en la responsabilidad extracontractual del Estado es una política pública que tiene incidencia en el presupuesto estatal.
- **Reglas procesales:** poder de configuración legislativa (art. 150-2 de la C.P.) / intervención residual del juez ante lagunas o antinomias normativas.

Tensión entre el legislador y el juez.

7.6.6 ¿Es válida la aplicación judicial del *favor victimae* en materia procesal?

- Principio de igualdad de partes (paridad de oportunidades o igualdad de armas) / función igualadora del proceso.

- Principio de imparcialidad (ausencia de prejuicios).
- Argumento retórico sin implicaciones prácticas.
- Interpretaciones judiciales *contra legem*.

7.6.7 Reflexión final

«(...) Si [bien] el criterio para distinguir lo justo de lo injusto es necesariamente ambiguo, quien está con la víctima no se equivoca nunca (...)» (Daniele Giglioli, *Crítica de la víctima*)

7.7 Responsabilidad precontractual

Eventos:

- Revocatoria del acto de apertura del procedimiento de selección.
- Revocatoria del acto de adjudicación, antes de la celebración del contrato.
- Ilegalidad de la adjudicación del contrato (sin celebración del contrato) o del acto que declara desierto el procedimiento de selección.
- Abstención de celebración del contrato, luego de su adjudicación.

Fundamentos:

- Principio de legalidad (art. 6 de la C.P.).
- Principio de buena fe (art. 83 de la C.P.).
- Culpa *in contrahendo* (art. 863 del C.Co.).
- Inaplicabilidad de otros fundamentos del Código Civil y del Código de Comercio.

Perjuicios:

- **Interés positivo:** la utilidad prevista en la propuesta.
- **Interés negativo:** es excluyente (los gastos en los que se incurre para la presentación de la propuesta deben ser asumidos por el contratista para efectos de obtener la utilidad).

7.8 Responsabilidad contractual: la existencia del contrato

- El contrato estatal es solemne (art. 41 de la Ley 80 de 1993).
- Excepción: contratación de mínima cuantía (oferta + aceptación de la oferta = contrato estatal) (art. 2 de la Ley 1150 de 2007).
- Controversia: los hechos cumplidos.

7.8.1 Sentencia de unificación de 2012

Eventos en los que es admisible reclamar la compensación del enriquecimiento sin causa, «entre otros»:

- Constreñimiento de la entidad estatal.
- Prestación de un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud.
- Omisión de declaratoria de urgencia manifiesta.

Nota I: en los demás eventos es inadmisibile, por inexistencia de buena fe objetiva.

Nota II: problema procesal / reparación directa.

7.8.2 Sentencia de unificación de 2025

- Demostración, por parte del interesado, del acaecimiento de una circunstancia extraordinaria, sustentada en razones de interés general:
 - Análisis de la gravedad y urgencia en la continuidad de un servicio.
 - La excepcionalidad no puede ser empleada como excusa para el desconocimiento de las normas del EGCAP.
- No depende de causas taxativas.
- Conducta de las partes.
- Constreñimiento → rectificación: responsabilidad extracontractual por falla del servicio.

COMENTARIO. Una condena por un «hecho cumplido» (por ejemplo, un kilómetro de carretera construido y no pagado al contratista) o por desequilibrio no es indemnizatoria sino reparatoria (ver Capítulo 10).

Capítulo 8

La reparación directa como vía procesal para reclamar la responsabilidad extracontractual del Estado

8.1 El medio de control de reparación directa (art. 140 de la Ley 1437 de 2011)

Finalidad: la reparación del daño antijurídico.

Admite tres esquemas de partes:

Demandante	Demandado
Persona interesada	Entidad pública causante del daño
Entidad pública perjudicada	Particular / entidad causante del daño
Persona interesada	Particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de una entidad pública

COMENTARIO. Sobre el alcance de la expresión «particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción» y su interpretación en la sentencia C-644 de 2011, así como sobre el último inciso del art. 140 (proporción de responsabilidad cuando concurren particulares y entidades públicas), ver Capítulo 5, secciones 5.10 y 5.11.4.

8.2 Fuente del daño

- Hecho administrativo.
- Omisión administrativa.
- Operación administrativa.
- Ocupación temporal o permanente de inmuebles por obras públicas.
- Otras causas imputables a entidades públicas o a particulares que obren siguiendo instrucciones de entidades públicas.

8.3 ¿Qué se puede pedir?

- Reparación de daños antijurídicos de origen extracontractual.
- Responsabilidad precontractual.
- *Actio in rem verso*.
- Daño al patrimonio público por actos de corrupción.

8.4 Legitimación en la causa por activa

- El particular con interés.
- Las entidades públicas perjudicadas.

COMENTARIO. Sobre la legitimación de las víctimas directas e indirectas, la reclamación *iure proprio* o *iure hereditario* y la legitimación del propietario, poseedor o tenedor en los daños a las cosas, ver Capítulo 4, secciones 4.4 y 4.5.3.

8.5 Caducidad

- Dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño.
- Dos (2) años contados a partir de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo, si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
- Delito de desaparición forzada: dos (2) años contados a partir de la fecha en que aparezca la víctima o, en su defecto, desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición.
- Daños causados por la comisión de delitos de lesa humanidad: sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, expediente 61033.

COMENTARIO. El desarrollo de estas reglas (el conocimiento del daño y la carga de invocarlo desde la demanda, los casos prácticos, la caducidad en lesa humanidad y el debate sobre el desplazamiento forzado) está en el Capítulo 4, sección 4.3. Las reglas de caducidad en el error judicial cuando se interpuso tutela están en el Capítulo 7, sección 7.2.3.

8.6 Otras reglas procesales relevantes

- **Fuero de atracción:** cuando el daño es causado por el Estado y por un particular, se puede demandar a ambos ante la jurisdicción contenciosa, que conoce de la responsabilidad de los dos (Capítulo 5, sección 5.6.1).
- **Estimación razonable de la cuantía:** es requisito de la demanda (art. 162 del CPACA); es el primer momento en que se cuantifican los perjuicios (Capítulo 4, sección 4.7.2).

- **Condena en abstracto e incidente de liquidación:** cuando se prueba el daño pero no la cuantía del perjuicio (Capítulo 4, sección 4.5.1).
- **Prueba sobreviniente:** por ejemplo, el dictamen de la Junta Médico Laboral expedido durante el proceso (Capítulo 4, sección 4.5.1).
- **Costas:** si se pierde el proceso, la condena en costas es proporcional a la cuantía de los perjuicios reclamados (Capítulo 4, sección 4.9.6).
- **Dictamen pericial:** necesario, por regla general, en responsabilidad médica (Capítulo 5, sección 5.6.2).

Capítulo 9

La desnaturalización de la responsabilidad extracontractual del Estado en la Ley 2195 de 2022

9.1 Introducción: el flagelo de la corrupción

- Uno de los principales males que acecha a Colombia.
- El impacto de la corrupción en el patrimonio público.
- Necesidad de instrumentos jurídicos para combatirla.
- ¿Excesivo fetichismo legal?

9.2 La reparación directa antes y después de la Ley 2195

9.2.1 Art. 140 de la Ley 1437 de 2011

Finalidad: reparación del daño antijurídico.

Demandante	Demandado
Persona interesada	Entidad pública causante del daño
Entidad pública perjudicada	Particular / entidad causante del daño
Persona interesada	Entidad pública por hechos de particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de una entidad pública

9.2.2 Reformas del medio de control de reparación directa en la Ley 2195 (arts. 59 y 61)

Demandante	Demandado
Entidad pública lesionada / Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Particular que ejerce función administrativa / servidor público causante del daño

- **Finalidad:** reparación del daño al patrimonio público causado por un acto de corrupción (responsabilidad extracontractual derivada del delito).

- Imposición de multas al responsable del acto de corrupción en la sentencia declaratoria de responsabilidad, por hasta 1.000 SMLMV, según la gravedad de la conducta.

9.3 Responsabilidad extracontractual derivada del delito

«Artículo 1494. Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia.» (Código Civil)

9.4 Exposición de motivos: la supuesta insuficiencia de los mecanismos existentes

«Aunque el incidente de reparación integral y el procedimiento administrativo de responsabilidad fiscal tienen fines reparatorios, al igual que la acción de reparación directa que se propone, lo cierto es que no son suficientes para los propósitos del proyecto de ley por varias razones: i) existe una limitación en el reclamo de perjuicios, estos procesos se circunscriben exclusivamente a la solicitud de perjuicios materiales derivados del detrimento patrimonial, lo cual no permitiría reclamar otro tipo de perjuicios, por ejemplo, no se podría reclamar el daño al buen nombre "good will" del Estado; ii) no es claro que se puedan solicitar medidas de reparación no pecuniarias, como de satisfacción, por ejemplo unas excusas públicas o que se realicen medidas por parte del responsable para renovar la confianza entre la sociedad y la administración pública; iii) la responsabilidad fiscal es exclusiva de los servidores públicos y particulares que ejerzan función fiscal; iv) para que se dé el incidente de reparación en materia penal es necesario que se pruebe la responsabilidad penal del investigado; la acción de reparación directa propuesta solo exige que se pruebe el daño y que este haya ocurrido con ocasión de un acto de corrupción.»

9.5 Reparación del daño e insuficiencia de los instrumentos existentes

«El daño al patrimonio público puede ser resarcido a través de medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias.»

- Art. 94 de la Ley 599 de 2000: «La conducta punible origina obligación de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquella». Sentencia C-344 de 2017: «en el entendido de que las categorías de perjuicios allí indicadas (...) no excluyen la reparación integral de todos los perjuicios tanto materiales, como inmateriales, que hayan sido causados a las víctimas como consecuencia del delito y resulten debidamente probados».
- CSJ, Sala Penal, sentencia del 3 de mayo de 2017, Exp. 36784, M. P. Fernando Alberto Castro Caballero.
- Medidas no pecuniarias: ¿era necesario crear una nueva acción para este tipo de medidas?

9.6 Reparación de perjuicios

«El juez deberá tener en cuenta para la tasación de los perjuicios el impacto en la sociedad del acto de corrupción.»

- Función de la responsabilidad extracontractual: reparar el daño, todo el daño y nada más que el daño.
- ¿Reducción de la indemnización por impacto a la sociedad?
- ¿Incremento de la indemnización (daños punitivos) por impacto a la sociedad?

9.7 ¿Qué es un acto de corrupción y cómo se determina su ocurrencia?

«PARÁGRAFO 1o. Entiéndase por acto de corrupción las conductas penales enlistadas en los capítulos de delitos contra la administración pública, el medio ambiente, el orden económico y social, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, los consagrados en la Ley 1474 de 2011, los delitos electorales o cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio público, que hubieren sido realizados.»

- ¿Debe hacer el juez de la reparación un juicio de adecuación típica? ¿Además debe estudiar la antijuridicidad y la culpabilidad de la conducta?
- ¿Existe prejudicialidad respecto del proceso penal?

9.8 *Non bis in idem*

«PARÁGRAFO 2o. El pago que haya realizado el demandado en desarrollo de otro proceso judicial o fiscal de responsabilidad por los hechos de corrupción objeto del medio de control de reparación directa, se descontará del monto de la condena del proceso de reparación directa. De igual manera, en los otros procesos de responsabilidad en los cuales el demandado deba realizar un pago por el daño causado al patrimonio público, se descontará la suma reconocida y pagada en la sentencia de reparación directa.»

- ¿Realmente era necesario crear un nuevo instrumento procesal para ejercer pretensiones que se pueden perseguir a través de otros?

9.9 Caducidad

«PARÁGRAFO 3o. El término para formular la pretensión de reparación directa derivada de un acto de corrupción se contará a partir del día siguiente de la fecha en que la entidad pública afectada tuvo o debió tener conocimiento de este, o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal.»

- Dos extremos iniciales concurrentes para contar el término de caducidad (subjetivo / objetivo).
- ¿Aplicación de la teoría del conocimiento del daño para personas jurídicas?

Puede representarse con dos líneas de tiempo:

Línea de tiempo	Extremo inicial	Extremo final
Primera	Acción u omisión causante del daño	Conocimiento del daño
Segunda	Conocimiento del daño	Ejecutoria del fallo penal

9.10 Imposición de multas (art. 61)

«PARÁGRAFO. Cuando la sentencia sea declaratoria de responsabilidad en los medios de control de reparación directa y controversias contractuales y el daño haya sido causado por un acto de corrupción, el juez deberá imponer, adicional al daño probado en el proceso, multa al responsable hasta de mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual atenderá a la gravedad de la conducta, el grado de participación del demandado y su capacidad económica. El pago de la multa impuesta deberá dirigirse al Fondo de Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción. En la sentencia se deberán decretar las medidas cautelares que garanticen el pago de la sanción.»

- ¿Desnaturalización del medio de control de reparación directa?
- ¿Vinculación del agente responsable y garantía del debido proceso?
- ¿Otros medios de control distintos a la reparación directa y a las controversias contractuales?

9.11 Problemas prácticos del *non bis in idem* entre la reparación directa y el proceso de responsabilidad fiscal

- ¿La sentencia absolutoria en el proceso de reparación directa hace tránsito a cosa juzgada en el proceso de responsabilidad fiscal? Depende del fundamento de la absolución: el demandado no lo cometió / inexistencia del hecho / inexistencia del acto de corrupción (problema de tipicidad).
- ¿Puede existir diferencia en la tasación de perjuicios entre el proceso de reparación directa y el proceso de responsabilidad fiscal?

Proceso	Objeto
Reparación directa	Reparación integral del daño al patrimonio público causado por acto de corrupción (art. 59 de la Ley 2195)
Proceso de responsabilidad fiscal	Resarcimiento del daño ocasionado al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quien realiza gestión fiscal, mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la entidad estatal (art. 4 de la Ley 610)

9.12 Función de la responsabilidad extracontractual del Estado

Fundamento	Función
Falla del servicio	Función demarcatoria
Daño antijurídico	Función indemnizatoria
Incremento de perjuicios por acto de corrupción	Función sancionatoria

9.13 Conclusiones

- El populismo punitivo en la lucha contra la corrupción.
- Suficiencia de los mecanismos existentes.
- Inconsistencia de las modificaciones al medio de control de reparación directa creadas en la Ley 2195.
- Desnaturalización del juicio de responsabilidad extracontractual / confusión con el juicio de responsabilidad penal.

Capítulo 10

La responsabilidad patrimonial del agente estatal: la acción de repetición

10.1 Normas relevantes anteriores a la Constitución (Código Contencioso Administrativo)

Art. 77 del CCA: «Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la Nación y a las entidades territoriales o descentralizadas, o a las privadas que cumplan funciones públicas, los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones.»

Art. 78 del CCA: «Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere.»

Art. 86 del CCA: «(...) Las entidades públicas deberán promover la misma acción [reparación directa] cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo (...).»

Art. 136-9 del CCA (caducidad): «La de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad.»

Sentencia C-832 de 2001: «a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo».

10.2 La Constitución de 1991

10.2.1 La ponencia del artículo 90

«(...) Finalmente, he estimado de suma utilidad acoger dos planteamientos contenidos en algunos proyectos: el de que, para proteger a las víctimas, se les permita

demandar indistintamente al Estado o a la autoridad pública involucrada; y el de que, para proteger el patrimonio público y combatir la indolencia personal del grueso de los funcionarios públicos, se le imponga al Estado el deber de repetir contra el funcionario culpable por las sumas por las que aquél hubiera sido condenado. (...)» (Gaceta Constitucional No. 56, p. 14)

Se distinguen así la responsabilidad patrimonial de la entidad estatal y la responsabilidad patrimonial del agente estatal.

«(...) El delegatario Ramírez Ocampo (...) insiste en reducir el artículo, agrega que la repetición contra el funcionario va a conducir a que no haya quien acepte desempeñar cargos públicos, el constituyente Uribe Vargas se muestra de acuerdo. (...)» (Gaceta Constitucional No. 132, p. 19)

De allí surge la culpa grave o el dolo como limitación para repetir.

10.2.2 El artículo 90 de la Constitución

«ARTÍCULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.»

El artículo 90 tiene dos incisos: el primero regula la responsabilidad patrimonial del Estado; el segundo, la responsabilidad patrimonial del agente, es decir, la acción de repetición.

10.3 Limitaciones constitucionales para el ejercicio de la acción de repetición

Del segundo inciso del artículo 90 se desprenden tres limitaciones (garantías) para exigir la responsabilidad patrimonial del agente: dos procesales y una sustancial.

10.3.1 Primera limitación (procesal): la condena previa contra el Estado

Para que pueda iniciarse la acción de repetición, tiene que haber una condena previa contra el Estado, porque el artículo 90 dice que el Estado repetirá cuando haya sido condenado.

EJEMPLO. María Victoria, empleada pública del Ministerio de Trabajo, expide actos administrativos (por ejemplo, impone multas por incumplimiento de normas laborales). Tiene una garantía: mientras no se condene al Ministerio de Trabajo, su patrimonio está a salvo; no hay forma de demandarla a ella hasta que exista esa condena. Primero tiene que haber un demandante que demande al Estado y, en ese proceso, una condena. María Victoria no es parte en ese primer proceso: a quien condenan es al Estado.

La condena debe ser indemnizatoria (no restitutoria). No basta cualquier condena: tiene que ser una condena a reparar un daño antijurídico. Si la condena es restitutoria, la acción de repetición es improcedente.

EJEMPLO. Caracol, RCN y la ANTV (caso real). Caracol y RCN tenían un contrato de concesión con el Estado y la obligación contractual de transmitir a las siete de la noche un contenido del Ministerio de Cultura; no lo hicieron. La Autoridad Nacional de Televisión (entidad concedente) les impuso a cada uno una multa contractual de 500 millones de pesos, que pagaron. Demandaron ante un tribunal de arbitramento, que anuló parcialmente la multa: sí había que multarlos, pero el tope permitido era de 200 millones. En consecuencia, el tribunal impuso una condena restitutoria: la ANTV debía devolver 300 millones. La ANTV repitió contra los tres comisionados que firmaron el acto. El Consejo de Estado dijo que la acción era improcedente, porque la condena era restitutoria: si se les cobra a los comisionados, se genera un enriquecimiento para la entidad, que nunca tuvo derecho a esos 300 millones (era un pago en exceso que debía devolver).

EJEMPLO. El hecho cumplido en obra pública. Un contratista construyó un kilómetro de carretera que nunca le pagaron; demanda y la entidad es condenada a pagarle 100 millones. La entidad no puede repetir contra el funcionario que no reconoció esa suma, porque de todos modos tenía que pagarla: una condena por desequilibrio no es indemnizatoria, sino restitutoria; es algo que se habría tenido que pagar en todo caso.

10.3.2 Segunda limitación (procesal): la legitimación en la causa por activa

María Victoria sabe que la única que puede demandarla es la entidad condenada (el Ministerio de Trabajo). El demandante del primer proceso no puede ir contra ella: quien repite es el Estado, por lo que fue condenado.

10.3.3 Tercera limitación (sustancial): la culpabilidad del agente

La acción de repetición se activa por la culpa grave o el dolo del agente estatal. Y aquí es esencial distinguir entre **culpa** y **culpabilidad**.

DEFINICIÓN. **Dolo**: la intención de lesionar a alguien.

DEFINICIÓN. **Culpa grave**: una negligencia tan grande, tan abrupta, que se asemeja al dolo.

EJEMPLO. María Victoria impone una multa después de un estudio juicioso de la jurisprudencia, pero no sabía que tres días antes la Corte Constitucional había expedido una sentencia que cambió la posición. La persona multada demanda, gana el proceso de nulidad y restablecimiento y condenan al Ministerio. Eso es culpa, no culpabilidad. Igual si había dos posiciones jurisprudenciales (una de la Subsección A y otra de la Subsección B), María Victoria acogió la que más la convenía y el juez acogió la otra: haber escogido una en lugar de la otra es culpa; de ninguna forma es culpabilidad. Es una garantía de la agente: solo se repite por dolo o culpa grave.

10.4 El esquema constitucional

- **Proceso 1:** la víctima demanda a la entidad causante del daño; condena indemnizatoria (no restitutoria).
- **Proceso 2:** la entidad condenada demanda al agente.

Reglas probatorias:

- **Carga de la prueba:** la entidad condenada tiene la carga de probar la culpabilidad del agente.
- **Inoponibilidad:** la sentencia condenatoria y las pruebas practicadas en el primer proceso no son oponibles al agente demandado.
- **Juicio de culpabilidad en concreto vs. culpa en abstracto.**

EJEMPLO. El falso positivo grabado (ejemplo inventado). El Ejército es condenado en reparación directa por la ejecución de Pedro en un falso positivo. En la sentencia se dice que la falla del servicio está probada con un video (que obra en el expediente) en el que se ve a los soldados amarrar a Pedro en un callejón y ejecutarlo, para luego presentarlo como guerrillero muerto en combate. El Ejército inicia la acción de repetición contra los tres soldados del video y aporta únicamente la sentencia de reparación directa. ¿Es suficiente? No: como los tres soldados no fueron parte del proceso de reparación directa, nada de lo que allí se hizo les es oponible; no pudieron ejercer defensa ni contradicción. Antes de la Ley 678, las entidades buscaban condenas en repetición con la sola sentencia condenatoria, y la jurisprudencia dijo por mucho tiempo que no era suficiente. ¿Qué debió hacer el Ejército? Pedir el traslado de la prueba (el video) al proceso de repetición, para que los agentes pudieran controvertirla.

10.4.1 ¿Cómo se defiende el agente estatal?

- **Primera defensa: desvirtuar su culpabilidad:** demostrar que no actuó con dolo ni culpa grave.
- **Segunda defensa: cuestionar la responsabilidad misma del Estado.** Como la sentencia del primer proceso no le es oponible, el agente puede discutir en la repetición incluso la responsabilidad del Estado.

EJEMPLO. John Jairo, conductor de un vehículo del Estado. Según la sentencia de reparación directa, John Jairo atropelló a la víctima y el Estado fue condenado. En la repetición, John Jairo puede alegar que en realidad hubo un hecho de un tercero (otra persona atropelló a la víctima) o un hecho de la víctima: si en el sector había una cámara de semáforo cuyo video muestra claramente que quien atropelló fue otro civil, y el Estado se defendió mal y no pidió ese video, la mala defensa del Estado no lo vincula. Eso no afecta la indemnización de la víctima, porque esa sentencia hizo tránsito a cosa juzgada; solo afecta la responsabilidad patrimonial del agente.

COMENTARIO. Precisiones. ¿Qué pasa cuando varios funcionarios participaron (quien proyecta, el coordinador, la segunda instancia)? La responsabilidad es subjetiva e individual; el problema usual de las acciones de repetición es que se dirigen solo contra quien firmó. Si se demanda solo al ministro por un acto ilegal, él dirá que no es abogado y que confió en el secretario general, el jurídico o el asesor, y probablemente el Consejo de Estado le dará la razón: hay que ver quién actuó con culpabilidad, es decir, quién, según las circunstancias internas, tenía el conocimiento jurídico, sabía o fue advertido. ¿Qué pasa si la entidad defendió en el proceso que el acto era legal y luego repite contra la funcionaria? No hay problema, porque si la sentencia declaró ilegal el acto, la entidad puede luego repetir. Además, las condenas que dan lugar a

repetición pueden provenir de cualquier tipo de proceso (controversias contractuales, nulidad y restablecimiento, reparación directa), no solo de la reparación directa.

10.5 La Ley 678 de 2001

La Ley 678 introdujo dos cambios importantes: el llamamiento en garantía con fines de repetición y las presunciones de culpa grave y dolo.

10.5.1 El llamamiento en garantía con fines de repetición

- **Proceso 1:** la víctima demanda a la entidad causante del daño.
- **Proceso 1:** la entidad demandada llama en garantía al agente.

Además del esquema del artículo 90 (víctima contra el Estado y luego Estado contra el agente), la entidad puede, en el mismo proceso de la víctima contra el Estado, llamar en garantía a María Victoria. En la sentencia se estudia primero la responsabilidad del Estado y luego si está probada la culpabilidad de la agente; si lo está, se dirá que lo que pague el Estado deberá ser reintegrado por ella.

Implicaciones procesales:

- Quien paga la condena a la víctima sigue siendo la entidad estatal; luego la agente reintegra. El llamamiento no altera ni modifica las relaciones procesales: es una acumulación de pretensiones que da economía procesal, porque se resuelven ambas relaciones en un solo proceso.
- El agente llamado en garantía puede cuestionar la responsabilidad de la entidad o su responsabilidad personal.
- **Limitación en las excepciones que puede formular la entidad demandada (art. 19):** si la entidad llama en garantía al agente, no puede alegar al mismo tiempo la causa extraña. Si alega la causa extraña, dice que no causó el daño; si llama en garantía, reconoce que causó el daño y busca que el agente le reintegre. Las dos posiciones son contradictorias, y formularlas de manera subsidiaria tampoco tiene lógica: se pierde por completo el argumento.

EJEMPLO. En el caso del accidente de tránsito, el municipio de Bucaramanga no puede decir a la vez «fue John Jairo, que iba manejando» y «fue la víctima, que se atravesó». Como dice la expresión popular, no se puede ser «cura y pandillero» al tiempo: hay que escoger.

10.5.2 Las presunciones de culpa grave y dolo

DEFINICIÓN. Presunción: técnica probatoria con un hecho base y un hecho presumido (hecho indicado), unidos por una inferencia lógica. Si se prueba el hecho base, se tiene por acreditado el hecho presumido.

Presunciones de dolo (Ley 678 de 2001):

- 1. Obrar con desviación de poder.
- 2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.

- 3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.
- 4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.
- 5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.

Presunciones de culpa grave (Ley 678 de 2001):

- 1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.
- 2. Carencia o abuso de competencia para proferir la decisión anulada, determinada por error inexcusable.
- 3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos, determinada por error inexcusable.
- 4. Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal.

Efecto e implicaciones procesales:

- **Efecto:** inversión de la carga de la prueba. Si se prueba el hecho base, ya no le corresponde a la entidad demostrar la culpa, sino al agente demostrar que no hubo culpa grave o dolo.
- Estructura de las presunciones: hecho base / hecho indicado / inferencia lógica.
- La entidad condenada debe invocarlas expresamente en la demanda de repetición.
- La entidad condenada tiene que probar el hecho base.
- El agente demandado puede desvirtuar la presunción.

EJEMPLO. María Victoria y la multa a Ricardo. María Victoria le impone a Ricardo una multa de 100 millones por supuestamente incumplir normas laborales. Ricardo demanda la multa alegando falsa motivación y desviación de poder (no es cierto que haya violado esas normas; las pruebas del expediente administrativo lo demuestran; la verdadera razón fue que María Victoria le cogió rabia porque él no le prestó los apuntes de clase). Además de las pretensiones restitutorias, pide perjuicios: su prestigio se vio afectado, sus utilidades disminuyeron y sufrió perjuicios morales. El tribunal anula el acto por falsa motivación y desviación de poder y concede todas las pretensiones restitutorias e indemnizatorias. Luego, el Ministerio de Trabajo repite contra María Victoria con la sentencia de nulidad y restablecimiento como único elemento de juicio. Antes de la Ley 678, esa sentencia no era suficiente, porque no le es oponible. Con la Ley 678 sí lo es, porque demuestra el hecho base de la presunción: el acto se anuló por desviación de poder, y eso permite presumir el dolo. Si María Victoria no presenta pruebas, será condenada; pero puede desvirtuar la presunción (por ejemplo, probando que tenía una buena relación con Ricardo y que nunca hubo falsa motivación ni desviación de poder). Ahora ella tiene que hacer un esfuerzo probatorio, porque se invirtió la carga; antes, si la entidad no invocaba presunciones y solo traía la sentencia, la agente no necesitaba esforzarse.

¿Para qué se crearon las presunciones? Para facilitarle la vida a la entidad condenada: la mayoría de las veces las entidades perdían los procesos de repetición. La Ley 678 intentó ser «un salvavidas». Aun así, las entidades siguen perdiendo las repeticiones, y son muy pocas las condenas. Hay dos razones:

- **Los comités de conciliación no entienden la diferencia entre culpa y culpabilidad.** Demandan en casos como el de María Victoria que escogió una de dos posiciones jurisprudenciales, lo que no tiene sentido. Podría decirse que el 90 % de las repeticiones se fallan en contra de las entidades porque no prueban la culpabilidad.
- **Invocan presunciones cuyo hecho base la sentencia no prueba.** Las entidades invocaban siempre la presunción de «violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho». El juez de la repetición respondía que la sentencia anuló el acto por violación de normas (por ejemplo, por no aplicar la jurisprudencia de una subsección), pero en ninguna parte dijo que esa violación fuera manifiesta e inexcusable: no se probó el hecho base y la entidad perdía.

10.5.3 Otros aspectos procesales relevantes de la Ley 678 de 2001

- **Art. 8:** legitimación por activa en cabeza de la entidad condenada, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia.
- **Art. 11:** caducidad regulada en términos similares a los previstos en el art. 136-9 del CCA; caducidad para el pago en cuotas; C-394 de 2002: caducidad sometida al mismo condicionamiento de la C-832 de 2001.
- **Art. 23:** medidas cautelares: embargo y secuestro de bienes del agente demandado; inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro.

10.6 La Ley 2195 de 2022

La Ley 2195 introdujo muchos cambios en la repetición (ver la relación completa más adelante); dos de ellos merecen especial atención:

10.6.1 Eliminación de la limitación procesal para formular el llamamiento en garantía

Se eliminó la restricción del art. 19 de la Ley 678: ahora la entidad puede llamar en garantía al agente y, simultáneamente, alegar la causa extraña. El legislador pensó que hay que darle la lucha al Estado «con todas las armas, por todas las vías».

COMENTARIO. Valoración: es válido pensar así, pero no es coherente. Formular el llamamiento en esos términos es muy débil: «fue culpa de John Jairo, pero, por si las moscas, fue solo culpa de la víctima». Ante esa contestación, el juez concluye que una de las dos defensas está abiertamente equivocada: en lugar de fortalecer la defensa, se debilita.

10.6.2 Ampliación de las presunciones de culpa grave y dolo

Presunciones de dolo (Ley 2195 de 2022) —siguen siendo, en lo sustancial, las mismas—:

- 1. Que el acto administrativo haya sido declarado nulo por desviación de poder, indebida motivación, o falta de motivación, y por falsa motivación.
- 2. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.
- 3. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia contrario a derecho en un proceso judicial.
- 4. Obrar con desviación de poder.

Presunción de culpa grave (Ley 2195 de 2022):

«Se presumirá que la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o exlimitación en el ejercicio de las funciones.»

Es una «o» disyuntiva: basta la infracción directa a la Constitución o a la ley.

COMENTARIO. Crítica: el hecho base de la presunción de culpa grave es absolutamente amplio, porque el legislador quiere que el Estado gane. Si se anula un acto administrativo, el comité de conciliación dirá inmediatamente que hay que repetir, porque los actos se anulan por violar la ley, es decir, por una infracción directa a la ley: el hecho base queda configurado con cualquier sentencia de nulidad. Cualquier acto que expida María Victoria y sea anulado generará una acción de repetición en su contra. ¿Significa eso que el Estado ganará todas las repeticiones? No: se amplió el hecho base, pero el agente sigue teniendo derecho a desvirtuar la presunción. A María Victoria le costará más defenderse (tendrá que presentar una contestación «de verdad»), pero podrá demostrar, por ejemplo, que en el acto expuso toda la evolución jurisprudencial y explicó por qué prefería una tesis sobre otra; seguramente se concluirá que no se demostró la culpabilidad. La lógica de la Ley 2195 en este punto es cuestionable.

10.6.3 Otros aspectos procesales relevantes de la Ley 2195 de 2022

- **Art. 8:** legitimación por activa en cabeza de la entidad condenada, el Ministerio Público y la ANDJE.
- **Art. 11:** la caducidad se extiende a cinco años.
- **Art. 12:** conciliación y reducción de capital según ingresos o patrimonio.
- **Art. 13:** acuerdos de pago y reducción de capital.
- **Arts. 23 a 25:** se elimina la necesidad de prestar caución; se agrega el embargo de salarios.

10.7 Jurisprudencia relevante reciente sobre la acción de repetición

SU-354 de 2020:

- Finalidades preventiva y retributiva de la acción de repetición. Carácter subsidiario, subjetivo y sujeto a criterios de proporcionalidad.

- «Estricto juicio de atribución de responsabilidad»; derecho de defensa.
- Configurar el supuesto de hecho de la presunción frente al demandado.
- Determinar la proporcionalidad de las consecuencias contra el agente.

SU-259 de 2021:

- Juicio de reproche subjetivo contra el agente.
- Garantías del principio de culpabilidad; superar criterios abstractos como el del «buen padre de familia».